

CELSO DE MORAIS

Prefácio de Renato Opice Blum

DESMISTIFICANDO A LGPD

Entenda como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
pode ser aplicada no dia a dia das empresas e das pessoas

Livro com realidade
aumentada disponível
neste QR CODE



DIALÉTICA
EDITORA

CELSO DE MORAIS

Prefácio de Renato Opice Blum

DESMISTIFICANDO A LGPD

Entenda como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
pode ser aplicada no dia a dia das empresas e das pessoas

Livro com realidade
aumentada disponível
neste QR CODE



DIALÉTICA
EDITORA

CONSELHO EDITORIAL



Alexandre G. M. F. de Moraes Bahia
André Luís Vieira Elói
Antonino Manuel de Almeida Pereira
Antônio Miguel Simões Caceiro
Bruno Camilloto Arantes
Bruno de Almeida Oliveira
Bruno Valverde Chahaira
Catarina Raposo Dias Carneiro
Christiane Costa Assis
Cíntia Borges Ferreira Leal
Eduardo Siqueira Costa Neto
Elias Rocha Gonçalves
Evandro Marcelo dos Santos
Everaldo dos Santos Mendes
Fabiani Gai Frantz
Flávia Siqueira Cambraia
Frederico Menezes Breyner
Frederico Perini Muniz
Giuliano Carlo Rainatto
Helena Maria Ferreira
Izabel Rigo Portocarrero
Jamil Alexandre Ayach Anache
Jean George Farias do Nascimento
Jorge Douglas Price
José Carlos Trinca Zanetti
Jose Luiz Quadros de Magalhaes
Josiel de Alencar Guedes
Juvencio Borges Silva
Konradin Metze
Laura Dutra de Abreu
Leonardo Avelar Guimarães
Lidiane Mauricio dos Reis
Ligia Barroso Fabri

Lívia Malacarne Pinheiro Rosalem
Luciana Molina Queiroz
Luiz Carlos de Souza Auricchio
Marcelo Campos Galuppo
Marco Aurélio Nascimento Amado
Marcos André Moura Dias
Marcos Antonio Tedeschi
Marcos Pereira dos Santos
Marcos Vinício Chein Feres
Maria Walkiria de Faro C Guedes Cabral
Marilene Gomes Durães
Mateus de Moura Ferreira
Milena de Cássia Rocha
Mortimer N. S. Sellers
Nígela Rodrigues Carvalho
Paula Ferreira Franco
Pilar Coutinho
Rafael Alem Mello Ferreira
Rafael Vieira Figueiredo Sapucaia
Rayane Araújo
Regilson Maciel Borges
Régis Willyan da Silva Andrade
Renata Furtado de Barros
Renildo Rossi Junior
Rita de Cássia Padula Alves Vieira
Robson Jorge de Araújo
Rogério Luiz Nery da Silva
Romeu Paulo Martins Silva
Ronaldo de Oliveira Batista
Sylvana Lima Teixeira
Vanessa Pelerigo
Vitor Amaral Medrado
Wagner de Jesus Pinto

CELSO DE MORAIS

Prefácio de Renato Opice Blum

DESMISTIFICANDO A LGPD

Entenda como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
pode ser aplicada no dia a dia das empresas e das pessoas

Livro com realidade
aumentada disponível
neste QR CODE



DIALÉTICA
EDITORA

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, fotocópia, gravação etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados, sem a expressa autorização da editora.

Copyright © 2023 by Editora Dialética Ltda.
Copyright © 2023 by Celso de Moraes.



 /editoradialetica

 @editoradialetica

www.editoradialetica.com

EQUIPE EDITORIAL

Editores

Profa. Dra. Milena de Cássia de Rocha
Prof. Dr. Rafael Alem Mello Ferreira
Prof. Dr. Tiago Aroeira
Prof. Dr. Vitor Amaral Medrado

Designer Responsável

Daniela Malacco

Produtora Editorial

Yasmim Amador

Controle de Qualidade

Marina Itano

Capa

Helena Dias

Diagramação

Maiara Souza

Preparação de Texto

Nathália Sôster

Revisão

Responsabilidade do autor

Assistentes Editoriais

Jean Farias
Larissa Teixeira
Ludmila Azevedo Pena
Thaynara Rezende

Estagiários

Diego Sales
Laís Silva Cordeiro
Maria Cristiny Ruiz



Conversão para ePub: Cumbuca Studio

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M828d Moraes, Celso de.
Desmistificando a LGPD : entenda como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pode ser aplicada no dia a dia das empresas e das pessoas / Celso de Moraes. – São Paulo : Editora Dialética, 2023.
E-book: 1 MB. ; EPUB.

Inclui bibliografia.
ISBN 978-65-252-7190-3

1. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 2. Empresas. 3. Direito.
I. Título.

CDD 343.07
CDU 343

Ficha catalográfica elaborada por Mariana Brandão Silva CRB -1/3150

“É muito importante que haja uma lei adaptada ao risco, que não trabalhe estritamente com proibições, mas que tente identificar os níveis de risco e, a partir disso, aplique medidas de proteção ou de prevenção de risco.”

Prof. Wolfgang Hoffmann-Riem

A Deus pela vida e pelo dom da advocacia. Foi no exercício sincero desse dom que planejei e idealizei este livro após muitas horas de estudo e dedicação.

A minha família, em especial a minha esposa, Jeane D’Arc Melo pelo companheirismo, parceria e incentivo nos dias difíceis, e a minha filha, Júia Melo de Moraes. Agradeço por me motivarem a deixar um legado útil e de contribuição ao próximo.

Aos meus colegas e funcionários do escritório, Moraes & Advogados, com quem compartilho minhas ideias, metodologias e sempre me estimulam a ser melhor e a inovar na forma de atender e representar os clientes.

Ao Dr. Renato Opice Blum, que gentilmente aceitou o convite de escrever o prefácio do livro. Atitude que me fez sentir honrado, pois sei de sua competência e da complexidade de sua agenda. Suas palavras acerca deste projeto são de grande valia.

Aos amigos e clientes que me impulsionam em uma evolução contínua e de aprendizagem dentro do Direito Digital, sobretudo, nos dias atuais, em que a Proteção de Dados tem sido amplamente discutida. É com vocês que mais aprendo.

PREFÁCIO

■

Quando lembro do caminho percorrido antes da promulgação de uma Lei brasileira que trata exclusivamente sobre Proteção de Dados, muitas memórias me vêm à mente, sobretudo a possibilidade de vivenciar esse momento histórico, ao lado de grandes profissionais Brasil a fora.

Mesmo após três anos de vigência da LGPD e o início da possibilidade de aplicação de sanções e multas por descumprimento da Lei, questiona-se: Será que a sociedade brasileira se adaptará de vez à LGPD? Será que a atuação prática da ANPD coexistirá em harmonia com as decisões judiciais? Haverá divisão ou somatória?

Esses questionamentos são válidos, pertinentes, mas naturalmente serão respondidos com o passar do tempo e o amadurecimento da Lei.

Apesar de ser inspirada e, praticamente testada previamente pela GDPR, a LGPD possui desafios peculiares que se tornam relevantes para os profissionais das áreas que cuidam de proteção e armazenamento de dados.

A título exemplificativo, a LGPD estabelece proteção especial aos dados sensíveis, elencando as hipóteses de tratamento na própria legislação e, enquanto isso, a GDPR utiliza como regra a proibição do tratamento de dados sensíveis, estabelecendo apenas algumas exceções. Isso tudo, porque a realidade brasileira é bastante peculiar e diferente da cultura europeia.

Dentre outras muitas diferenças, mas também incontestáveis semelhanças, nos deparamos com um fim comum: proteger os dados. E isso é suficiente para entender que não há segredos para compreender a proposta de legislar sobre dados pessoais.

Sob outra ótica, costumo tratar com os meus alunos da “não proteção de dados”, ou melhor dizendo, a “desproteção de dados”. E aqui, dentro deste conceito, que tudo tem a ver com o escopo desta obra “Desmistificando a LGPD”, é certo que o caminho correto vem sendo trilhado e os dados pessoais recebendo a devida importância.

Com o advento da internet e suas ferramentas facilitadoras, vieram também a simplificação da troca de informações sigilosas, guarda e possibilidade de exposição dos usuários, com inúmeros meios de se obter dados indevidamente. Por este motivo é necessário partir da premissa de que, atualmente, fala-se em “desproteção de dados”. Em outras palavras é como se todos os dados estivessem desprotegidos, até que se prove o contrário.

Ainda que um usuário da internet tome os cuidados necessários indicados, siga à risca os protocolos de defesa e não dê brecha para insegurança cibernética, ainda assim, não estaria completamente isento de uma possível invasão em seu dispositivo móvel e, provavelmente, um seguido vazamento de dados. Isso demonstra, basicamente, que a tecnologia não para de evoluir – e é praticamente impossível acompanhar o ritmo dela, adequando-se a todo instante.

Esse pensamento não deve ser levado em consideração para “desistência” do cuidado da proteção de dados. Pelo contrário, ele visa incentivar de forma ostensiva a capacidade de reinventar medidas práticas que garantam, com suficiência, a tranquilidade dos usuários da internet.

A impressionante obra a seguir, conta com um vasto material de auxílio e proposição aos conceitos gerais e específicos da LGPD. Além de Segurança da Informação, bases legais, conceitos, Princípios e definições da Lei, há também uma atenção ao Direito Digital, Telemarketing e um profundo estudo sobre o órgão de fiscalização – a ANPD, que tanto vem somando para democratizar a LGPD.

Com o passar da leitura, certamente a compreensão se fará presente e o desafio de construir o entendimento de proteção de dados torna-se irreversível. O Autor Celso de Moraes, grande entusiasta do Direito Digital, estudioso e especialista em privacidade e proteção de dados, produz aqui uma memoriosa obra, digna de fazer parte dos principais acervos voltados ao tema. Uma honra colaborar.

Façam uma ótima leitura e que Deus lhes dê, cada vez mais, o discernimento necessário.

Renato Opice Blum¹

@renatoopiceblum

[1 Renato Opice Blum – Advogado e economista. Mestre pela Flórida Christian University. Chairman no Opice Blum, Bruno e Vainzoft Advogados. Patrono regente do curso de Pós-Graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da Escola Brasileira de Direito \(EBRADI\). Professor e coordenador dos cursos de Direito Digital e Proteção de Dados da Fundação Armando Alvares Penteado \(FAAP\). Professor em cursos no INSPER. Diretor da International Technology Law Association. Membro do Conselho da EuroPrivacy \(Senior Expert em Proteção de Dados\). Juiz do Inclusive Innovation Challenge do MIT \(Massachusetts Institute of Technology\). Presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados \(ABPDados\). Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito e Inovação da OAB-SP. Coordenador dos livros Proteção de Dados –](#)

Desafios e Soluções na Adequação à Lei (2020) e Data Protection Officer (Encarregado) – Teoria e Prática de Acordo com a LGPD e o GDPR (2020), entre outros.

SUMÁRIO

■

[Capa](#)

[Folha de Rosto](#)

[Créditos](#)

[INTRODUÇÃO](#)

[PARTE I - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO](#)

[CAPÍTULO I O QUE É E PARA QUE SERVE A SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO?](#)

[CAPÍTULO II QUAIS AS BASES LEGAIS DA LGPD?](#)

[CAPÍTULO III QUAIS AS DEFINIÇÕES DA LGPD?](#)

3.1 QUAL A DEFINIÇÃO DE LGPD?

CAPÍTULO IV O QUE SÃO CONSIDERADOS DADOS PESSOAIS?

4.1 DADOS PESSOAIS

4.2 DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

4.3 DADO ANONIMIZADO

CAPÍTULO V QUEM DEVE ADEQUAR-SE?

CAPÍTULO VI QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS?

CAPÍTULO VII POR QUE A PROTEÇÃO DE DADOS É UM DIREITO FUNDAMENTAL?

CAPÍTULO VIII QUAIS SÃO OS LIMITES DO CONSENTIMENTO?

CAPÍTULO IX DIREITO DIGITAL

CAPÍTULO X AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA

PARTE II - IMPLEMENTAÇÃO E MUDANÇAS NA CULTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I QUAIS DEPARTAMENTOS DEVEM ADEQUAR-SE?

CAPÍTULO II QUEM É A FIGURA RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS?

CAPÍTULO III SOBRE AS ADEQUAÇÕES NOS CONTRATOS

CAPÍTULO IV O QUE MUDA NO E-COMMERCE COM A LGPD?

CAPÍTULO V TERMO DE ACEITE E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

CAPÍTULO VI COMO FICAM O TELEMARKETING E O E-MAIL MARKETING?

PARTE III - FISCALIZAÇÕES E SANÇÕES

[CAPÍTULO I QUAL O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO?](#)

[CAPÍTULO II COMO A FISCALIZAÇÃO ACONTECE?](#)

[CAPÍTULO III COMO A EMPRESA PODE SE PROTEGER?](#)

[CAPÍTULO IV ADEQUAÇÃO PARA ALÉM DAS SANÇÕES](#)

[PARTE IV - BÔNUS](#)

[CAPÍTULO I CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO](#)

[REFERÊNCIAS](#)

Landmarks

[Capa](#)

[Folha de Rosto](#)

[Página de Créditos](#)

[Sumário](#)

[Bibliografia](#)

INTRODUÇÃO

De certo que, a pandemia da COVID-19 foi e está sendo, um divisor de águas na vida de muitas pessoas, empresas e profissionais. E, ao considerar que o cenário mundial passou e passa por diversas transformações em deste evento e, sabemos que essas transformações, terminam por impactar direta ou indiretamente na vida como um todo.

Não seria diferente no cenário atual, em razão do quanto o uso da internet, que foi massiva e intensamente potencializado, quando da chegada da pandemia e, claro da necessidade de isolamento das pessoas. Nesse sentido, a realização de compras e o consumo de produtos e serviços pelos meios virtuais, que tiveram um crescimento por muitos considerados assustador e que, desencadearam no uso dessas novas tecnologias, tais como, plataformas de ensino à distância, de cursos nas mais diversas áreas, realização de lives, tanto de músicas quanto de transmissão de conhecimentos sobre temas variados, redundando em um crescimento exponencial e ainda maior de pessoas que se utilizam de serviços pela internet.

Não diferente disso, tal qual o que já ocorre com a energia elétrica e água, o uso da internet, sendo um meio advindo dos serviços de telecomunicações, que se tornou um serviço essencial, pois em meio ao caos, naquele cenário inicial epidemiológico da doença, foi quando então, instalou-se o caráter de essencialidade, dada a importância dos serviços de telecomunicações para o funcionamento das mais diversas atividades dentro dos municípios, dos estados e não diferente disso, do país.

E, nesse ponto, temos que considerar ainda que, mesmo a Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (LGPD), tendo sido criada em agosto de 2018, com uma vacância de tempo para entrar em vigor de 02 (dois) anos, sua entrada em vigor culminou exatamente com o momento ainda de intensa pandemia e em 18 de setembro de 2020 a Lei entrou em vigor.

No que isso importa? Importa, pois foi exatamente nesse momento de entrada em vigor da LGPD que muitas pessoas e empresas, necessitando de informações mais claras e mais detalhadas sobre como se daria a aplicação da lei na prática, que surgiu a ideia de escrever o livro.

O fato é que, diante do advento dos grandes vazamentos de dados pessoais que desencadearam as preocupações das autoridades mundo afora, em especial na Europa, e porque não dizer, as autoridades brasileiras, que a privacidade, a proteção de dados pessoais e o próprio tratamento de dados passaram a ser evidenciados por meio de leis, mas a interpretação da lei, não deve ser um peso imposto à sociedade que merece entender sobre as regras impostas pelas leis. Nesse caso, este livro se propõe exatamente a fazer isso, desconstruir a ideia de que a necessidade de adequação a uma lei seja objeto de desgaste para a sociedade e de forma descomplicada traz informações de como é possível entender a LGPD, por meio de uma leitura leve e descontraída.

Partindo-se de uma análise sobre os conhecimentos básicos acumulados e considerando que a lei já vinha sendo estudada desde 2019. Em um primeiro olhar e buscando identificar quais elementos seriam necessários para atingir esse objetivo, considerando as formações, o interesse e até mesmo a possibilidade de levar até as pessoas parte desse conhecimento que se decidiu pela escrita de um livro, diferente de todos aqueles até ali estudados. Visto que, em sua maioria, eram compostos de conhecimentos técnicos que se limitavam a descrever apenas tecnicamente detalhes ou partes do que a lei impunha, sem contudo, explicar de forma clara, pormenorizada e com linguagem mais acessível à todos aqueles que necessitavam conhecer sobre o que de fato trata a Lei, sem que houvesse a necessidade de conhecimentos técnicos jurídicos ou conhecimentos técnicos em segurança da informação, duas áreas que são, verdadeiramente, importantes para

realizar a adequação de empresas à Lei, mas que não necessariamente são importantes para, em um primeiro olhar, as pessoas entenderem sobre o que trata exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e foi a esse papel de explicar com maior clareza sobre o que propõe a Lei, que nos dedicamos.

Para se ter uma ideia, nessa obra, você encontrará na Parte I todo um discorrer sobre Segurança da Informação, mas de uma maneira clara e de fácil interpretação, pois serão tratados temas que explicam para que serve a segurança da informação; além disso, sobre o Direito Digital e, estão sendo abordados temas, que explicam ainda, sobre as bases legais estabelecidas na LGPD, sobre a necessidade e os limites atribuídos ao consentimento, uma das bases legais da Lei para o tratamento de dados nas empresas. Assim como, sobre as definições existentes na Lei, explicações sobre o que são dados pessoais, dados pessoais sensíveis e, aqueles dados que ganharam proteção especial da Lei, sobre crianças e adolescentes.

Outro ponto interessante trazido na parte I do livro é a questão de a proteção de dados ter se tornado um direito fundamental e também, em uma descrição clara e objetiva, sobre quais são os direitos dos titulares de dados e como não poderia deixar de lado, o livro trata de explicar de forma particular, sobre um dos principais direitos protegidos pela Lei. Nesse caso, o direito à autodeterminação informativa, que o livro trata de explicar com riqueza de detalhes, inclusive, sobre sua importância para a garantia da proteção pretendida pela LGPD.

Na Parte II do livro buscou-se descrever também de forma muito detalhada, sobre a importância e sobre a necessidade das empresas, no processo de adequação e implementação da legislação geral de proteção de dados, cuidar da mudança cultural não apenas de seus colaboradores. Mas especialmente, da toda a diretoria das empresas, passando a adequação por cada um dos setores, indicando quem é a figura responsável pelo tratamento dos dados dentro das empresas, sobre a importância e obrigatoriedade da adequação de todos os contratos da empresa, tanto os novos quanto os já existentes e, um outro ponto que é exaustivamente esclarecido no livro, pois em muitos casos no dia a dia é

confundido e muito mal interpretado é que é sobre a Política de Privacidade da empresa, que dada a sua importância, o livro cuidou de explicar com riqueza de detalhes, inclusive, deixando claro, que a Política de Privacidade, na prática não se resume a um simples documento publicado no site das empresa e pronto, mas fica demonstrado em capítulo próprio, toda a importância dessa Política de Privacidade ser tratada como um projeto cultural dentro da empresa e não apenas, como um documento.

A Parte III do livro traz como se dará o processo fiscalizatório determinado pela Lei e demonstrar que a fiscalização não se resume à aplicação das sanções, mas também deixa claro, como as empresas poderão se proteger, avaliando se existem e quais são, os benefícios, para além das sanções.

Por fim, o livro ainda traz um chamado uma última Parte, intitulada de Bônus, composta por um capítulo – Consultoria e Implementação, que reserva particularidades interessantes para tornar mais acessível ainda, aquilo que o leitor pode pretender ou não, como intenção ou interação, após absorver o conteúdo proposto pelo livro e, na condição de se ver diante da possibilidade de uma tomada de decisão, poder facilmente, definir sobre suas escolhas.

PARTE I

■

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CAPÍTULO I O QUE É E PARA QUE SERVE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO?

De início, quando pensamos em Segurança da Informação, pensamos quase que necessariamente, que esse é um conteúdo essencial e por que não dizer, indispensável para que possamos estabelecer minimamente a possibilidade de compreensão de alguns pontos tidos como importantes ou até mesmo necessários para fornecer dentro do cenário atual do avanço tecnológico, do Direito Digital e, do próprio tratamento de dados que tem sido o foco do que precisa ser pensado dentro do novo conceito de acultramento das empresas, quer para que esteja em conformidade com a Lei, quer para que esse tratamento de dados seja um diferencial de mercado, enquanto respeito aos titulares e à proteção dos seus dados pessoais.

Ao que perguntamos: O que é, afinal, Segurança da Informação? Temos, pois, que a Segurança da Informação é uma espécie de proteção dos dados, que supostamente, são de propriedade das organizações, contra os mais diversos tipos de ameaças que podem ocorrer. Veja-se que, quando digo supostamente é por quê, particularmente, entendo que são de propriedade dos titulares dos dados e não propriedade das empresas como elas têm entendido e agido. Tal entendimento se baseia, dentre outras coisas, no que diz a Lei, conforme se pode observar pela leitura do Art. 17 da Lei nº 13.709/18, a saber, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Vejamos:

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.

A Segurança da Informação pode ser resumida em um conjunto de esforços empreendidos pelas empresas, como ações que têm como objetivo minimizar os riscos de vazamento de dados, visando a garantia da continuidade das suas atividades, das suas operações, quaisquer que sejam elas.

Assim, partindo da definição do que é, em síntese, “segurança” e ato contínuo, pensarmos na questão da “informação” propriamente dita e, não diferente disso, pensarmos e/ou correlacionarmos a um sistema, cuja finalidade está relacionada à proteção, já que estamos falando de segurança e essa segurança se mostra necessária para proteger contra ameaças ou tentativas de invasão as informações de uma empresa ou mesmo, de informações pessoais.

Portanto, segurança é a condição de colocar algo ou alguém livre ou fora de perigo, evitando assim, que este, esteja exposto a riscos e a danos ou a situações que possam gerar danos.

Já por informação entende-se que são os dados. Vale dizer que nos últimos tempos, tornou-se, como muito se tem noticiado, o novo petróleo mundial, dada a importância que os dados (informações) para as empresas que atualmente são responsáveis pelos maiores faturamentos no mercado². Saibam que diferente do petróleo, que necessita ser localizado e extraído de profundezas submarinas ou subterrâneas, os dados são facilmente “conseguidos” por serem culturalmente disponibilizados a todo instante na internet, por meio de preenchimento de formulários, autorização de navegação em sites, dentre outros. Estes são compartilhados livremente entre os usuários e as empresas e até então, sem nenhum critério de segurança, respeito ou proteção a esses dados.

Em seguida, pensar na questão da Segurança da Informação, a partir da junção dessas duas definições, segurança e informação, nos leva a entender qual a relação existente entre elas e o impacto que essa definição tem para o que iremos propor aqui.

Dessa forma, necessário se faz aprofundar mais no quesito Segurança da Informação, como ponto de partida para abordarmos desde os temas auxiliares, passando pelos temas que dão suporte a uma melhor compreensão do que nos importa aqui, a saber, a compreensão relativa à Privacidade e à Proteção dos Dados Pessoais até, efetivamente, atendermos aos anseios da proposta principal que é a relação que o tema segurança da informação guarda, enquanto base legal, com a Lei Geral de Proteção Dados Pessoais.

Dito isso, importa-nos pensar que necessário se faz, então, conceituar segurança e informação.

O tema ganha relevância quando relacionamos aos inúmeros eventos que noticiam grandes e constantes vazamentos de dados de usuários no âmbito da internet e que, a todo momento, as manchetes de jornais são tomadas por números que cada vez se tornam mais e mais expressivos, como por exemplo, a notícia recente (em 2020)³ de um grande vazamento de dados na base da Serasa (Centralização de Serviços de Bancos), que terminou por expor dados de milhões de brasileiros, gerando insegurança e um grande temor a muitos consumidores que ali têm, obrigatoriamente, seus dados pessoais creditícios ou mesmo, do ocorrido com os dados de mais de 87 (oitenta e sete) milhões de usuários do Facebook⁴, pela empresa Cambridge Analytica - uma consultoria política - que usou essas informações a serviço de campanhas políticas, que ajudaram a eleger políticos, sendo a de maior expressão aquela que elegeu o então presidente do Estados Unidos da América, Donald Trump, em 2016.

Nesse ponto, pensar em Segurança da Informação é, em primeiro momento, pensar que tem sido o que se mostra como primordial e como prática interna nas empresas, uma espécie de busca constante por identificar e evitar que existam vulnerabilidades nos sistemas internos dessas organizações, como forma de garantir, que haja um crescimento constante e escalonável, como forma de sempre encontrar soluções que buscam garantir a proteção de seus sistemas, tornando-os livres de ataques cibernéticos ou ao menos, minimizando os riscos

decorrentes desses ataques, considerando estes têm se tornado cada vez mais constantes e sofisticados.

Veja-se que a segurança e a proteção das informações na área dos negócios têm ocupado um lugar de destaque nas empresas, pois muito se tem aplicado os princípios ligados à Segurança da Informação e de dados. Isso ocorre porque as empresas têm buscado soluções cada vez mais robustas e eficazes para garantir a Segurança da Informação e de dados.

Há quem diga que, “lidar com segurança de dados é lidar com crises”. Portanto, aqui, importa ainda dizer que a legislação, por muito tempo, não se ocupou de cuidar da segurança que os dados e as informações sempre precisaram.

Nesse sentido, não se pode deixar de mencionar que, a Segurança da Informação, vista da ótica da legislação atual, encontra guarida, pois a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (sobre a qual iremos dissecar mais detalhadamente adiante) traz em seu bojo a determinação expressa de que os agentes de tratamento de dados devem, obrigatoriamente, adotar medidas técnicas, administrativas e de segurança que sejam eficazes para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, buscando segurança e proteção contra situações, desde acidentais até aquelas consideradas ilícitas e que se mostram das mais diversas formas e naturezas.

Na referida Lei visualiza-se de forma cristalina a necessidade que as empresas têm de adotar procedimentos de segurança à proteção dos dados, que consiste no que tem se chamado de privacidade by design. Ou seja, as empresas devem buscar a segurança desde o início, desde a concepção do produto ou serviço até atingir o fim da sua execução.

Outro ponto a ser considerado, consiste no fato de que essa Lei não se ocupou de

estabelecer ou eleger um padrão específico de segurança. Parece-nos que ela entendeu que os padrões de segurança estão em constante mutação, constante evolução e, claro, se podem mudar a todo instante, não pode existir um específico.

É notório que a área de Segurança da Informação das empresas lida constante e diariamente com um número enorme de incidentes, que terminam por colocar em risco os dados de seus clientes. Esse tem sido um grande desafio dentro das empresas, pois a proteção de dados clientes passou a ganhar notoriedade, desde a entrada em vigor da nova Lei (sobre isso trataremos mais adiante).

Importa ainda dizer que as empresas têm se ocupado e se preocupado em criar programas de governança que sejam cada vez mais voltados para concretizar os princípios da segurança e da prevenção. Nesse tocante, cumpre-nos dizer que os princípios são, em linguagem simples, um conjunto de normas ou mesmo até podem ser considerados, como normas fundamentais que estabelecem ou que norteiam os rumos que devem ser seguidos por uma pessoa ou mesmo por uma organização como busca pelo correto, enquanto busca também por um padrão de conduta.

Quanto ao princípio da segurança tem-se que ele visa garantir que determinadas organizações - quando efetivamente preocupadas com a segurança dos dados dos seus clientes - devem estar sempre cercadas de cuidados que visam, sobretudo, garantir - no mínimo - a confidencialidade e a integridade dos dados que lhes são confiados pelos clientes.

Não por acaso que na área de tecnologia estabeleceu-se que são três os princípios da Segurança da Informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Muito embora haja quem diga que existe um quarto princípio que é o da autenticidade.

A confidencialidade, em rápida síntese, está relacionada a maneira como é realizada a proteção dos dados dentro da empresa ou organização, visando sempre, proteger e evitar ataques.

A integridade guarda relação com a proteção para que nenhum dado dentro da organização seja alterado ou modificado de forma indevida.

Já que mencionamos a disponibilidade, entendemos que ela é a garantia de que esses dados constantes nos sistemas da empresa possam ser acessados a qualquer tempo, pelos detentores do direito a esses dados. Ou seja, eles precisam estar disponíveis para seus titulares quando esse acesso for necessário por alguma razão.

A autenticidade pode ser entendida como a maneira exata como esses dados são mantidos em poder da empresa, tal qual eles foram fornecidos e confiados.

De certo que a pandemia da COVID-19 exigiu das empresas a necessidade de implementação de medidas, que sinalizaram para um avanço sem precedentes, no processo de digitalização. E exatamente nesse contexto, a Segurança da Informação ganhou notoriedade devido o aumento do tráfego de informações entre pessoas, entre empresas e mesmo entre países. Não poderia deixar de ser uma preocupação dentro das organizações a maneira como esses dados são ou devem ser protegidos, com vista a não permitir que haja impactos em suas atividades, decorrentes da quebra da segurança dessas informações.

Já que os dados são o novo petróleo, visto que são, indiscutivelmente, muito valiosos, de fácil “extração” e obtenção. Uma vez que são fornecidos o todo tempo e até sem critérios, pelos usuários, o que coaduna com o fato de as grandes empresas do mercado sequer cobrarem por muitos dos serviços que são oferecidos aos seus usuários, a exemplo disso, Facebook, Instagram, Google,

dentre outras. Tal qual o valor desses dados para essas empresas, bem como, para as empresas parceiras, pois são - repito - indiscutivelmente, uma fonte inesgotável e sempre passível de expansão, isso porque são considerados verdadeira matéria-prima para todos os produtos e serviços que são disponibilizados a todo instante através do uso da internet e tudo que dela deriva, em especial, as redes sociais que são - de igual modo - o maior veículo de captação desses dados.

O que se percebe é que as empresas enfrentam e enfrentarão como grande desafio que é a utilização adequada dos dados que lhes são fornecidos e confiados, utilizando-os com inteligência. A partir de uma combinação desses dados que são armazenados (criando perfis de consumos), as empresas poderão gerar novos e cada vez mais relevantes, produtos e serviços que quando criados poderão, com base nos dados já existentes, serem facilmente oferecidos e entregues.

Assim, esse trabalho “inteligente” artificialmente vai cada vez mais coexistir com a necessidade de se potencializar a segurança dos dados, até como forma de se criar estratégias para as tomadas de decisões que permitirão que esses dados se perpetuem em suas bases de dados. Isso, claro, considerando que os ditames legais sejam respeitados, como por exemplo, a justificativa da finalidade do uso desses dados, por meio do uso de uma base legal, ainda que esta seja o consentimento (sobre o que trataremos de forma bem exaustiva adiante, visto que esse tema é de grande relevância).

Conclui-se, portanto, que a Segurança da Informação é um conjunto de esforços que são empreendidos pelas organizações. Esses esforços têm como objetivos minimizar os riscos e garantir a continuidade das suas atividades e/ou operações. É uma ferramenta para a continuidade e escalabilidade do uso dos dados, eis que protegidos e cada vez mais confiáveis, do ponto de vista de quem os “entrega” a serem tratados.

A Segurança da Informação serve – indiscutivelmente - para garantir que os dados sejam e estejam protegidos. Sempre com base nos pilares da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, que visam garantir que as organizações, efetivamente preocupadas com a segurança dos dados dos seus clientes, se cerquem de todos os cuidados que garantam a segurança dos dados que lhe são entregues e confiados pelos clientes, a saber, os titulares dos dados.

2 As “empresas que mais faturam no mercado” atualmente, são aquelas que exploram a utilização maciça dos dados, por exemplo, Google, Facebook, Instagram, etc., sem necessitar adentrar em águas profundas ou perfurar o solo em busca da matéria-prima, pois apenas coletam dados, sua matéria-prima.

3 Fonte da notícia: <<https://tecnoblog.net/428888/procon-sp-nao-gostou-das-respostas-do-serasa-sobre-vazamento-de-dados/>>. Acesso em 09/12/21 às 07h08min.

4 Fonte da notícia: <<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-eleva-para-87-milhoes-o-n-de-usuarios-que-tiveram-dados-explorados-pela-cambridge-analytica.ghtml>>. Acesso em 09/12/21 às 07h21min.

CAPÍTULO II QUAIS AS BASES LEGAIS DA LGPD?

Desde o início da criação da Lei que muito se falou que ela viria para proibir o tratamento de dados, mas não, decorrido esse tempo de análise da Lei, a cada dia fica mais claro, que essa veio para regular a maneira correta como as empresas realizam o tratamento de dados, desde a coleta até o armazenamento dos dados pessoais.

Assim, resta claro, que a LGPD tem como função principal regular as atividades de tratamento de dados pessoais e, também alterou os Arts. 7º e 16º do Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/14 - que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil), obrigando todas as empresas, quer públicas ou privadas, a se adequarem as exigências trazidas pela Lei.

Veja-se que, a Lei se aplica a toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, independente de porte, regime fiscal ou área de atuação, a quem compete tomar decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No caso da pessoa física o mencionado tratamento de dados precisa ter cunho financeiro, ou seja, a obtenção de lucro com o tratamento dos dados, por exemplo, qualquer profissional autônomo, que se utiliza dos dados pessoais de uma ou mais pessoas para aferir lucro em sua atividade, como por exemplo, um advogado, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico, um nutricionista, dentre outros vários profissionais que ainda que não possuam um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) desenvolvem suas atividades, utilizando-se da coleta e tratamento dos dados pessoais.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece em seu Artigo 7º os requisitos para o tratamento de dados pessoais e afirma que o tratamento de

dados somente pode ocorrer quando for realizado em uma das hipóteses constantes do rol descritivo do Artigo.

Em nosso entendimento não basta dizer que são 10 (dez) as bases legais, tendo em vista, a necessidade de explicar, ainda que resumidamente, quais são essas bases legais, a partir do que disciplina o Art. 7º, da Lei nº 13.709/18.

Assim, temos que as BASE LEGAIS são, em síntese, uma série de hipóteses que contém requisitos que possibilitam o tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei e frisa-se que esses dados somente podem ser tratados a partir dessas hipóteses. Veja-se:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

[...] (BRASIL, 2018).

O fornecimento do consentimento pelo titular dos dados, cujo entendimento é o de que esse consentimento, quando escrito, deve ser destacado das demais cláusulas sempre de forma clara, expressando a manifestação inequívoca da vontade do titular, não pode haver vício nesse consentimento, além de que este poderá ser revogado a qualquer tempo.

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

[...] (BRASIL, 2018).

O cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, em resumo, refere-se à justificativa do tratamento de dados em razão da obrigação que a empresa tem, de cumprir o que está estabelecido em outras leis. Em uma situação hipotética, em que um funcionário, após se desligar da empresa, decide acionar juridicamente seu antigo empregador e requerer a eliminação dos seus dados. Ocorre que, em decorrência de outra Lei, a empresa é obrigada a armazenar os dados por determinados períodos até mesmo para apresentar sua defesa em caso de processos judiciais ou, por exigência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo.

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

[...] (BRASIL, 2018).

O tratamento de dados pela Administração Pública que ocorre quando é necessário pela administração o uso compartilhado de dados, necessários à execução de políticas públicas.

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

[...] (BRASIL, 2018).

Quando da realização de estudos em órgãos de pesquisa, poderá o órgão justificar que a finalidade do tratamento seja especificamente, para a realização

de pesquisa científica, histórica, estatística ou mesmo tecnológica, sempre por meio de órgão de pesquisa devidamente registrado. Veja-se que não se trata de uma hipótese para realização de qualquer pesquisa por qualquer empresa.

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

[...] (BRASIL, 2018).

Para a execução de contrato realizado com o titular de dados e a pedido dele poderá a empresa de forma legítima, na condição de controladora, diante da necessidade de manipular informações pessoais, utilizar-se desta base legal observando os limites da finalidade que deverá estar ligada ao tipo de prestação de serviço estabelecida como objeto do contrato.

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

[...] (BRASIL, 2018).

Essa base legal do exercício regular de direitos, tem como objetivo assegurar o direito de acesso à justiça, que é garantido pela Constituição. Trata-se de um direito que toda pessoa, enquanto cidadão, tem de poder ingressar com uma ação ou se defender em um processo judicial. Dessa forma, toda vez que uma pessoa, sendo parte de um contrato, desejar fazer uso do seu direito de ação, quer administrativa, judicial ou ainda, mediante o juízo arbitral, poderá ingressar com uma ação em face da outra parte, sendo, portanto, dispensado nesse caso, o consentimento para validar a utilização dos dados.

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
[...] (BRASIL, 2018).

Para a proteção da vida ou integridade física, é possível o tratamento dos dados, mesmo sem o consentimento do titular. Como por exemplo, em caso de um acidente, encontrando-se impossibilitado de acionar o socorro ou mesmo de solicitar ajuda a um familiar, poderá utilizar-se do acesso aos documentos de uma pessoa para, exclusivamente, essa finalidade.

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência.

[...] (BRASIL, 2018).

No que diz respeito a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias, poderão tratar dados pessoais que sejam necessários para a realização de suas atividades. Podemos citar como exemplo, a análise de dados, quando necessária para uma campanha de vacinação ou mesmo para notificar pacientes sobre o resultado de exames.

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

[...] (BRASIL, 2018).

O legítimo interesse, considerada uma das bases legais mais flexíveis, é uma das

hipóteses em que é possível o tratamento de dados pessoais, mesmo que não haja o consentimento do titular dos dados e se aplica, por exemplo, nas situações em que o tratamento será realizado para fins legítimos, com base no caso concreto, como a prestação de serviços que beneficia diretamente o titular dos dados.

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

[...] (BRASIL, 2018).

A base legal da proteção do crédito tem por finalidade a garantia de que, em situações de cobrança da dívida, por exemplo, os titulares dos dados não utilizem de mecanismos da LGPD como argumentos para escaparem de suas obrigações financeiras perante a instituição credora.

Deve-se atentar ao fato de que para o início de um projeto de adequação, o profissional deve analisar e avaliar os riscos: avaliar os mecanismos de segurança das bases de dados e, obrigatoriamente, deve analisar e definir as bases legais para o tratamento dos dados pessoais.

Além disso, é muito importante que haja a definição de uma base legal para as atividades de processamento de dados da organização e para isso, é necessária uma equipe ou indivíduos responsáveis por definir as bases jurídicas das quais a empresa depende para desenvolver sua atividade.

Importa-se dizer, que as bases legais tiveram origem ou foram embasadas no GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679), um regulamento do direito europeu que versa sobre privacidade e sobre proteção de dados pessoais. Tornou-se aplicável a todos os cidadãos da União Europeia, tendo sido criado no ano de 2018 e traz como exigência, o fato de que todas as

empresas, organizações e os órgãos públicos utilizem das bases legais para manipular os dados pessoais.

Importa ainda deixar claro que o objetivo principal da LGPD é garantir a proteção e privacidade dos dados pessoais, de modo que o usuário tenha controle sobre o uso, compartilhamento e armazenamento de suas informações. Isso, porque diante da revolução dos dados e mesmo da presença e do significativo uso da inteligência artificial, no decorrer do tempo, vem surgindo paralelamente, muitas formas de cruzamento de dados, o que por via de consequência, vem permitido de forma “descontrolada”, o acesso às diversas informações, que muitas das vezes deveriam ser exclusivamente pessoais e por que não dizer, confidenciais.

O fato é que, diante desse cenário, as empresas se valiam dos dados dos usuários de maneira considerada ilegal, uma vez que vos utilizavam de forma ilimitada. O uso na maioria das vezes era em benefício próprio das empresas, o que é totalmente condenável, visto que os titulares de dados, na maioria maciça das vezes, sequer tinham conhecimento do uso de seus dados. Veja-se que, a partir desse uso “desautorizado” dos dados pessoais pelas empresas foram criadas as BASES LEGAIS. Ou seja, para que os dados pessoais das pessoas naturais pudessem estar protegidos de ações de tratamento de dados de maneira antiética.

Assim, a partir da criação das bases legais as empresas podem realizar de forma fundamentada, o tratamento de dados, por exemplo: considerando o que dispõe o Art. 5º, inciso XII da LGPD, em que o consentimento fornecido pelo titular expressa a manifestação livre, informada e inequívoca de que o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Dessa maneira, nos setores de marketing e de vendas, que são considerados “o carro chefe” dentro de muitas empresas, visto que são responsáveis pela captação de novos negócios. Podendo, portanto, a empresa, utilizar-se da base legal do consentimento, que como explicitado alhures, deve ser fornecido pelo

titular dos dados de forma livre e inequívoca, concordando com a realização do tratamento dos dados, desde que, a finalidade determinada seja aquela indicada no consentimento, a saber, por exemplo, o envio de publicidades. O que até então não era realizado pelas empresas.

Ou seja, a utilização desta base legal permite que empresa, quando da realização de uma compra por meio do seu site, utilizando-se da base legal do consentimento pode usar uma declaração, em que o usuário expressamente afirma que concorda com a utilização dos seus dados por aquela empresa. Uma vez marcando sim para a pergunta concorda em receber, por exemplo, e-mails promocionais informando sobre o recebimento de novos comunicados de venda, isso por meio das informações que foram fornecidas para a realização da compra. Frisa-se que essa hipótese também se aplica normalmente, e de igual modo, a aceitação da política de privacidade da empresa.

De igual modo, pode-se utilizar o exemplo do Art. 7º, inciso IX, ainda o Art. 10º da mesma lei, onde fica expresso que o legítimo interesse da empresa, que é o controlador dos dados, pode basear o tratamento dos dados para finalidades consideradas legítimas.

Conclui-se, portanto, que a utilização correta das bases legais por parte da empresa, permite que as empresas tratem dados, garantindo a proteção e a privacidade dos dados pessoais do usuário, permitindo que o usuário tenha controle sobre o uso, o compartilhamento e o armazenamento das informações que lhe foram fornecidas.

CAPÍTULO III QUAIS AS DEFINIÇÕES DA LGPD?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais trouxe em seu escopo diversas definições, que particularmente, consideramos essenciais para que se possa entender de forma clara e objetiva o teor do quanto pretendido pela Lei.

Demais disso, importa ainda esclarecer, que a lei brasileira foi inspirada na lei europeia - a GDPR (General Data Protection Regulation⁵ – Relatório Geral de Proteção de Dados) -, o chamado Regulamento 679/16 - o que não é privilégio somente do Brasil, pois a lei europeia inspirou diversos outros países na elaboração de suas leis de proteção de dados.

Assim, como dito acima, abordaremos, ainda que brevemente, sobre as principais definições existentes na Lei em comento, como forma de tornar a leitura, o mais clara possível.

De início, devemos considerar que a principal definição sobre a qual devemos nos debruçar, é definição da própria Lei.

3.1 QUAL A DEFINIÇÃO DE LGPD?

Veja-se que trataremos das definições de forma resumida, tendo em vista, que trataremos de forma mais ampla e descritiva, em capítulo próprio.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – a saber, a Lei 13,709/18 é uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de garantir a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2018).

É, portanto, uma Lei que ao contrário do que muitos pensavam: que viria para “proibir” o tratamento de dados. Em verdade veio para proteger a maneira correta como as empresas devem tratar os dados pessoais dos cidadãos.

A Lei traz consigo ainda, algumas definições que são, como dito, importantes para uma melhor compreensão, por exemplo, do objetivo pretendido e seus desdobramentos. Dessa maneira:

DADOS PESSOAIS: dado pessoal é toda e qualquer informação relativa à pessoa física (pessoa natural), que pode ser identificada ou identificável;

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: há ainda, nas definições da Lei, os dados pessoais sensíveis, que são uma espécie de dados considerados como toda informação pessoal que pode causar constrangimento ou discriminação ao titular dos dados;

DADO ANONIMIZADO: o dado anonimizado é aquele dado que quando de início constava como sendo relativo a uma pessoa, mas que em algum momento da etapa de tratamento foi desvinculado de determinada pessoa, tornando-a de certa forma “anônima”;

BANCO DE DADOS: o banco de dados é um conjunto de informações, sistematicamente organizados dentro de uma empresa, que normalmente, seu armazenamento se dá de forma eletrônica por meio de computadores ou servidores;

CONTROLADOR: a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete tomar decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No caso da pessoa física, o mencionado tratamento de dados precisa ter cunho financeiro, ou seja, a obtenção de lucro com o tratamento dos dados, por exemplo, qualquer profissional autônomo, que se utiliza dos dados pessoais de uma ou mais pessoa para aferir lucro em sua atividade, como por exemplo, um advogado, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico, um nutricionista, dentre outros vários profissionais que, ainda que não possuam um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) desenvolve sua atividade, utilizando-se da coleta e tratamento dos dados pessoais;

OPERADOR: é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS: a Lei tratou de estabelecer que no referido Art. 5º, inciso VIII, o encarregado - de proteção de dados - será uma pessoa que deve ser indicada pelo controlador e pelo operador, pois ambos necessitam do encarregado e que este deve atuar como uma espécie de canal de comunicação entre o controlador e a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), bem como entre o controlador e os titulares de dados;

ANPD - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: é o órgão da Administração Pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei. Está diretamente ligada ao Poder Executivo;

TRATAMENTO DE DADOS: é toda e qualquer operação ou conjunto de operações que são realizadas com os dados pessoais ou mesmo em um conjunto de dados pessoais, seja ou não por meios automatizados, como, por exemplo, a coleta, a produção, a recepção, a classificação, a utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, a distribuição, o processamento, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação, a avaliação ou o controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Enfim, qualquer manipulação que ocorra com os dados dentro da empresa é considerada tratamento de dados.

5 Fonte:

<<https://www.hscbrasil.com.br/gdpr/#:~:text=Em%2025%20de%20maio%20de,em%202016%20pelo%20Parlamento%20Europeu>>. Acesso em 09/12/21 às 07h:24min.

■

CAPÍTULO IV O QUE SÃO CONSIDERADOS DADOS PESSOAIS?

■

4.1 DADOS PESSOAIS

Parte-se de princípio, de que um dado pessoal é qualquer informação que permite que uma pessoa possa ser identificada a partir daquela informação, quer de forma direta ou mesmo de forma indireta.

Para a LGPD, importa dizer, que a pessoa em comento precisa estar viva, pois a LGPD não trata da proteção de dados de pessoas mortas.

Dessa forma, aquelas informações sobre a pessoa, como o nome, RG e CPF, número de telefone, endereço, conta de e-mail, data de nascimento, local de nascimento, além de informações sobre sua localização, informações sobre saúde, biometria, são considerados dados.

Os dados pessoais são: toda e qualquer informação relativa à pessoa física (pessoa natural), que pode ser identificada ou identificável, vejamos por outra via:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

[...] (BRASIL, 2018).

Quando a empresa dispõe desses dados e por meio de um cruzamento de dados tem-se uma pessoa identificada. Por outro lado, quando se tem, por exemplo, apenas o número de uma placa de automóvel, aquele dado torna a pessoa identificável, pois no primeiro momento, possui-se apenas um dado, mas esse dado pode levar à identificação completa de uma pessoa, considerando que em seu cadastro no órgão emissor da placa do veículo, nesse caso, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), constam todas as informações que tornarão aquela pessoa, antes identificável, agora identificada.

É muito importante deixar claro que a Lei não entende como dados pessoais, aqueles dados que são relativos à pessoa jurídica, ou seja, às empresas, portanto, dados como Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), razão social da empresa, o endereço comercial, telefone da empresa, dentre outros relativos a empresa, não são considerados dados pessoais, visto que se referem à pessoa jurídica e não a pessoa natural, como assim definiu a Lei.

4.2 DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

Há ainda, nas definições da Lei, os dados pessoais sensíveis, que são uma espécie de dados, considerados como toda informação pessoal que pode causar constrangimento ou discriminação ao titular dos dados.

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

[...] (BRASIL, 2018).

Por exemplo, aqueles dados que tratam sobre origem racial ou étnica, sobre convicção religiosa ou sobre opinião política. Dados que tratam sobre filiação a um sindicato ou uma organização de caráter religioso, também de caráter filosófico ou mesmo de caráter político.

Ainda há aqueles dados referentes a saúde ou a vida sexual de uma pessoa, aqueles genéticos ou biométricos que são considerados dados que dizem mais ou muito mais sobre a pessoa, em especial, na espécie os mais sensíveis, chamamos a atenção para os que versam sobre crianças e adolescentes.

Sobre os dados sensíveis de crianças e adolescentes, especialmente, a lei tratou de reservar uma sessão própria, data sua importância e no Art. 14 da lei. Ficou estabelecido:

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente (BRASIL, 2018).

Veja-se que, a LGPD, na condição de lei geral, compatibiliza-se com os demais diplomas legais. E nesse caso, a LGPD manteve e trouxe em seu bojo, a antiga preocupação já existente Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é em especificamente, proteger os direitos fundamentais desse grupo de pessoas, consideradas frágeis do ponto de vista da Lei. Portanto, já no parágrafo primeiro do mencionado Artigo, descreve sobre a necessidade de um consentimento especial para a realização do tratamento de dados:

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal (BRASIL, 2018).

Assim, em síntese, para que ocorra o tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes deve, obrigatoriamente, ser realizado mediante o consentimento específico. Nesse sentido, a Lei traz que deve ser em destaque, cujo consentimento precisa ocorrer por pelo menos um dos pais da criança ou adolescente.

4.3 DADO ANONIMIZADO

O dado anonimizado é aquele que quando, de início constava como sendo relativo a uma pessoa, mas que em algum momento da etapa de tratamento foi desvinculado de determinada pessoa. Ou seja, é aquele dado que, originariamente, era relativo a uma pessoa, mas que passou por etapas que garantiram a desvinculação dele a essa pessoa.

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

[...] (BRASIL, 2018).

Por exemplo, quando são eliminadas partes de um número (dígitos de um telefone) e/ou são eliminados todos os nomes de uma relação, aquela relação, muito embora ainda possua informações, mas a retirada dos nomes da lista e não sendo possível o cruzamento dos dados restantes a ponto de identificar a pessoa, tem-se o dado anonimizado.

Veja-se que, quando um dado passa a ser anonimizado, logo, a LGPD não mais se aplicará a ele, pois a Lei somente se ocupa dos pessoais que são passíveis de causar danos ao titular, o que não é o caso dados anonimizados.

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido (BRASIL, 2018).

Assim, quando utilizando-se de uma técnica a empresa remove completamente as informações “identificáveis” da sua base de dados, a ponto de tornar-se aquele cadastro não identificável, tem-se o dado anonimizado.

■

CAPÍTULO V QUEM DEVE ADEQUAR-SE?

■

Desde a criação da Lei, em 2018, tornou-se “quase” natural o questionamento sobre: Quem, afinal, deve se adequar?

E muitas empresas - ou mesmo muitos dirigentes de empresas- se perguntaram isso e muitos, por desconhecimento dos rigores da Lei; alguns, por incredulidade na sua eficácia e; ainda há outros que simplesmente, esperam para verem se a Lei realmente vai ou não pegar. Em qualquer das situações, representa um risco muito alto para a empresa, pois a Lei é clara, também nesse aspecto.

Já em seu artigo 1º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2018).

Veja-se que da leitura do artigo supra, dúvida não há, quanto ao fato de que todas as empresas, quer públicas ou privadas e ainda, qualquer pessoa natural que se utiliza de dados pessoais para ganhos financeiros, são obrigados a se adequarem às exigências trazidas pela lei.

É muito importante deixar claro que a Lei se aplica até mesmo a empresas com

sede no exterior, sendo que nesse caso, deve-se considerar que a operação de tratamento de dados seja realizada em território nacional.

No que se refere a Lei, ao tratamento de dados pessoais por “pessoa natural”, trata-se de uma referência às pessoas físicas, aqui entendidas como profissionais autônomos, que tratam dados pessoais com a finalidade de aferir lucro. Tem-se como exemplo de profissionais autônomos: Médicos, Contadores, Advogados, Educadores Físicos, Nutricionistas, dentre outros tantos profissionais que coletam dados para suas atividades, com ganhos financeiros. São aqueles profissionais que, embora desenvolvam uma atividade remunerada, o fazem em nome da própria pessoa física e não de uma pessoa jurídica, com um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).

O fato é que, como já tratado anteriormente, a Lei foi criada em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, portanto, as empresas tiveram 02 (dois) anos para se adequar.

Como também já fora dito, as sanções entraram em vigor em 01 de agosto de 2021 e as fiscalizações previstas para terem início a partir de janeiro de 2022, segundo a Resolução 001/21 da ANPD, datada de 28 de outubro de 2021 e publicada no Diário Oficial de União, em 29 de outubro de 2021. Nela, consta a regulamentação de como funciona o processo administrativo de fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Chama-se a atenção para o Art. 70º da referida resolução, que dispõe que:

Art. 70. O primeiro ciclo de monitoramento terá início a partir de janeiro de 2022.

Portanto, quando se pergunta, quanto tempo as empresas terão para se adequar, responde-se de forma rápida e prática: não há mais tempo a perder, sob pena das sanções recaírem sobre aquelas empresas que ainda não se adequaram.

Isso porque o processo de adequação e implementação não é tão simples e mostra-se, pelo rigor, relativamente demorado. Por menor que seja a empresa não é possível realizar a adequação completa em menos de 02 (dois) ou 03 (três) meses, podendo chegar a 12 (doze) meses, a depender do porte da empresa e de como são seus processos internos e mesmo ao uso e alimentação de sistemas utilizados.

Outro ponto importante a se considerar é que, muito embora todas as empresas, como dito, querem públicas ou privadas, devem se adequar, primordialmente a adequação vem sendo realizada por empresas de grande porte, e sendo ignorada em sua maioria, pelas micro e pequenas empresas.

Esse fato se dá, em grande parte, pela dificuldade que as micro e pequenas empresas têm, de disponibilizar pessoal para apoiar uma equipe de adequação, além da dificuldade na disponibilização de um Encarregado de Proteção de Dados (DPO). Quer pelo custo na formação, manutenção, quer pela própria ideia equivocada em sua maioria de que não está em risco ou mesmo que custa caro implementar a Lei.

Para se ter uma ideia mais clara, sobre esses números da adequação serem prioridade para as grandes empresas, a RD Station realizou uma pesquisa em que aponta sobre a dificuldade de adequação pelas pequenas empresas em detrimento do interesse das grandes empresas no processo de adequação.

[...] Cerca de 18% das grandes organizações afirmaram ter formado um grupo de trabalho com colaboradores de diferentes áreas, sendo que aproximadamente

15% das microempresas ainda não possuem nem mesmo colaboradores dedicados à tarefa [...]⁶.

De acordo com a pesquisa, o motivo das grandes empresas estarem se adequando mais rapidamente é exatamente o que explicamos. Ou seja, pela maior facilidade que elas têm de contratar um Encarregado de Proteção de Dados, e mesmo para disponibilizar uma equipe de apoio a equipe de adequação.

Aqui chamamos a atenção ainda, para um outro indicador na dificuldade ou demora na adequação pelas empresas, aquele mencionado no início deste capítulo, que se trata do fato de que muitas empresas ou mesmo muitos dirigentes de empresas, quer por desconhecimento dos rigores da Lei, ou ainda alguns, por incredulidade na eficácia da Lei e outros, que simplesmente esperam para verem se a Lei realmente vai ou não pegar.

A verdade é que, muito se questionou no início, se a Lei vai ou não pegar, devido as alterações na data de entrada em vigor, que, inicialmente, tinha como previsto o prazo de 1 (um) ano, depois estendeu-se para 1,5 (um ano e meio) e terminou que o prazo foi ampliado para 2 (dois) anos, para que as empresas se adequassem, ou seja, de 14 de agosto de 2018 a 18 de setembro de 2020.

A demora deveu-se, inicialmente, ao fato de que após diversas idas e vindas entre a Câmara Federal dos Deputados e o Senado Federal, após diversos e sucessivos adiamentos, além dos impactos causados pela pandemia, que terminaram por impactar e afetar diretamente na adequação das empresas às regras que eram impostas para o tratamento de dados pessoais nas empresas, oriundos das exigências da LGPD.

Claro que, não sem antes, ter sido objeto de diversos adiamentos, como aquele previsto na Medida Provisória - MP 959/20, que tratou das medidas para o

auxílio emergencial e prorrogação da entrada em vigor da LGPD.

Em síntese, a LGPD, cuja origem se deu através do Projeto de Lei Complementar – PLC 053/2018, após as mencionadas idas e vindas entre a Câmara e o Senado, foi aprovado em julho de 2018, por unanimidade, considerando o regime de urgência pelo Plenário do Senado, e que foi sancionado pelo então presidente da República, Michel Temer, em agosto de 2018, tornando-se assim, a Lei nº 13.709/18.

Além do fato de que, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), cuja criação era prevista em decreto e na LGPD, mas que somente foi criada pela Lei nº 13.853, de julho de 2019, trazendo consigo, alterações na LGPD, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispôs sobre a proteção de dados pessoais e criou a ANPD.

E vejam que, após a criação da ANPD e com o início das sanções, cuja possibilidade se deu a partir em 01 de agosto de 2021, sendo que, as fiscalizações somente foram previstas para terem início a partir de janeiro de 2022.

É bem verdade que todas as idas e vindas e a demora na entrada em vigor da Lei, não estão sozinhas como aspecto causador da “incredulidade” por parte dos empresários, se essa Lei vai ou não pegar.

Tem-se ainda um fato que sempre trazemos ao debate que é a relação entre a resistência ocorrida por parte dos empresários nos idos dos anos 90 (noventa), quando da entrada em vigor da Lei nº 8.078/90, a saber, Código de Defesa do Consumidor (CDC), que sofreu a mesma resistência por parte das empresas e hoje, decorridos mais de 30 (trinta) anos, todas as empresas estão adaptadas.

Para se ter uma ideia, não é incomum, ao entrar em uma loja, empresa ou qualquer estabelecimento comercial ou de prestação de serviços estar disposto de forma visível, logo na entrada ou no balcão de atendimento, um exemplar do CDC, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 12.291/10, que tornou obrigatória a manutenção de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de multa, o descumprimento de tal regra, nos termos dos artigos 1º e 2º da referida Lei, vejamos:

Art. 1º São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição:

I - multa no montante de até R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);

[...] (BRASIL, 2010).

Outro forte exemplo da efetividade do CDC na realidade das empresas são o temor pelas ações judiciais, em que os casos de condenações pelo judiciário, em favor dos consumidores, que redundam em pagamentos de indenizações por danos morais, que se tornaram regra para os casos em que empresas e prestadores de serviços descumprem o quanto determinado pela Lei.

Dessa maneira, arrisco dizer, e muitos especialistas também, que essa Lei vai pegar sim.

Por fim, e claro, será objeto de capítulo próprio, tem ainda a questão de que o objeto da Lei que é a proteção de dados pessoais, ter se tornado um direito fundamental.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já havia reconhecido e, o Senado Federal aprovou em 20 de outubro de 2021 a PEC 17/19 (Proposta Emenda à CF/88) o Direito Fundamental a Proteção de Dados, tornando cláusula pétrea⁷, que significa de forma simplista, duro como pedra – difícil de se alterar.

Assim, desde a entrada em vigor da possibilidade de aplicação das sanções pela ANPD, em 01 de agosto de 2021, cujas penalidades podem ser aplicadas e que vão desde simples advertências, multas e suspensão do direito de tratar dados.

Além, é claro, da possibilidade de ações judiciais com pedidos de indenizações que já são possíveis desde o dia 18 de setembro de 2020. Como exemplo, tem-se um caso que se tornou notório, que é o caso da Construtora Cyrela⁸ – em setembro/2020. Portanto, no mesmo mês da entrada em vigor da Lei, muito embora, tempos depois, a decisão tenha sido revertida, mas o caso ganhou notoriedade nacional e o impacto à imagem da empresa, não pode ser revertido, dada a ampla divulgação como primeiro caso de condenação pela aplicação da lei

Vale dizer, que já existem mais de 600 (seiscentas) decisões judiciais com base na LGPD e multas aplicadas, por exemplo: Google (dez milhões) e do Facebook (sete milhões), além de outro exemplo emblemático, que é o de uma rede de farmácias – condenada em quase R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por descumprimento da Lei, dentre outros casos.

Portanto, lhes asseguro que essa lei vai pegar sim, pois ela é muito mais rigorosa que o próprio CDC, a começar pelas sanções que são, inegavelmente, muito mais rigorosas na LGPD, visto que se iniciam com simples advertências, passando por multas que vão de 2% (dois por cento) do faturamento bruto da empresa, até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração, a depender do porte da empresa. Devendo ser ainda, considerado, que em caso de reincidência o valor poderá ser majorado. Muito embora, particularmente, entenda que a maior penalidade está diretamente ligada ao fato de que, a suspensão do direito de tratar dados, é uma penalidade mais gravosa, pois impede que a empresa trate dados até que esteja solucionada a irregularidade da adequação e que pela Lei pode ser de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

[...] (BRASIL, 2018).

Veja-se como exemplo, a impossibilidade que a empresa terá de emitir boletos para cobrança de seus serviços, pelo prazo acima, até que seja regularizada a situação da adequação.

Por fim, eu diria - mesmo sem conhecer a realidade financeira dessas empresas -

que muitas delas teriam sérios problemas para manter suas atividades. Pois chegariam ao ponto de decretarem falência ou encerrarem suas atividades, pela impossibilidade de emitir cobrança (boletos e faturas) pelos seus serviços, somada a possibilidade de imposição de sanções/multas pela ANPD.

Conclui-se, dessa forma, que as empresas precisam entender a coleta e o uso de dados pessoais de agora em diante, como um bem, um valor a ser agregado nas organizações.

Deve-se, portanto, aplicar corretamente a Política de Privacidade, implementar as mudanças contratuais, processuais e técnicas, que passam a ser imprescindíveis.

As multas são penosas caso não haja a devida proteção aos dados pessoais e a ANPD deverá observar os mecanismos e procedimentos internos adotados preventivamente pela empresa, e a implementação de boas práticas de governança.

Isso, certamente, será um diferencial de mercado – seletividade dos clientes e empresas operadoras e que fará com que as empresas se perguntem: se custa caro fazer a implementação e concluirão que, definitivamente NÃO, não custa caro. Muito mais caro poderá ser o dano à imagem da empresa e a rejeição do mercado (consumidores e fornecedores – pela não adequação).

6 Fonte: <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/empresas-nao-conseguem-se-adaptar-a-lei-de-protecao-de-dados-diz-pesquisa/>>. Acesso em 12/12/21 às 06:28.

7 Cláusulas pétreas - não podem ser alteradas nem por proposta de emenda à Constituição (PEC), emenda que pode ser apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados federais ou dos senadores ou por mais da metade das assembleias legislativas. Uma PEC, porém, tem o poder de modificar outras partes da Carta. Para aprovar essa emenda, o texto tem de ser discutido e votado em dois turnos em cada Casa do Congresso. Em cada votação, é preciso de três quintos dos votos para aprovar a PEC, o equivalente a 308 deputados e 49 senadores.– Fonte: <<http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe-planalto/noticias/2018/10/clausulas-petreas-as-regras-da-constituicao-que-sao-intocaveis>>. Acesso em 12/12/21 às 09h:10min.

8 Condenação LGPD – Construtora Cyrela – Fonte: <<https://canaltech.com.br/juridico/cyrela-e-a-1a-empresa-condenada-por-descumprir-a-lgpd-e-deve-pagar-r-10-mil-172465/>>. Acesso em 12/12/21 às 09h:30min.

■

CAPÍTULO VI QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS?

■

A razão de ser, enquanto objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é, segundo a disciplina do artigo primeiro, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural [...] (BRASIL, 2018).

Nesse contexto, dentre os direitos dos titulares de dados, um dos pontos de maior convergência entre a doutrina e os especialistas da área, diz respeito ao direito basilar trazido pelo Princípio da Autodeterminação Informativa, que desponta como sendo o principal dos direitos dos titulares de dados. O que significa em síntese, aquele poder que o cidadão (titular dos dados) tem sobre seus próprios dados pessoais e que, significa dizer, que toda vez que a pessoa, enquanto titular dos dados, precisar fazer escolhas, ele poderá decidir sobre praticamente tudo que será feito com seus dados, quando coletados, tratados ou armazenados por uma organização.

Novamente, importa dizer que, equivocadamente, pensam muitas empresas e muitos de seus dirigentes, que os são de propriedade das empresas, e que estas empresas detêm direitos sobre eles, quando na verdade, não são e não possuem as empresas, esses direitos sobre os dados pessoais dos titulares.

Explica-se: os dados são e continuam sendo, de propriedade dos titulares dos dados, e o que as empresas têm é um consentimento para tratá-los e quando não possuem esse consentimento e o tratamento não está fundamentado em uma das bases legais, o tratamento é considerado ilegal, nos termos da Lei.

Nesse sentido, claro está, que não se trata de uma propriedade das empresas, e esses dados, essas informações, com base no princípio da autodeterminação informativa, que dá as pessoas naturais o controle sobre o uso de seus dados pessoais.

A autodeterminação informativa, enquanto direito do titular de dados, encontra amparo, na LGPD, em seu Art. 2º, no inciso II, a saber:

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

[...]

II - a autodeterminação informativa;

[...] (BRASIL, 2018).

Muito embora o conceito de autodeterminação informativa não fique explicitado, mesmo na legislação brasileira como um todo, mas há muito se debruça sobre ele, e desde seu surgimento na Alemanha nos idos dos anos 80, que o tema tem se desenvolvido tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência.

A ideia aqui é que, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, aliado ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade, ambos garantidos constitucionalmente, que a Suprema Corte Alemã⁹, diante da grande quantidade de dados e informações que eram coletadas sem critérios, poderiam de algum modo, ameaçar a autonomia das pessoas. Então, entendeu-se que o tratamento de dados deveria ocorrer somente a partir de uma justificativa legal com definição de uma finalidade.

A partir dessa ideia, no Brasil tem-se debatido exaustivamente a questão e, a prova disso, são as várias Ações Diretas de Inconstitucionalidades, apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.

O fato é que, o direito a autodeterminação informativa foi reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, inclusive, como direito fundamental.

O entendimento do Supremo é de que, a proteção de dados, pessoais e a autodeterminação informativa, são direitos fundamentais (vale dizer que trataremos desse tema de forma mais detalhada em capítulo próprio), isso porque as origens da autodeterminação informativa se dão, no direito à garantia da inviolabilidade da intimidade e da vida privada.

Mas, sobre os demais direitos dos titulares de dados, a LGPD tratou de disciplinar quem é o titular:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

[...] (BRASIL, 2018).

Veja-se que o titular dos dados é, em resumo: você, eu, toda e qualquer pessoa física, que disponibiliza os dados para tratamento, nas mais diversas necessidades perante as empresas.

A Lei então tratou ainda de disciplinar - em mais de um artigo - sobre quais são os direitos dos titulares de dados.

No Art. 9º está disposto que:

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso:

I - finalidade específica do tratamento;

II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

III - identificação do controlador;

IV - informações de contato do controlador;

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e

VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei (BRASIL, 2018).

A Lei, preocupada em proteger os direitos dos titulares de dados, trouxe em seu bojo, um capítulo próprio para tratar dos direitos dos titulares de dados e assim, em seu Art. 17 consta:

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei (BRASIL, 2018).

No Art. 18 da Lei consta ainda que:

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:

I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou

II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção,

a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor (BRASIL, 2018).

Trocando em miúdos, tem-se que o titular de dados, possui como direitos, além daquele estabelecido pelo princípio da autodeterminação informativa, o direito a:

1) Confirmação da existência de tratamento de dados pela empresa;

2) Ao acesso aos dados, porventura existentes, na base de dados da empresa;

3) A correção pela empresa, de seus quando incompletos, inexatos ou desatualizados;

4) A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados quando julgar que estes são desnecessários, excessivos ou quando estiverem sendo tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;

5) Portabilidade dos dados a qualquer outro fornecedor de produtos ou serviços, respeitando-se, os direitos da empresa quanto à segredos industriais e comerciais;

6) A eliminação de seus dados pessoais, quando estes estiverem sendo tratados sem o seu consentimento, exceto naqueles casos em que o art. 16 da LGPD autoriza;

7) A Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

8) Ainda, sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

9) E o direito à revogação do consentimento;

10) O direito que o titular dos dados pessoais tem de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional;

11) O direito de opor-se ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento da LGPD;

12) Há ainda o direito que o titular dos dados tem de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua

personalidade.

Assim, estes são os direitos dos titulares de dados que visam, sobremaneira, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme preceitua o artigo primeiro da Lei.

9 Suprema Corte ou Tribunal Supremo - É o maior órgão judiciário de um país. Onde são decididas em geral, sobre o cumprimento da Constituição daquele país. Normalmente é considerada a última instância judicial do país. No Brasil chama-se STF - Supremo Tribunal Federal.

■

CAPÍTULO VII POR QUE A PROTEÇÃO DE DADOS É UM DIREITO FUNDAMENTAL?

■

A proteção de dados como direito, importa - e muito -, quando pensamos ou tratamos da proteção de dados como direito fundamental. Mas, antes de avançarmos sobre a questão do tema propriamente dito, entendemos ser interessante abordarmos sobre a importância desse direito enquanto fundamental e, claro, entender a importância dos dados como um todo.

O termo direito dispensa apresentações, visto que muito mais comum entre nossos costumes, trata-se de um comportamento predeterminado e que, torna-se uma norma, uma regra e que, se aplica ao nosso dia a dia, como uma norma a ser seguida.

E, quanto ao termo fundamental, partindo-se da etimologia da palavra, ou seja, partindo da evolução do termo fundamental, tem-se que é, aquilo que tem fundamento, aquilo que exerce grande importância, daí, o porquê fundamental.

Sobre os dados, são informações entregues ou registradas. Aquelas informações que uma vez entregues possibilitam seu uso para os mais distintos fins.

Superada essa conceituação superficial, podemos citar que desde o evento de uma publicação na revista *The Economist*¹⁰ que o termo passou a ser muito explorado e, fala-se que:

“Os dados são o novo petróleo.”

Originalmente, o termo foi cunhado por um matemático inglês, chamado Clive Humby¹¹, cujo termo original foi:

“Data is the new oil”.

O fato que nos importa aqui é tratar dos dados sob o prisma do avanço tecnológico, da transformação digital e do impacto que o uso das informações, dos dados passou a ter, no mundo dos negócios.

Não se pode deixar de considerar, sobre o Big Data, que em resumo bem simplista, quer dizer a reunião de dados ou um conjunto de dados que é cada vez maior e mais expressivo e por que não dizer, cada vez mais complexo, inclusive, do ponto de vista das métricas dos dados, que se tornam também, cada vez mais volumosas, tornando cada vez mais difícil de operar e de gerenciar, considerando o volume de dados, até por sua grandeza de expressão numérica.

Há muito pouco tempo falava-se em byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e, atualmente, fala-se em grandezas de números como terabytes que é o equivalente a 1.024 gigabytes.

Mas deixando de lado as métricas, para ocupar-se dos conceitos que aqui importam mais, temos que:

Os dados [são] o petróleo da atualidade, tamanho o seu valor [econômico]¹².

Para se ter uma ideia, muito recentemente, a Revista Abril S.A., que está em recuperação judicial, foi vendida por um valor considerado simbólico, em razão das dívidas acumuladas junto a bancos, para uma holding, cujo financiamento da compra se deu por via do Banco de Investimentos BTG Pactual, que passou a ser o maior credor isolado das dívidas, que antes eram partilhadas entre outros bancos como Bradesco, Itaú e Santander¹³.

Discute-se no mercado que o objetivo da compra - o interesse por uma empresa em recuperação judicial com tamanha dívida – passa, principalmente, pela grandeza do banco de dados de clientes da editora Abril, que possui dados de milhares de assinantes. Esses dados são considerados muito valiosos para os interesses em sua utilização para desenvolver a alavancagem e modernização da empresa através do fornecimento de conteúdo por meio de plataformas, bem como, por meio da exploração do fluxo de visitantes digitais, princípio já explorado por outras empresas. Afirma o Empresário Fábio Carvalho, o comprador:

A gente quer manter e partir para melhor, com a adoção de novas plataformas para oferecer conteúdo¹⁴.

Sinaliza ainda que:

Onde existe uma demanda grande, não só do BTG, é por mais fluxo de visitantes digitais focados em investimento. Esse é o princípio por trás de empresas como a Infomoney.

A partir de exemplos como esse, dessa importância conferida aos dados, não poderia ser diferente. Fator que justifica a preocupação com a proteção dos

dados, tal qual, o que se mostra pela criação da LGPD e mais, pela necessidade de se pensar na proteção dos dados, como um direito fundamental, visto que a valorização dos dados e a continuidade do uso dos dados de forma indiscriminada, sem controle e sem proteção, gerará cada vez mais insegurança jurídica.

Daí, a considerar pela necessidade da proteção de dados pessoais, em ser um direito fundamental, importa e muito e é sobre isso, que trataremos de agora em diante.

Superada essa fase, e respondendo objetivamente sobre o questionamento que aqui importa: A proteção de dados é um direito fundamental?

O STF já havia reconhecido o direito a proteção de dados como um direito fundamental e o Senado Federal, aprovou em 20/10/21, a PEC 17/19 (Proposta Emenda à CF/88) o direito a proteção de dados, como um direito fundamental, tornando cláusula pétrea, que significa, como já dito “duro como pedra”, “difícil de se alterar”.

Muito embora não seja uma tarefa simples, pois estamos muito longe de haver um consenso unânime sobre a conceituação do tema, DIREITOS HUMANOS e DIREITOS FUNDAMENTAIS, mas apenas para que se entenda melhor, sobre a importância da proteção de dados como direito fundamental, entende-se que é importante entender, ainda que de forma superficial, o que é considerado direito humano, para que não paire dúvidas sobre a diferença entre um e outro.

No entendimento do Prof. Doutor Ingo Wolfgang Sarlet sobre essas duas categorias, tem-se que:

DIREITOS HUMANOS: são, em síntese, não em sentido jurídico, aqueles direitos que derivam da condição do ser “humano”, por exemplo, quando se estuda na Filosofia e, se necessário for, entender do ponto de vista jurídico, são aqueles direitos humanos que estão assegurados juridicamente, por meio dos tratados internacionais, portanto, positivados (escritos na lei);

DIREITOS FUNDAMENTAIS: são aqueles direitos que, relativos à pessoa humana, por sua natureza, são reconhecidos por meio das constituições de cada país.

Por esse motivo, que se entende que os direitos humanos não são, necessariamente, direitos fundamentais.

Assim, a proteção de dados é sim, um direito fundamental. De início, importante dizer, que de certo, já havia a necessidade de um olhar mais atento para o tema, pois já havia diversos precedentes sobre o tema. Os tribunais brasileiros já caminhavam nesse sentido, até porque tinha-se o entendimento de que a proteção de dados carecia de maior amparo, pois o compartilhamento de dados entre empresas e órgãos, tanto no âmbito das instituições públicas, quanto das privadas, deparavam-se com as chamadas agressões ao princípio da finalidade e em muitos casos, ferindo o princípio da privacidade.

Foram vários os casos que ascenderam ao Supremo Tribunal Federal para tratar do tema, multiplicando-se em diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI's), fazendo com que o STF, invariavelmente, decidisse nesse sentido, como dito anteriormente.

Um segundo ponto a que se chama a atenção, é aquele que poderemos tratar como sendo, o reconhecimento desse direito, pela relevância dele à sociedade como um todo, ou seja, sua importância se dá, principalmente, porque enquanto

direito, tornou-se relevante socialmente e não apenas mais do ponto de vista individual.

10 The Economist - é uma publicação inglesa de notícias e assuntos internacionais de propriedade da The Economist Newspaper Ltd. e editada em sua sede na cidade de Londres, no Reino Unido. Está em publicação contínua desde a sua fundação por James Wilson, em setembro de 1843. Fonte: <<https://www.economist.com/>> - Acesso em 17/12/21 às 05h:52min.

11 Clive Humby - Traduzido do inglês-Clive Robert Humby OBE é um matemático e empresário britânico no campo da ciência de dados e estratégias de negócios centradas no cliente. Desde 2014, ele é cientista-chefe de dados da empresa Star Insight - Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=clive+humby&sxsrf=AOaemvKCNBsqdVVwh34IHbN-NHws_lZC7w%3A1639731322338&ei=elC8YcT_E4LR1sQPzP6ZoAU&gs_ssp=wiz>. Acesso em 17/12/21 às 05h:59min.

12 Prof. Doutor Ingo Wolfgang Sarlet, Mapa da Aula.

13 Fonte: <<https://theintercept.com/2018/12/21/bancos-agora-mandam-na-imprensa/>>. Acesso em 17/12/21 às 06h:24min.

14 Fonte: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/empresario-fabio-carvalho-acerta-compra-do-grupo-abril.shtml>>. Acesso em 17/12/21 às 06h:27min.

CAPÍTULO VIII QUAIS SÃO OS LIMITES DO CONSENTIMENTO?

De início, é importante dizer, que o consentimento é um dos temas que muitos especialistas consideram dos mais importantes e por que não dizer, que se apresenta como sendo um dos maiores desafios, quando falamos em proteção de dados pessoais. O consentimento pode ser considerado um dos pilares dentro do tema da proteção dos dados pessoais, objeto da LGPD.

O consentimento, em síntese, pode ser considerado um pré-requisito para que os dados pessoais de uma pessoa - pela Lei, chamado de titular dos dados - possam ser coletados e utilizados de forma legal pelas empresas. Chamadas de controlador, pois detêm, em tese, o poder de decidir o que pode ser feito com os dados. É considerado um dos principais mecanismos que possibilita a efetivação do direito de proteção à privacidade dos dados pessoais.

A LGPD, a saber, a Lei nº. 13.709/18 estabeleceu uma espécie de “conceituação” do que é para a ela o consentimento. Essa ideia é trazida em seu Art. 5º, inciso XII:

[...] manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada (BRASIL, 2018).

Assim, a Lei estabelece que, para que haja o tratamento de dados pessoais por parte de uma empresa é necessário antes o consentimento do titular dos dados.

De forma clara, no inciso I, do artigo 7º da LGPD, está posto que o tratamento de dados pessoais, somente poderá ser realizado (e tratou de um rol taxativo) descrevendo, as hipóteses em que os dados poderão ser tratados e, dentre estas hipóteses, tem-se o consentimento.

Então, veja-se que dentre algumas alternativas legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, a LGPD estabeleceu que como política e procedimento interno, que a empresa poderá identificar uma das bases legais que lhe permita a coleta e o tratamento de dados pessoais. E isso deve ser registrado por meio de um documento específico e esse documento deve estar de acordo com o regulamento.

Não nos ocuparemos em explicar detalhadamente, as bases legais outras, pois em capítulo próprio, já tratamos dessas Bases Legais, mas apenas à título de conhecimento, são 10 (dez) as bases legais e são elas:

- 1) O Consentimento;
- 2) O cumprimento de obrigação legal;
- 3) O tratamento de dados pela Administração Pública;
- 4) A realização de estudos em órgãos de pesquisa;
- 5) A execução de contrato;

- 6) O exercício regular de direitos;
- 7) A proteção da vida ou integridade física;
- 8) A tutela da saúde;
- 9) O legítimo interesse;
- 10) A proteção do crédito.

Veja-se que a LGPD traz um rol de 10 (dez) bases legais para o tratamento de dados pessoais e o consentimento é apenas uma delas, portanto, importa dizer que existem outras 09 (nove) bases legais que tornam possível o tratamento de dados sem o consentimento do titular de dados.

Cumprindo com o objetivo do tema a que propomos tratar, destacamos aqui a base legal do consentimento. Entendemos que para além do conceito e informações sobre a questão das bases legais em si, é extremamente pertinente falarmos sobre os limites desse consentimento, considerando especialmente, que ele é, certamente, a base legal mais utilizada pelas empresas e, não diferente disso, a base legal mais discutida e conhecida entre os titulares de dados.

Considera-se que o conhecimento seja, dentre as bases legais, aquele que apresenta a maior facilidade para implementação, tendo em vista que, uma vez cumpridas as formalidades da lei, quanto às finalidades específicas para o uso de dados pessoais, em tese bastariam, porque pela lei, as chamadas autorizações

genéricas, devem ser consideradas nulas de pleno direito.

Vale pensar que, o principal requisito é que o consentimento, precisa ser apresentado ao titular de dados, de forma destacada das demais cláusulas contratuais, deve ser sempre apresentado de forma clara ao titular e, mais do que isso, deve expressar de forma inequívoca a manifestação da vontade do titular de dados quanto ao seu consentimento para que a empresa realize o tratamento dos dados.

Também é importante constar que não pode haver vício no consentimento do titular dos dados, pois do contrário, será nulo o consentimento, além é claro. O fato de que este consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo pelo titular dos dados, devendo a empresa (controlador) responder ao titular dos dados, imediatamente ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a revogação do consentimento e nesse caso, deverá utilizar-se de uma nova base de dados que justifique a finalidade, para o caso de necessidade de manter os dados em sua política de tratamento de dados.

Importa-se dizer que, também como exemplo do que está disposto no Inciso V, do Art. 7º da LGPD que é dispensado o consentimento nas hipóteses de execução de contratos ou de procedimentos preliminares a eles relacionados para alcançar o fim do objeto principal.

Veja-se que a ideia aqui é que os dados coletados sem consentimento só poderão ser utilizados para os fins específicos, conforme fora delimitado acima e que, muito embora de forma ampla, a Lei apresenta uma espécie de aval para o tratamento de dados, sem consentimento do titular de dados.

Entenda-se que caso a empresa necessite realizar o tratamento de dados com finalidade diversa do que foi especificado inicialmente, deverá pedir novo

consentimento ao titular dos dados pessoais. Nesse caso, especificamente, para a nova finalidade, inclusive e especialmente, se nesse caso houver a necessidade de repassar esses dados para empresas outras, ou parceiros comerciais.

Importa ainda dizer, apenas para se ter uma ideia, que até então, trabalhava-se com a possibilidade três vertentes de consentimento, a saber:

a) O consentimento presumido: aquele consentimento que teoricamente estaria sendo dado pelo titular e que é compreendido quando da ideia da existência de um consentimento explícito. Quando da aceitação de uso de dados pessoais em diversos contratos com empresas que ofertam produtos e serviços, por exemplo;

b) O consentimento informado: aquele que deverá apresentar ao titular, a condição que deverá ser aceita de forma escrita. A linguagem complexa dos termos de uso, em conjunto com impossibilidade de acesso aos serviços, nos casos em que esses termos fossem recusados, levaram ao questionamento da ideia de consentimento presumido como verdadeiramente voluntário – daí a necessidade do consentimento informado;

c) O consentimento ativo: aquele consentimento que traz de volta o poder de decisão às mãos do titular, considerando o avanço do modelo ampliado pelo princípio da autodeterminação informacional/informativa, onde o titular, de forma ativa, consente com o tratamento de dados e que poderá fazer uso de sua revogação a qualquer tempo, se assim entender melhor.

Nesse sentido, importante esclarecer que o fornecimento do consentimento pelo titular dos dados, cujo entendimento é o de que esse consentimento, quando escrito, deve ser destacado das demais cláusulas, sempre de forma clara, expressando a manifestação inequívoca da vontade do titular, não pode haver vício nesse consentimento, além de que, este poderá ser revogado a qualquer

tempo.

Dessa forma, não há dúvida de que para garantir que o consentimento para o uso dos dados que serão submetidos ao tratamento possa ser obtido de forma apropriada. Nesse caso, devemos pontuar a importância de que o consentimento dos pais para o caso de tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser ainda mais criterioso, dado o rigor com que a lei trata dos dados sensíveis, devendo assim, contar com um formulário próprio para esse pedido de consentimento.

Por outro norte, veja-se, que para nós, interessa mais, nesse momento, avaliar como dito anteriormente, quais são os limites do consentimento.

Já que a ideia aqui é tratar dos limites do uso do consentimento, não podemos deixar de contextualizar que, desde o Marco Civil da internet, a saber, a Lei nº. 12.695/14, que já havia uma preocupação com a necessidade de consentimento dos usuários, como sendo um direito destes quando no ambiente da internet.

A própria LGPD, tratou de definir de forma pontual, sobre o que a lei considera ser o consentimento e nesse aspecto, no inciso XII, do artigo 5º, ficou estabelecido que a definição do que considera ser o consentimento, aos olhos da LGPD:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

[...] (BRASIL, 2018).

A própria Lei deixa claro a ideia de que é uma manifestação livre, informada e inequívoca, onde o titular dos dados deve concordar com o tratamento dos seus dados pessoais e de igual modo, deixa claro a necessidade de o controlador apresentar uma finalidade específica.

Para além do conceito e da própria definição do que a Lei entende por consentimento, partindo-se dessa definição, cumpre-nos esclarecer que, muito embora o titular dos dados possua o “poder” de revogar a qualquer tempo esse consentimento, tratar da função e mesmo dos limites do consentimento é extremamente crucial. Para isso, consideramos importante demais, tratarmos do que pode ser a origem ou “daquilo” que concedeu, que permitiu, que esse direito de revogação fosse obtido pelo titular de dados. E nisso, temos que não se pode deixar de abordar, ainda que numa espécie de sobrevoo, sobre o Princípio da Autodeterminação Informativa ou Autodeterminação Informacional.

Qual é, afinal, a função do consentimento? Quais são os limites do consentimento?

É necessário entender que o uso dos nossos dados tem sido, ao longo dos tempos, atropelado pelas empresas, como se delas fossem nossos dados, quando na verdade não são, são “nossos” dados (dos titulares). No então, tal apropriação indevida se deu principalmente, pelo interesse de alimentar diariamente, os interesses econômicos dessas empresas, sem, contudo, respeitar os direitos à privacidade e o direito à proteção dos dados pessoais. Daí deriva, pelo menos em

primeiro olhar, a necessidade de se estabelecer os limites do consentimento que, para além da ideia de uma base legal, tem-se que a Lei Geral de Proteção de Proteção de Dados, iluminou sobre nós, a ideia do uso correto do consentimento do titular, para um patamar que desde então, passou a ganhar destaque como uma das ferramentas de efetividade para a proteção dos dados pessoais. Entende-se que essa condição, esse poder de revogação do consentimento, por parte do titular dos dados, enquadrado à condição de um limite, quando somados à sua função (consentir que os dados sejam utilizados apenas para a finalidade específica indicada pela empresa), isso então, nos direciona para o que aqui propomos como tarefa a ser estudada a partir de agora.

Primeiro, considera-se necessário pensar que aquele estado de vulnerabilidade em que sempre esteve o titular de dados, começa a ganhar destaque na contramão desse viés, pois a partir da possibilidade da aplicação do Princípio da Autodeterminação Informativa, assegurado o direito de consentimento e a possibilidade de revogação do consentimento e, estabelecidos os limites do uso desse consentimento, temos que, esse panorama da vulnerabilidade, muito em breve, estará revertido.

Sobre a função do consentimento: Como então, pode-se pensar na função do consentimento, diante do direito fundamental à proteção dos dados pessoais?

A velocidade com que os dados pessoais são coletados e tratados é, tão assustadoramente significativa - Big Data¹⁵, que a sociedade da informação nos trouxe a necessidade de estudar de forma aplicada sobre a função e os limites do consentimento, por exemplo.

Nesse sentido, importa agora entender que a função do consentimento é, ainda que de forma simplória, explicada como sendo: a maneira pela qual, por meio de requisição do controlador, de forma clara, concisa, inequívoca, por meio da qual, é demonstrada a manifestação da vontade do titular dos dados, de permitir que

seus dados sejam utilizados para atingir a finalidade a qual lhe é apresentada a solicitação.

Para além disso, necessário se faz, ato contínuo, estabelecermos sobre: Quais são, afinal, são os limites do consentimento? E nesse sentido, temos que pensar que desde o Código Civil, passando pelo Marco Civil da Internet, pelo Código de Defesa do Consumidor, que a figura do consentimento ganha contornos que nos leva à necessidade de entender, quais são os limites do conhecimento, em especial, a partir da entrada em vigor da LGPD.

Dessa maneira, partindo de uma ideia de proteção aos direitos do consumidor, que podemos buscar entender, que os limites do consentimento, relativos ao uso adequado dos dados pessoais. Nessa ideia trazida pela LGPD, tem como escopo principal, proporcionar ao titular de dados pessoais, proteção aos seus dados pessoais, a partir da imposição de penalidades ou sanções, que visam, sobretudo, estimular as empresas a cumprirem com os ditames da lei, no que se refere ao tratamento adequado dos dados. Visando, sobremaneira, fazer com que as empresas tenham como cultura, uma análise muito mais cuidadosa, durante todo o processo de tratamento dos dados dentro das empresas.

Veja-se que, desde a entrada dos dados por meio da coleta, passando pelo mapeamento desses dados, incluindo, é claro, a adoção de novos procedimentos com relação à privacidade dos dados, são necessários e urgentes. Considerando, por exemplo, todo esse novo momento em que o mundo passou a viver, analisando primordialmente, tudo que foi vivenciado a partir do uso da internet após a pandemia, o que de certa forma forçou ou acelerou o uso de novas tecnologias, muito embora muitas delas, já existentes, mas que interferiram na questão do desenvolvimento social e político e econômico, especialmente, quanto ao uso das redes sociais, que representam novas formas de vida e relacionamentos interpessoais.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), portanto, reafirmou direitos

que antes já existiam na sociedade como um todo, mas, sobretudo, no que diz respeito ao direito à privacidade e proteção de dados, que não por acaso, se tornou um direito fundamental.

Assim, questões como transparência na gestão de dados dentro das empresas, e a própria gestão sobre o armazenamento de informações e dados excessivos, deve, de agora em diante, trazer consigo - dentro dessa ideia de nova cultura nas empresas - uma nova mentalidade, dessa vez, com consequências muito positivas, no desenvolvimento social e econômico do país. O que significa, em resumo, maior vantagem competitiva entre as empresas e grandes organizações.

Em síntese, pensar de agora em diante, o tratamento dos dados pessoais, passa obrigatoriamente, por estabelecer e entender que esse tratamento, com base no consentimento. Especialmente, nos limites desse consentimento, o tratamento de dados, deve, ser sempre, limitado ao mínimo necessário para fazer cumprir com a realização da finalidade para a qual houve o consentimento.

O que representa de forma clara e inquestionável que, aos titulares de dados, passou a ser garantidos dentre destes limites do consentimento, condições como o direito a consulta rápida, facilitada e, também gratuita, sobre as formas (maneiras). Mesmo sobre o tempo de duração para a realização do tratamento dos seus dados, assim como, o direito ao acesso do titular dos dados, de forma integral aos dados que ele confiou à empresa.

15 Big Data: é uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações, a partir de conjuntos de dados muito grandes. O termo surgiu para definir o crescimento dos dados, junto com a sua não estruturação.

CAPÍTULO IX DIREITO DIGITAL

Definir o direito como um sistema de normas por meio do qual é possível regular as condutas humanas, ao se estabelecer o que são os direitos e o que são os deveres de cada cidadão, é, por demais, uma definição simplória, mas que se entende necessária, pois o desafio aqui é ainda maior. Visto que se trata de trabalhar, não apenas com a ideia de definição do direito em si, mas do Direito Digital que é, em síntese, uma espécie de evolução do próprio direito e que busca, com base na evolução da sociedade, até atingir a era digital, passando por todo o processo de transformação digital, que naturalmente, para existir, necessita antes, de existir a mencionada era digital.

Nessa toada, é possível pensar que no direito, como algo que nasceu desde os primórdios da civilização e que, portanto, não há como pensar esse direito, sem, contudo, pensar na evolução da sociedade.

Consequentemente, pensar na origem do direito, como a partir dos costumes e das imposições religiosas, que foram estabelecidas por meio de institutos como, por exemplo: o registro dos nascimentos, o casamento, a aquisição das propriedades, dentre outras formas de demonstração do que seria, esse direito sobre qual falamos.

Há quem diga que o direito nasceu quando surgiu a escrita, mas arriscamos dizer, que o direito nasce, mesmo antes da escrita, pois independente dela, já se praticava o direito como regulador da vida em sociedade, ainda que esse direito se manifestasse apenas de forma verbalizada.

A origem do Direito Digital: pensar no Direito Digital é pensar que de tempos em tempos, de geração em geração, os povos e sociedade evoluem. E como não poderia deixar de ser, o Direito Digital necessitou ocupar-se do que podemos chamar de necessidade de regulação das várias áreas que se ocupam de utilizar-se das mais diversas ferramentas tecnológicas, aquelas chamadas ferramentas digitais e todas as suas tendências.

Em um dado momento o uso de tecnologias, como computadores, notebooks, e em especial, smartphones, fez com que o uso da internet se popularizasse e com isso, inevitavelmente, surgiram sites, programas, aplicativos das mais variadas espécies e finalidades, que terminaram por popularizar as chamadas redes sociais e estas sim, impulsionaram de forma absurdamente potencial, os chamados conflitos na rede. Estes que, como não poderia deixar de ser, fizeram surgir, como ferramenta para dirimir os conflitos decorrentes do ambiente digital, o chamado Direito Digital, que não por acaso, atua no ambiente real, para tratar dos temas oriundos daquele ambiente digital.

O Direito Digital é considerado um ramo novo do direito, pois até muito pouco tempo atrás não se falava na necessidade dessa atuação para regular as relações do ambiente online.

Por muito tempo, se pensou no direito apenas no mundo real e este, como sendo muito diferente do mundo digital, até então, não pensado enquanto necessidade de regulação de conflitos. Ocorre que, a cada dia, os dois mundos passaram a se confundir, se assim nos permite dizer, e a interferência de um, terminou por afetar o outro.

Veja-se, por exemplo, que há pouco tempo quando falávamos em temas como calúnia, injúria e difamação eram temas existentes a princípio, apenas no mundo real, sem qualquer presença ou legislação para tratar do tema no âmbito do mundo digital. Veja-se que não eram abrangidos pelo Direito Digital, até porque não se falava da existência do deste direito até então. Atualmente, o Direito

Digital já se ocupa de igual modo, em tratar de questões que estão igualmente presentes, tanto no mundo real (não virtual) quanto no ambiente digital, sendo que, atualmente, ocorre da mesma maneira que ocorria, apenas no chamado mundo real.

Um exemplo interessante para elucidar esse fato é que nos idos de 2012 escrevíamos um trabalho sobre a ausência de legislação específica, para tratar dos crimes digitais no Brasil e, pouquíssimo tempo depois, a figura do Direito Digital começa a se mostrar, com uma vasta ambientação e com o surgimento de legislação própria para regular o tema.

A finalidade do direito: a finalidade do direito se resume em regular as relações humanas, a fim de que haja paz e prosperidade no seio social, impedindo a desordem ou o crime. Sem o direito estaria a sociedade em constante processo de contestação, onde a lei do mais forte imperava sempre, num verdadeiro caos¹⁶.

As leis e os conflitos no ambiente digital: a chegada do Direito Digital se deu de forma gradativa e bem interessante, a considerar que até 2012, invadir dispositivos informáticos no Brasil, não era crime, veja-se: Em 2012 – A Lei 12.737/12 - Lei Carolina Dieckman, que dispôs sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e que alterou o Decreto-Lei nº 2.848/40 a saber, o Código Penal e veja-se que em seu escopo esta Lei estipula pena para quem invadissem dispositivos informáticos alheios, causando violação indevida de mecanismos de segurança com finalidade de obter dados e informações sobre os proprietários/proprietárias desses dispositivos.

Muito embora tenha sido alvo de muitas críticas e questionamentos, mas foi um dos primeiros dispositivos legais que tratou de forma mais específica no Brasil, sobre a questão da proteção penal do direito à privacidade.

Em 2014 – a Lei nº 12.695/14 – O Marco Civil da Internet, que apresentou e estabeleceu os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Veja-se que, o objetivo principal desta lei era estabelecer direitos, deveres e garantias no meio digital.

Em 2018 – a Lei nº 13.979/18 – A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive, nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Importa dizer que, o Direito Digital, como sendo um ramo do direito, considerando o que foi estabelecido acima, tem como objetivo, proporcionar normas para o uso dos chamados ambientes digitais e, deve prover, antes, proteção para os dados e informações que circulam nos espaços informáticos, por meio do uso de aplicativos e equipamentos eletrônicos.

O avanço desse segmento do direito, o chamado Direito Digital é tão rápido, dinâmico e significativo, que atualmente, um dos ramos de maior ebulição é o que está relacionado às criptomoedas e ao metaverso. Veja-se que, há pouquíssimo tempo, discutia-se, sobre o Direito Digital no âmbito da internet das coisas – IOT¹⁷, Big Data e, sobretudo, da Inteligência Artificial que, como sabemos é um caminho sem volta, pois a cada dia, maiores são os desafios impostos pelos algoritmos, uma vez que, para além da robotização, temos que o uso do Machine Learning¹⁸ – Aprendizado Máquina - Torna-se imperioso ser pensado, como ferramenta que apresenta um crescimento sem precedente, dentro da ideia daquilo que ocorre enquanto perspectiva do que é, o uso e o processamento dos dados, sobretudo, aqueles colhidos pelos dispositivos robóticos, decorrentes da inteligência artificial.

De certo que algumas áreas do direito prometem maior demanda, mas o fato é que o Direito Digital é disparado uma das áreas em que apresentam maior

tendência de crescimento, pois o objeto a ser tratado está diretamente ligado ao crescimento dos crimes que são praticados pela internet, mas não apenas no viés do direito criminal. Essa tendência se confirma também em outras áreas dentro do Direito Digital, com por exemplo, o Direito do Trabalho e suas implicações derivadas, por exemplo, do uso de plataformas de teletrabalho.

Também no campo do Direito Digital tributário, questões como tributação digital, oriunda de operações, eminentemente, provocadas pelo ambiente digital, tanto no que se refere a produtos quanto no que se refere a serviços.

É inegável que o mercado jurídico vem se atualizando e, claro, as chamadas experiências dos clientes, tendem a forçar o Direito Digital a regular essas mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos e do uso das novas tecnologias.

Já não basta compreender o direito puro e simplesmente, como ponto de partida, pois não há mais como compreender todos os reflexos das novas tecnologias na sociedade, sem, contudo, compreender o papel do Direito Digital. Em especial, voltado para todo o contexto do que ocorre no campo dos problemas jurídicos que estão ligados à essas relações, contatos e negócios que são realizados no ambiente da internet e que são exatamente de onde derivam as consequências que terminam por refletir no Direito Digital do Trabalho, Direito Digital Tributário, Direito Digital Criminal. Enfim, de todas as áreas ou subáreas do Direito Digital, que tem com como o chamado direito 4.0 que é o Direito Digital que se ocupa das novas tecnologias, seus usos e seus reflexos.

Assim, é possível afirmar que a transformação digital no Direito, anda a passos largos e já não é mais possível pensar, também no campo da educação, por exemplo, no que diz respeito ao ensino à distância, o chamado EAD, que não ter-se-á implicações.

No que diz respeito ao Direito Digital Civil, quando pensamos no campo dos contratos, das obrigações, das coisas e o próprio Direito Digital decorrente do direito em relação às responsabilidades civis decorrentes das práticas no ambiente da internet, berço do Direito Digital.

Não se pode deixar de pensar no Direito Digital quando o assunto é ética, pois um dos campos a serem muito explorados está relacionado à inteligência moral no campo da era digital.

E por fim, como não poderia deixar de ser, não há como não falar sobre os impactos da LGPD como braço principal do Direito Digital, pois a Lei estabeleceu princípios, direitos e obrigações que devem, obrigatoriamente, serem seguidas pelas empresas e que, guarda relação direta com a necessidade de adequação por parte das empresas quanto ao tratamento dos dados pessoais das pessoas naturais, mas que, sobremaneira, visam proteger a privacidade dos dados, inclusive, nos meios digitais.

Impulsionados pelo enorme crescimento do Direito Digital, diversas associações e institutos que buscam difundi-lo como ramo de atuação, permitindo assim, que diversas pessoas e profissionais possam ter acesso aos conhecimentos relativos a este.

Veja-se que o Direito Digital não apenas se refere aos operadores do direito, mas também guarda relação direta aos diversos profissionais da área de tecnologia. Dessa forma, no âmbito do Direito Digital, tem-se que o avanço tecnológico traz questões muito relevantes nesse campo do direito, que guardam relação direta com o que chamamos de exercício de cidadania, decorrentes do uso da internet, que estão totalmente ligados aos direitos sociais. Estes, a cada dia promovem a necessidade de maior proteção da privacidade e da proteção de dados pessoais e mesmo o Direito Digital como ferramenta para garantir os direitos dos cidadãos, que se utilizam das tecnologias, das inovações tecnológicas e que, como não poderia deixar de ser, devem sempre, estarem pautados na regulação pelo Direito

Digital, naquilo que está posto como sendo os princípios estabelecidos pelo Marco Civil da Internet e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Por outro norte, não há como afirmar que os ataques virtuais e os crimes cibernéticos serão freados no curto prazo, pois as mentes que os produzem são tão brilhantes quando as mentes que trabalham para evitar os ataques. De certo que a era digital e todo o processo de informatização das coisas e dos processos trouxeram consigo uma gama de grandes riscos que derivam do uso demasiado dessas tecnologias e os ataques virtuais, os ataques cibernéticos e todos os diversos meios ilegais de práticas utilizadas por hackers são, por qualquer ótica, objeto do Direito Digital, o que, por sua vez, termina por ser cada dia mais útil e necessário para normatizar e controlar tais práticas.

Não há dúvidas, portanto, que de agora em diante vai existir a necessidade da criação de normas e de procedimentos que visam, a proteção das pessoas que são cada dia mais atacadas. Cujo atos necessitam de punição que estão no rol de atos que prejudicam e que tem reflexos diretos no ambiente digitalmente controlado ou descontrolado.

Isso, portanto, torna-se um caminho que naturalmente deverá ser seguido e perseguido pelo Direito Digital, fazendo com que haja crescimento e/ou necessidade de criação e adequação de novas leis que visem regular e controlar o ambiente digital, que é o campo de atuação do Direito Digital. Por isso, sua importância é inquestionável relevância para os dias atuais.

16 Fonte: <<https://ricardofatore.jusbrasil.com.br/artigos/765422172/ramos-do-direito>>. Acesso em 17/06/22 às 18h:15min.

17 A Internet das Coisas (Internet of Things, ou IoT) é um conceito que dispõe que a maioria dos dispositivos que utilizamos diariamente está conectada entre si e pela Internet. Fonte: <https://www.i2ai.org/content/glossary/?gclid=CjwKCAjwiJqWBhBdEiwAtESPaDOJm_hdv1UH3BueknneoKEsUhDNij> Acesso em 07/07/22 às 08h:19min.

18 O aprendizado de máquina (em inglês, machine learning) é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Fonte: <[>.](https://www.google.com.br/search?q=O+que+%C3%A9+o+machine+learning%3F&sxsrf=ALiCzsZZhIvw0HqbPi_TIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYAUoECEEYAEoECEYYAVAAWABg4I4RaAJwAwiz>https://www.google.com.br/search?q=O+que+%C3%A9+o+machine+learning%3F&sxsrf=ALiCzsZZhIvw0HqbPi_TIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYATIKCAAQ5AIQsAMYAUoECEEYAEoECEYYAVAAWABg4I4RaAJwAwiz>)

CAPÍTULO X AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA

A título de conhecimento, desde a década de 70, mais especificamente em 1970, o tema se tornou alvo de estudo e de debate na Alemanha e, portanto, a Corte Alemã já discutia desde então, sobre o tema da Autodeterminação Informativa.

Veja-se que a Lei do Estado alemão de Hesse, de 1970, é considerada a primeira lei que trata da questão da proteção de dados e esse era seu objetivo principal: proteger os dados pessoais contra os já sinalizados abusos quando em tratamentos.

Mas o tema ganhou força em 1983, quando a Suprema Corte Alemã, proferiu uma decisão em sede de análise do que foi a chamada Lei do Censo. O caso, em resumo grotesco, fundou-se no fato de que, naquela ocasião, o governo da Alemanha, durante a realização de um censo, que tinha como objetivo levantar dados da população alemã. Cujo “problema” consistiu basicamente em dois pontos: primeiro, no fato de que os dados coletados no censo, poderiam ser compartilhados entre os demais órgãos públicos. Segundo, como se não bastasse isso, tinha-se o agravante de que, caso o cidadão se negasse a responder alguma das perguntas do censo, este cidadão poderia ser multado.

A atuação da Suprema Corte Alemã, foi decisiva naquilo que posteriormente ficou caracterizado como sendo o Princípio da Autodeterminação Informativa, que hoje é discutido como sendo uma importante ferramenta de garantia à proteção de dados dos titulares.

Sobre a decisão: trocando em miúdos, a corte decidiu que o direito fundamental, garante o poder do próprio indivíduo decidir, em princípio, sobre o uso e a exibição de seus dados pessoais.

E mais do que isso, entendeu-se que as restrições a esse direito (a autodeterminação) sobre a informação, somente devem ser permitidas, em casos que ficam comprovados, os interesses de uma coletividade. Entendeu a corte, que essas restrições necessitam de uma base legal constitucional, que deve atender ao mandamento da clareza normativa, próprio do Estado de Direito.

Nessa linha de entendimento, o legislador deve, além disso, observar, em sua regulamentação, o Princípio da Proporcionalidade, também deve tomar precauções organizacionais e processuais, que evitem o risco de uma violação aos direitos da personalidade.

No Brasil - o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que surgiu em 1990, por meio da Lei nº 8.078/90, ou seja, completou três décadas em 2020 e que em seu Art. 43º, o CDC já previa que as pessoas tivessem direito de acessar as informações existentes sobre si, nos cadastros das empresas.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes (BRASIL, 1990).

Em resumo, o fato é que o Princípio da Autodeterminação Informativa, consiste basicamente, no poder que nós, os titulares de dados temos em decidir nós mesmos sobre o que poderá ser feito com nossos dados.

Não é incomum recebermos em nossos e-mails, em nossos celulares, por meio das redes sociais e outros aplicativos, propagandas de diversos produtos e serviços que não solicitamos e: De onde vêm essas informações? São várias as “propostas” de produtos e serviços, que vão desde ofertas de comidas, seguros, itens de vestuários, higiene pessoal, medicamentos, enfim, uma gama dos mais diversos produtos e serviços e então, questionamos: Até que ponto, realmente, temos controle sobre nossos dados pessoais? Como é possível haver tanto conhecimento sobre nossos hábitos e rotinas?

Partindo de questionamentos como esses, entendemos que existe um histórico e até podemos dizer, que existe uma cultura já arraigada, de que nossos dados pessoais de fato, não estão sendo protegidos pelas empresas com as quais confiamos nossos dados e esses dados são compartilhados com outras empresas parceiras. O compartilhamento não era, até então, objeto de controle por nós, pois inadvertidamente, sempre “autorizamos” esse uso compartilhado e indiscriminado dos nossos dados. Tínhamos então como resultado a essa disseminação em massa dos dados pessoais dos usuários sem o consentimento, pelo menos nos moldes do que hoje é exigido pela LGPD, salvo para os casos em que as empresas já estão devidamente adequadas às exigências da Lei, no que diz respeito à implementação.

Surge a partir daí a necessidade de entender, até mesmo com base na ideia primeira do que dispõe o Princípio da Autodeterminação Informativa, que garante ao usuário, o direito de decidir o que pode e o que não pode ser feito com seus dados a partir do consentimento e, até mesmo da possibilidade de revogação desse consentimento, naqueles casos em que o titular dos dados entender necessário.

Em resumo, a Autodeterminação Informativa é o poder que cada titular de dados tem, para decidir sobre o que pode ou não ocorrer com seus dados. É o poder que ele, o titular de dados e não as empresas, tem de decidir se seus dados serão ou não coletados, que tipo de tratamento poderá ocorrer e por quanto tempo. Se esses dados poderão ser compartilhados com outras empresas ou não.

Assim, questiona-se mais: Não estando as empresas devidamente adequadas às exigências da LGPD, que tipo de garantia tem, a pessoa, enquanto titular dos dados de que eles serão protegidos? Existe a partir daí, algum tipo de segurança ao titular de dados, de que uma vez, tendo sido seus dados confiados à uma empresa, ela se limitará ao uso desses dados, apenas para a finalidade indicada e informada ao titular ou essa finalidade poderá ser desviada?

De certo que não estando a empresa adequada às regras impostas pela LGPD, não há, portanto, nenhuma garantia de que os dados estarão ou serão protegidos. Visto que, ainda que o titular dos dados conte com a ferramenta princípio da Autodeterminação Informativa, a empresa, por ela mesma, não estará pronta para atender aos pedidos e solicitações, que são de direito do cliente, funcionário, usuário ou consumidor, mesmo quando este estiver usando a Autodeterminação Informativa.

É bem verdade ainda, que tal exercício de direito, somente poderá ser exercido, por meio de ajuizamento de ações judiciais, para se fazer valer os direitos dos titulares de dados. Quando da negativa ou mesmo da inércia da empresa, que na condição de controlador dos dados, deveria de pronto (imediatamente), atender à solicitação do titular que fazendo uso da autodeterminação informativa, poderá requerer, dentre outras coisas, o não compartilhamento de seus dados, com empresas, diversas daquela com a qual ele contratou os serviços ou comprou produtos.

Não existe, portanto, a segurança almejada à proteção dos dados, quando a empresa não cumpre com a obrigação legal de se adequar, deixando assim, os dados dos titulares, desprotegidos, visto que não houve a adequação.

De igual modo, não estando a empresa devidamente adequada, conforme dispõe a LGPD, não está apta a tratar corretamente os dados pessoais, ainda que o

indivíduo faça uso do seu direito, por meio da Autodeterminação Informativa. Por exemplo, solicitando que não haja compartilhamento com outras pessoas, que haja a exclusão dos dados excedentes e desnecessários ao cumprimento da finalidade a qual houve autorização para tratamento, dentre outros direitos que lhes são pertinentes, quando da assinatura de um contrato, por exemplo, para qualquer serviço ou compra de produto, se for o caso.

Enfim, em resumo, a autodeterminação Informativa é o controle que o cidadão tem sobre os dados que lhe pertencem. É como ele que o titular de dados gerenciará e controlará o uso dos seus dados, ainda que o tratamento seja legítimo por parte do controlador.

Por exemplo, quando por meio de um contrato ou de um consentimento, forneço meus dados permitindo que esses dados possam ser objeto de tratamento por uma empresa e, mesmo tendo sido definida uma finalidade, não significa que eu não possa mais, enquanto titular desses dados, saber o que ocorre com meus dados durante o tempo em que eles serão tratados dentro da empresa.

PARTE II

■

IMPLEMENTAÇÃO E MUDANÇAS NA CULTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I QUAIS DEPARTAMENTOS DEVEM ADEQUAR-SE?

Antes de adentrar no questionamento específico, sobre quais departamentos deverão se adequar, tem-se como necessário, pensar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), estabeleceu como regra, sua aplicação para todas as pessoas jurídicas, quer de direito público, quer de direito privado e ainda, qualquer pessoa física que, tal qual as pessoas jurídicas, comercialize produtos ou serviços e que, por meio destes, realize atividades de tratamento de dados pessoais.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2018).

Dessa forma, claro está, que a Lei se aplica a todas as empresas públicas ou privadas, além das pessoas físicas que se utilizam do tratamento de dados para fins econômicos. E a lei, ainda define que a regra se aplica ao tratamento de dados por meio físico (em papel) ou mesmo por meio virtual, quando realizados dentro do território nacional brasileiro ou ainda, quando coletados no Brasil e que sejam alvos de compartilhamento internacional, também se aplica, é o que disciplina o Art. 1º da Lei, em especial, nos incisos I e III, veja-se:

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei (BRASIL, 2018).

Portanto, a lei se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, realizado no Brasil, independente do país onde está localizada a sede da empresa, desde que os dados pessoais sejam coletados no Brasil.

Nunca é demais esclarecer que a LGPD não se aplica à coleta de dados cujo objetivo não seja para ganhos econômicos (financeiro), é o que dispõe o art. 2º da Lei, vejamos:

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

[...] (BRASIL, 2018).

Assim, esclarecida a questão inicial de aplicação da Lei sobre quais empresas, tem-se a necessidade de buscar esclarecer, o ponto principal da questão aqui posta e, superada a ideia inicial, repita-se, sobre quais empresas recai a aplicação da Lei, passamos à ideia sobre “quais departamentos deverão se adequar”.

Ora, ao considerarmos que a Lei estabelece as regras para o uso, a coleta, o armazenamento, o compartilhamento dos dados dos titulares/usuários e aqui definimos que tanto para as empresas privadas, quando para as empresas públicas, deve ficar claro ainda, que o objetivo maior ou principal é a garantia de maior transparência, segurança e privacidade no uso dos dados pessoais, quando do tratamento desses dados pelas empresas e dessa forma, pensar o tratamento dos dados, dentro das empresas, pressupõe a análise de: Em quais departamentos ocorre o tratamento de dados e ato contínuo, quais devem adequar-se?

A ideia aqui é simples, vejamos. Se a Lei visa regular as atividades de tratamento de dados pessoais e dispõe claramente, que o tratamento de dados pessoais, inclusive, nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, tem como objetivo, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Logo, toda a empresa deve estar imbuída de cuidar para que toda a operação de tratamento de dados, independente de departamentos, toda ela deve, cuidar para que os dados sejam protegidos, não existindo, assim, que determinar quais os departamentos devem e quais não devem adequar-se.

Aqui, quando se fala no todo da empresa, na não distinção de departamentos, claramente, está embutida a ideia de que, muito embora a responsabilidade seja da empresa, enquanto controlador dos dados. Mas a figura do colaborador, devidamente treinado, conscientizado, nos moldes indicados pela LGP é de suma importância para assegurar que os dados não sofrerão ou não estarão em risco, em razão de descuidos ou falhas, quer intencionais ou não, venham impactar na segurança dos dados pessoais, violando assim, a privacidade dos dados que estão confiados à empresa.

Vamos entender melhor isso.

Poder-se-ia imaginar que a forma como são coletados os dados nas empresas, poder-se-ia também determinar quais os departamentos deveriam ou não se adequar. Pode gerar um equívoco, no sentido de que alguns departamentos devem e outros não precisam, quando na verdade, repita-se, todos os departamentos da empresa devem se adequar, pois a mudança da cultura da empresa como um todo, deve ser revista e, assim, estabelecida a nova Política de Privacidade da empresa. Todos os departamentos dela devem passar por treinamentos, que devem, obrigatoriamente, serem renovados em períodos curtos, a fim de estabelecer e manter as diretrizes de garantia da segurança e da privacidade dos dados. Por exemplo, estabelecendo políticas de destruição periódicas de arquivos confidenciais, o que deve ser um mecanismo constante e objeto de treinamentos, além é claro, de vários outros procedimentos que devem ser implementados no dia a dia das empresas, em todos os departamentos.

De novo, chamamos a atenção para a ideia de que não se pode mudar a cultura de uma empresa, sem o devido treinamento dos colaboradores e claro, da própria diretoria da empresa, quando estamos falando em diretrizes que visam garantir a segurança dos dados pessoais. Por isso, o correto treinamento de conscientização é peça fundamental para assegurar que os procedimentos estabelecidos pela LGPD, que visam a proteção dos dados pessoais, sejam objetos dos treinamentos, da conscientização e do correto uso por todos os colaboradores, de todos os departamentos da empresa.

Outro ponto importante a ser tratado aqui, é o fato de que os dados podem ser tratados por diversos meios e de igual modo, por diversos departamentos.

Assim, considerando que todas as fases ou etapas do tratamento de dados, que compreendem, claro, diversas atividades e que somente à título exemplificativo, temos: a coleta, a avaliação, a produção, a recepção, a classificação, a utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, a distribuição, o processamento, o arquivamento, o armazenamento, a modificação, a comunicação, a transferência, a difusão, a extração, eliminação ou qualquer forma de controle das informações do titular de dados, compreendem risco à segurança ou à privacidade dos dados. Pode então ocorrer em qualquer dos departamentos da empresa, daí a importância de todos os departamentos estarem adequados às regras impostas pela LGPD.

Não diferente disso, o descarte dos dados, a chamada eliminação dos dados excedentes, ou mesmo dos dados não utilizados pela empresa, deve ser sempre, parte integrante da rotina de tratamento de dados, pois dessa forma, quando da eliminação ou do descarte dos dados, a empresa minimiza os riscos de vazamento, repita-se, quer vazamos acidentais, quer vazamentos intencionais. E novamente chamamos a atenção para a necessidade dos treinamentos periódicos que visam conscientizar os colaboradores sobre o uso correto das ferramentas de tratamentos de dados e, em especial, o respeito a todas as fases do tratamento dos dados, cuidando especialmente, da eliminação dos dados desnecessários ou que não se aplicam à finalidade indicada no consentimento ou, em qualquer das bases jurídicas que forem utilizadas pelas empresas.

Ainda, em respeito ao viés primeiro, aqui cabe um pequeno exercício para imaginar-se. Hipoteticamente, se existe a possibilidade de adequação da Lei, por apenas alguns dos departamentos de uma empresa, esclarecemos: Pensar, por exemplo, que o setor comercial, normalmente o responsável pelo preenchimento de ficha de adesão para geração de contratos ou o departamento técnico, responsável por abertura de OS (Ordem de Serviços) para atendimento de

clientes, o departamento de marketing que é responsável pela publicidade, comunicação ou captação de clientes, ou ainda, o RH (Recursos Humanos) sejam os maiores responsáveis pelos cuidados impostos pela Lei é, de fato, um grande equívoco. Pois a responsabilidade é de toda a empresa, desde a coleta dos dados, passando por todas as fases, inclusive, o armazenamento é de responsabilidade de todos, e especialmente, da diretoria que deve ocupar-se de demonstrar que a nova cultura da empresa, passa obrigatoriamente, por incorporar os costumes que visam a segurança, a proteção e a privacidade dos dados.

O ponto, ora explorado, guarda relação direta com o que dispõe o Art. 6º da LGPD, que estabelece como devem ser as atividades de tratamento de dados e que, por conseguinte, estabelece os princípios que deverão ser observados e, claro, por todos os departamentos e pessoas dentro da empresa. Vejamos:

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas (BRASIL, 2018).

Não por acaso, dentro de todas as empresas, todas as pessoas, em todos os departamentos, devem cumprir, especialmente, a partir dos treinamentos de conscientização, fazendo valer a adequação. Considerando que, todas as atividades de tratamento de dados, que ocorre na empresa e em todos os departamentos é, definitivamente, responsabilidade de todos, incluindo, a diretoria. E aqui podemos pensar na ideia de uma gestão topdown.

Considera-se importante dizer, que não nos basta aqui, definir o termo, como sendo um método que pode utilizado para demonstrar o funcionamento das organizações. Cujo objetivo, a princípio, permite uma análise de componentes e dos microssistemas já existentes dentre da organização, ou simplesmente, apresentar um significado, ou mesmo ainda, apresentar uma tradução do termo e dizer que consiste em uma gestão que ocorre de cima para baixo, em que se pensa uma arquitetura de gestão de forma geral até atingir níveis específicos. Não, não podemos nos limitar a isso, muito embora, nesse caso, importa-se mais falar do específico no que diz respeito à relação do termo com sua aplicação no processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), mas ainda assim, devemos debruçar um olhar que parte do amplo ao específico, por assim dizer.

Há tempos, que nosso entendimento e orientação está pautada na ideia de que a empresa deve, a partir das pessoas com poder de decisão, trabalhar cotidianamente, em um processo de conscientização de que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, veio para mudar a maneira com que as empresas tratam os dados e, não diferente disso, também deve-se ter, a ideia de conscientização de que, de agora em diante, não apenas acerca da existência da lei para todos os colaboradores e parceiros, mas em especial, sobre os benefícios advindos da existência e da compreensão do seu objetivo e, não diferente disso, a necessidade de que cada um dentro da organização, independente, de sua posição, deverá aderir ao processo de implementação e adequação, como forma de compreender claramente, que a existência da lei e seu objetivo, pode sim, trazer inúmeros benefícios e que, não sejam as sanções, o motivo maior da adequação de uma empresa.

Nesse sentido, é importante que as empresas e seus colaboradores não pensem a LGPD como obrigação decorrente apenas da imposição da Lei, mas sobretudo, pela importância do respeito à maneira correta do tratamento dos dados.

Pensar de início, que toda a empresa precisa estar envolvida no processo de adequação e, mais do que isso, pensar na estrutura da adequação como sendo, um modelo em que, desde o “topo”. Ou seja, desde a diretoria de cada empresa até sua base, todos estejam envolvidos, de forma consciente, não apenas no processo de adequação, mas na conscientização da sua importância como um todo, visando a cada dia, tornar claro, o método de funcionamento da empresa com relação a sua Política de Privacidade. E claro, demonstrar que de cima a baixo, todos estão envolvidos e comprometidos com os processos internos no sentido de fazer cumprir, o que determina a Lei, no sentido de proteção dos dados pessoais.

Assim, desde sempre, deve-se pensar dentro da organização, a ideia da proteção dos dados e os cuidados que devem ser adotados dentro da empresa. E que não devem – nunca - serem alvos de apenas a diretoria, mas sim, como dito, atingir todos os envolvidos, de maneira que toda a empresa, da diretoria à sua base, faça parte desse processo, atingindo níveis específicos dentro da empresa. Sempre voltados para a ideia principal que é a de proteger os dados pessoais dos titulares dos dados.

Para se ter uma ideia, quando se pensa nas etapas de um processo, qualquer que seja o processo dentro de uma empresa existe a necessidade de pensá-lo a partir de uma conscientização quando da execução deste. Não seria diferente com os processos de implantação da LGPD.

Ainda que se pense de forma negativa a utilização ou aplicação do método no processo de adequação da Lei nas empresas, por exemplo, se considerarmos que

se pode falhar porque os colaboradores não estão preparados para executar por falta de similaridade ou por falta de treinamentos. Nesse caso, é pouco provável, pois dentro do processo de implementação da LGPD já se conta com a necessidade de treinamentos e desenvolvimento de ferramentas que visam gerar condições de utilização dos novos métodos que visam a proteção dos dados pessoais de forma harmônica e cotidiana e cujos treinamentos deverão ser renovados periodicamente, visando exatamente, manter todos, de cima a baixo dentro da empresa, imbuídos e motivados, por meio da conscientização de que são responsáveis pela proteção dos dados pessoais de todos os titulares de dados, quer sejam seus colegas colaboradores, quer sejam seus clientes.

Em resumo, conclui-se, que não, não podemos pensar, no âmbito da adequação da LGPD nas empresas, que seja possível, adequar este ou aquele departamento, ou mesmo considerar que este ou aquele departamento é mais ou menos importante, dentro da ideia de adequação ao cumprimento da lei, mas sim, que todas as pessoas de todos os departamentos, devem, obrigatoriamente, ser imbuídos de cuidar da proteção dos dados pessoais dos titulares.

■

CAPÍTULO II QUEM É A FIGURA RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS?

■

Muito embora, seja comum, se pensar que o Encarregado de Proteção de Dados, definido pela lei, como encarregado, seja o responsável pelo tratamento dos dados pessoais, mas na verdade não é, como será demonstrado a seguir.

Vale dizer, que a obrigatoriedade para a indicação do Encarregado é aplicável para empresas que contêm em seu quadro de funcionários, mesmo com 01 (um) colaborador. Mas que se, tratar dos dados de 01 (um) único cliente ou de um único colaborador, já deverá proceder com a adequação às exigências da Lei, como medida para assegurar a maneira correta com que é realizado o tratamento dos dados pessoais e privacidade.

Abre-se um parêntese para dizer que, originalmente, a Lei estabeleceu que todas as empresas (micro, pequenas e grandes) deveriam indicar o Encarregado de tratamento de dados pessoais. No início de 2022, a ANPD, que é o órgão responsável pela fiscalização, regulamentação e controle da LGPD, por meio da Resolução 02 da ANPD, estabeleceu algumas mudanças, às quais se chamou de flexibilização na Lei, visando facilitar ou favorecer essas micro e pequenas empresas, startups e entidades sem fins lucrativos, maior prazo para processamento de solicitações, dentre outras flexibilizações, a desobrigação da indicação de um Encarregado para esses casos.

O Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, muito embora, indispensável aos olhos da Lei, não é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Ele funciona como uma espécie de elo de comunicação entre a empresa (o controlador) e a ANPD, assim como entre a empresa e os titulares de dados.

Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tratou de definir, que o responsável pelo tratamento dos dados pessoais é o controlador, que é quem detém o poder de decisão sobre os dados pessoais, conforme dispõe o Inciso VI, Art. 5º da LGPD. Veja-se:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

[...] (BRASIL, 2018).

Logo, sendo o controlador (a empresa) a quem compete as tomadas de decisões sobre o tratamento de dados, também ela, a empresa, na condição de controlador é, portanto, a figura responsável pelo tratamento dos dados pessoais.

O fato é que a Lei estabelece quem são os atores da LGPD. Para que melhor se compreenda o papel de cada um desses atores, temos que é necessário esclarecer que:

1) O Controlador – que pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

2) O Operador – que pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, por exemplo, uma Contabilidade ou RH Terceirizados ou mesmo o INSS;

3) O Encarregado – nesse caso, um indivíduo ou empresa, indicados pelo controlador, que atue como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional, uma espécie de elo entre a empresa (Controlador) e a ANPD ou entre a empresa e os titulares de dados;

4) A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) é o órgão da Administração Pública, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei.

Veja-se, para além das definições acima descritas, é importante considerar que a empresa, como a responsável pelo tratamento dos dados pessoais, assume essa condição de controlador. Entende-se, portanto, que essa condição de agentes de tratamento de dados é a ela - geralmente - atribuída, justamente porque a empresa possui o dever de adotar e implementar os métodos de segurança, técnicos e/ou administrativos. O imperativo é adotar todos os meios que visem a proteção dos dados pessoais contra invasões e acessos não autorizados, bem como, evitar que haja vazamento, de forma intencional ou acidental.

De mais a mais, não se pode deixar de esclarecer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também é considerada, por alguns especialistas, como sendo um dos agentes da LGPD e sobre a ANPD. Isso se dá porque a LGPD, em seu Art. 46º, parágrafo 1º estabelece que:

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança,

técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (BRASIL, 2018).

Aqui, fica clara a figura dos agentes de tratamento e a partir daí, dos agentes de tratamento de dados. Restando clara a compreensão sobre quem é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais.

É importante ainda, esclarecer, que a LGPD trouxe a necessidade de criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e por meio da Lei nº 13.853/19 instituiu a necessidade de criação da Autoridade Nacional e ela já está criada.

Nos primórdios, a ANPD esteve diretamente ligada ao Poder Executivo, até que, em 14/06/22, fora publicada a MP 1.124/22, que alterou a LGPD e transformou a ANPD em autarquia, uma autarquia especial, que passou a ter autonomia e patrimônio próprios.

Além disso, quando se falou sobre pensar-se no Encarregado de Proteção de

Dados Pessoais como responsável pelo tratamento dos dados pessoais, quando na verdade o responsável é o Controlador. Tal fato se dá, porque às empresas foi atribuída a obrigatoriedade da figura do Encarregado de Proteção de Dados e dada sua importância, por vezes, ele é confundido com o responsável pelo tratamento de dados pessoais dentro das empresas, quando na verdade, a Lei estabeleceu em seu Art. 41º, a definição sobre quem é a figura do Encarregado. Vejamos:

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou

estabelecidas em normas complementares.

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados (BRASIL, 2018).

Veja-se mais, ainda que a Lei tenha estabelecido a obrigatoriedade de o Controlador fazer a indicação do Encarregado e, sendo inegável sua importância dentro das empresas, mas a figura responsável pelo tratamento dos dados pessoais, ainda é o Controlador.

Ainda sobre o Encarregado de Proteção de Dados, comumente chamado de DPO – em razão da lei europeia assim o designar, ou seja, DPO (Data Protection Officer) – Oficial de Proteção de Dados. Na Lei brasileira, tal designação se limita ao termo Encarregado, que na prática, por questões óbvias, se referindo ao que se chama de Encarregado de Proteção de Dados Pessoais.

O DPO (Encarregado de Proteção de Dados Pessoais), tornou-se obrigatório a toda empresa, quer seja ela Controlador ou Operador, devendo ele ser indicado como canal de comunicação, ainda que TERCEIRIZADO, toda empresa deve ter.

Essa figura do Encarregado, ainda que terceirizado, tornou-se prática comum nas empresas, por dois aspectos básicos.

Primeiro, porque as empresas não dispunham de muito tempo para treinar adequadamente um profissional interno para ocupar a função, considerando que

ele precisaria ter conhecimentos sólidos sobre a empresa, seu sistema de informação e ainda, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD brasileira e sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR, lei europeia. Considerando, em especial, aqueles casos de compartilhamento de dados internacionais entre empresa, ou matriz e filial em um dos países da Europa.

Segundo, porque o custo para tal formação a curto prazo e mesmo o acúmulo das funções, poderia em muitos casos, impactar nas atividades da empresa e ser um complicador, visto que as demandas já desenvolvidas quando somadas àquelas a serem desenvolvidas para a finalidade a que fora indicada a figura do Encarregado.

Quando se fala no curto prazo para formação do Encarregado é considerando que a Lei foi criada em 14/08/2018 e entrou em vigor em 18/09/20. Portanto, as empresas tiveram 02 (dois) anos para se adequar.

Além disso, as sanções já entraram em vigor em 01/08/2021 e, não há mais tempo a perder, sob pena das sanções lhe serem impostas, visto que, o início das fiscalizações já foram determinados pela Resolução 01 da ANPD, em seu Art. 70º, cuja entrada em vigor foi estabelecida para janeiro de 2022.

Conclui-se então, que o DPO (Data Protection Officer), no Brasil, denominado de Encarregado de Proteção de Dados é o profissional que ficou responsável pela avaliação, pelos cuidados, pela educação e pelo monitoramento das atividades de tratamento de dados pessoais dentro da empresa.

Isso é tão verdade, que aliado à ideia de que cada funcionário não pode ser responsabilizado por algo para o qual ele não foi treinado, também ao Encarregado, ainda que este sim, detenha obrigatoriamente, conhecimentos para

o ônus, não pode ser atribuída a ele, a responsabilidade pelo tratamento dos dados pessoais na empresa, pois esta é, na verdade, uma responsabilidade do Controlador.

É, portanto, em síntese, aquele profissional que ficou responsável por auxiliar a empresa no que diz respeito ao cumprimento de todas as obrigações que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que não se confunde com o que já está definido, sobre a figura responsável pelo tratamento dos dados pessoais, como sendo a empresa, o Controlador.

■

CAPÍTULO III SOBRE AS ADEQUAÇÕES NOS CONTRATOS

■

A partir de uma visão geral sobre a Lei brasileira, a LGPD, Lei nº 13.709/18, que segue o modelo europeu e nesse quesito, temos que lembrar que a lei europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a saber, o Regulamento 679/16, que passou a ser aplicado, obrigatoriamente na Europa a partir de 25 de maio de 2018, traz em Art. 6º:

Art. 6º - O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações:

[...]

b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados;

[...] (BRASIL, 2018).

Nesse sentido, a LGPD de igual modo estabeleceu em seu Art. 7º:

Art. 7º - O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...]

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular a pedido do titular dos dados;

[...] (BRASIL, 2016).

Superada essa ideia introdutória há que se falar, que importa dizer, que a adequação das empresas aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais passa pela necessidade de adequação de “todos” os contratos da empresa.

Quando falamos em todos os contratos da empresa, estamos falando de realizar alterações contratuais - de forma rigorosa - pois todos os contratos, por exemplo, contratos do Controlador com os titulares dos dados, sejam eles internos ou externos. Ou seja (com funcionários ou clientes/consumidores), do controlador com fornecedores, do controlador com o operador (empresa e parceiros que manipulam os dados do controlador – exemplo: Empresa/Controlador X INSS, Contabilidade terceirizada, RH terceirizado), etc. Enfim, todos os contratos querem novos ou já existentes na empresa.

O fato é que, todos os contratos, desde a entrada em vigor da Lei, devem incluir ajustes ou inclusões sobre informações “específicas” relativas à privacidade e proteção de dados pessoais, além de fazer constar nos “novos” termos. Estes também devem ser incluídos no rol dos ajustes contratuais naquilo que for necessário para que conste de forma a fazer valer, as questões relativas à privacidade e proteção de dados pessoais, nesses novos termos e contratos.

E quando falamos em “novos termos”, estamos falando por exemplo, dos termos de aceite, termos de responsabilidade, termos de privacidade, termos de uso, termos aditivos, termos de consentimento, termos de conduta, termos de privacidade, termos acessórios, termos de integração, termos e condições de contratos diversos. Enfim, de todos os termos que, geralmente, são utilizados no dia a dia para estabelecer relações contratuais entre empresas e empresas (B2B), entre empresas e pessoas (B2C), dentre outros.

Além disso, as mencionadas informações específicas devem também constar nos novos contratos, seja com clientes ou parceiros, fornecedores, todos os novos contratos que venham a ser estabelecidos dentro da empresa.

Explicando melhor essa questão, todos os contratos, tanto os já existentes, que precisam ser alterados/ajustados para fazer constar informações específicas sobre a proteção dos dados, quanto os novos contratos que não podem deixar de constar as mesmas informações, ditas “específicas, sobre a proteção dos dados”, estas baseadas e de acordo com o que determina a LGPD, no quesito privacidade e proteção de dados.

Em resumo, todos os contratos já existentes na empresa e, todos os novos contratos, precisarão ser alterados, fazendo constar as alterações obrigatórias, de acordo com a Lei.

Importante lembrar que a Política de Privacidade não é apenas aquele documento que é elaborado e disponibilizado no site da maioria das empresas, o Termo de Privacidade é, em regra, a própria implementação. É o processo de adequação da empresa aos rigores da LGPD, apenas para que se conste.

Para além desta questão, importa ainda dizer, que o Código Civil Brasileiro, a Lei nº 10.406/2002 estabeleceu em os negócios jurídicos para terem validade, devem ser interpretados com base na boa fé objetiva. Veja o que dispõe o Art. 104 do Código Civil, complementado pelo Art. 113 do mesmo diploma legal:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

[...]

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

(Grifo nosso).

O que são os negócios jurídicos e como eles se dão? Os negócios jurídicos são, em resumo simples, a manifestação da vontade das pessoas, por meio de contratos, que são celebrados, quando, por exemplo, da realização de uma compra e ou venda ou da realização de uma prestação de um serviço entre duas ou mais pessoas ou empresas.

E nisso, temos que, o mesmo Código Civil, estabelece que os negócios jurídicos, devem ser interpretados com base na boa fé objetiva dos contratos.

Daí a necessidade de entender melhor sobre a boa-fé objetiva nos contratos, que em resumo, significa dizer, que é a maneira como se deve agir ou se comportar em relação a outra parte do contrato ou perante a outra parte, no que diz respeito

a confiança ou mesmo a honestidade que deve sempre prevalecer quando contratamos com alguém. É o fazer valer do que moralmente, ética e mesmo legalmente, está posto em sociedade.

No que diz respeito a LGPD a boa-fé objetiva vem acompanhada dos princípios da finalidade, da adequação, da segurança, da necessidade, da transparência e de outros mais, direitos do titular de dados.

Mas a LGPD, como não poderia deixar de ser, preocupa-se primordialmente com a proteção dos dados pessoais, visando evitar possíveis violações que coloquem em risco os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e, do livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais, conforme dispõe o Art. 1º da Lei.

Nesse sentido, a Lei trouxe, conforme já antecipado, a necessidade de adequação de todas as empresas, quer públicas ou privadas, além das pessoas físicas cujo uso dos dados tenha finalidade econômica. Além disso, a adequação dos contratos é parte integrante do processo de adequação da empresa às normas estabelecidas pela LGPD.

Sobre a necessidade de revisão ou adequação dos contratos é muito importante entender que, a coleta de dados não está limitada aos meios digitais, como claramente estabelece o referido Art. 1º da Lei, mas também, aos meios físicos. Nisso, temos que considerar os dados que estão relacionados ou dispostos em contratos, então surge a necessidade e a obrigatoriedade de adequação dos contratos.

Deve-se observar, que sendo importante para a empresa estar adequada a LGPD, a revisão ou adequação dos contratos se faz de igual modo, necessária, sob pena de incorrer em falha no processo de adequação.

Diante disso, há que considerar, que a revisão dos contratos é uma forma de prevenção das empresas, por exemplo, para a minimização de riscos de incidentes, que podem provocar a aplicação de sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que podem gerar problemas com processos judiciais indenizatórios que podem gerar elevados prejuízos à empresa, que muitas vezes, abalam mais do que o campo financeiro, podem abalar a credibilidade da empresa, na sua área de atuação ou mesmo no mercado como um todo.

Nesse sentido, existe a necessidade de mencionarmos que algumas cláusulas contratuais, devem passar a constar dos contratos antigos e, claro, não podem faltar nos novos contratos.

A empresa deve, portanto, conhecer seus contratos e a partir daí, estabelecer as alterações necessárias, fazendo constar as cláusulas que são consideradas obrigatórias nos contratos.

Não é demais esclarecer que esse trabalho deve sempre ser realizado por um profissional especializado e que, as adequações devem vislumbrar os contratos, considerando, por exemplo, que muitos são os tipos de contratos utilizados na empresa, as diversas áreas que necessitam ter seus contratos ajustados, em razão da coleta ou mesmo do tratamento de dados, inclusive, observando os mecanismos dos contratos já existentes.

Outro ponto muito importante e que requer total atenção da empresa é a observação aos contratos em que acontece o tratamento de dados sensíveis, além da empresa ocupar-se em gerenciar todos os riscos decorrentes do tratamento de dados na empresa.

Das Cláusulas Obrigatórias:

Cláusula de Tratamento de Dados: deve constar dos novos contratos e ou aditivos aos contratos já existentes, uma cláusula que verse sobre o tratamento dos dados pessoais, onde haja a indicação clara da finalidade, das obrigações contratuais que devem ser descritas no instrumento, além das outras cláusulas anteriormente definidas com base nos termos de privacidade de uso

Deve ainda, constar desta cláusula, a vedação ao compartilhamento dos dados pessoais, sem a concordância da outra parte, com a finalidade evitar violação a finalidade.

Por fim, deve ficar claro na cláusula que as partes envolvidas no contrato tratarão os dados pessoais em consonância e observância a todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis, consoante o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Cláusula de Responsabilidade: considerando, por exemplo, que a empresa opera com operadores, parceiros, clientes e funcionários e, dessa relação deriva responsabilidades de parte a parte, a empresa deve incluir em todos os contratos, cláusula de responsabilidade que estabeleçam obrigações em geral à respeito das normas de proteção de dados, estabelecidas na LGPD, cujas responsabilidades devem estender ao que estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC), naquele que lhe couber.

A empresa, na condição de Controlador, deve estabelecer responsabilidades, especialmente, com operadores e parceiros, exigindo, principalmente, que estes estejam igualmente adequados às normas da LGPD, sob pena de, no caso de a empresa sofrer sanções ou mesmo em caso de condenações solidárias, poder

promover ação de regresso, para fazer valer seu direito ao que lhe fora imputado como responsabilidade indevidamente, em razão ou decorrência da omissão ou da não adequação do operador ou parceiro.

Cláusula de Confidencialidade: ao adequar os contratos, a empresa deve ainda fazer constar, de forma clara, sobre a confidencialidade e sigilo, quanto ao conteúdo dos dados pessoais que são, eventualmente, disponibilizados no próprio contrato, demonstrando haver, comprometimento das partes quanto à proteção dos dados, evitando que haja possibilidade de acesso de outros, inclusive, a concorrência, às informações importantes e constantes do contrato havido entre as partes.

Cláusula de indicação de procedimento para relatórios de incidentes: deve constar dos contratos, a indicação do procedimento que será adotado pela empresa para o caso de incidentes no tratamento dos dados, considerando que a empresa, em caso de vazamento de dados, deverá adotar meios para elaborar os relatórios, que poderão ser exigidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou pelo judiciário.

Cláusula de Consentimento nos Contratos: importante considerar que nos contratos, novos ou ajustados por meio de aditivos, deve constar cláusula especial, que estabeleça de forma clara e inequívoca, o consentimento do titular dos dados, concordando com o tratamento dos seus dados pessoais, de acordo com a finalidade indicada no objeto do contrato, em respeito às normas da LGPD, constando assim, as disposições necessárias, sempre de forma transparente e acessível à parte envolvida no contrato com a empresa.

Quando se fala em ajuste aos contratos antigos deve ficar claro que tais ajustes, via de regra, ocorrerão por meio de um aditivo contratual que terá por objetivo inserir as cláusulas obrigatórias, no contrato já realizado entre as partes, fazendo constar aquelas disposições que foram estabelecidas pela LGPD, sobre a

proteção dos dados pessoais dos titulares. Dessa forma, as partes contratantes/contratadas, após a vigência da LGPD, passam a estarem sujeitas ao que dispõe o contrato, seu aditivo e em razão do cumprimento da lei.

Deve-se considerar ainda que na hipótese da outra parte entender por bem, não assinar o aditivo contratual, que estabelece sobre a adequação da empresa e consequentemente do contrato, às normas estabelecidas pela LGPD, poderá a empresa, sob o fundamento de descumprimento legal, rescindir o contrato, mediante notificação prévia ao titular dos dados.

Dessa forma, considerando a importância da adequação dos contratos para a adequação às regras da LGPD, em especial, para a empresa, tem-se que, as mencionadas alterações, para além de obrigatórias, trazem segurança jurídica e mais do que isso, evita danos e prejuízos à empresa, que possam ser causados por vazamentos de dados, quer de forma acidental ou intencional.

■

CAPÍTULO IV O QUE MUDA NO E-COMMERCE COM A LGPD?

■

Em um passado recente a ideia que dominava era aquela de um mundo globalizado. Tempos depois veio a era da digitalização e com ela, os avanços da vida online que foram intensificados com a chegada da pandemia, que não por acaso, acelerou o uso dessas novas tecnologias, mesmo sabendo que muito embora, várias delas já existissem, ainda assim, tiveram seus usos acelerados pela chegada da pandemia e as plataformas de comércio eletrônico, são indiscutivelmente uma das plataformas que mais teve seu uso intensificado, potencializado, durante esse período da pandemia.

Apenas para que se entenda melhor, o e-commerce – que pode ser entendido como um comércio eletrônico – é um modelo de negócio que se estabelece no formato de uma loja virtual, onde se pode encontrar online, produtos e serviços, ou seja, no ambiente da internet.

O fato é que, ainda que se pense na LGPD (2018), como uma legislação anterior à pandemia (2020), a necessidade de regulação e proteção dos dados pessoais, em razão do e-commerce vieram de forma indiscutível e identificar o que muda no e-commerce a partir da entrada em vigor da Lei faz toda diferença.

É um fato também, que dada a alta movimentação das muitas transações virtuais de compras de produtos e serviços, essa prática fez com que muitas empresas desse segmento, tivessem que se preocupar um pouco mais com a necessidade de adequação às normas estabelecidas pela LGPD, com a finalidade de garantir maior segurança às transações comerciais que ocorriam sob suas responsabilidades e para atingir seus objetivos.

Muito embora, a grande maioria das micro e pequenas empresas no ambiente físico, ainda não tenham buscado se adequarem às normas da LGPD, de igual modo, existe um sem-número de empresas no ambiente virtual, que também não se adequaram e por isso, também estão expostas aos riscos decorrentes da não adequação e isso persiste.

É bem verdade também, que muitas empresas sejam no ambiente virtual ou no ambiente presencial, não se atentaram para os prazos e, principalmente, para os riscos de fiscalização e mesmo para o peso da aplicação das sanções, derivadas pelo descumprimento da LGPD. Ignorando assim a necessidade de adotarem e manterem as boas práticas de segurança e governança para o tratamento adequado dos dados pessoais, coletados e tratados pelas empresas.

A verdade é que como a Lei já está em vigor desde 18 de setembro de 2020, a cada dia, aumentam os riscos de incidentes com os dados que estão sob a responsabilidade dessas empresas que, ao não se adequarem, podem vir a sofrer o peso das sanções e/ou mesmo, dos processos judiciais que normalmente contam com pedidos de indenizações, para os casos de vazamento dos dados pessoais.

É importante frisar, que as empresas do chamado e-commerce devem, atentar-se para a necessidade urgente de adequação, tendo em vista, os elevados riscos. Devem adequarem-se logo, em especial, buscando a implementação de uma Política de Privacidade de dados que seja efetiva e adequada ao que dispõe a LGPD.

Uma forte tendência dos últimos tempos na e-commerce é a contratação de consultorias jurídicas especializadas, baseadas no uso intensificado das compras realizadas por meios eletrônicos, que passaram a ganhar força e exigir das empresas de e-commerce, cuidados no sentido de evitar que haja vazamento de

informações/dados pessoais. Como já dito, quer de maneira acidental, quer de maneira intencional, mas que de uma forma ou de outra, podem ocasionar em riscos à segurança dos dados e portanto, passível de aplicação das sanções por parte da ANPD e que podem ser consideradas penalidade pesadas para muitas empresas, naqueles casos de tratamento de dados de forma irregular, pois as sanções podem ser demasiadamente rigorosas.

Seria redundante dizer, que esses vazamentos podem gerar grandes prejuízos financeiros, mas como também já explicitado anteriormente, mais do que os danos financeiros, podem gerar grandes danos à imagem da empresa. Pois assim como o processo de vendas foi acelerado pelo uso em massa das compras pela internet, essa mesma internet, também se tornou uma ferramenta extremamente eficaz para a realização de denúncias, comentários, positivos ou não, e a publicidade negativa para os casos de violação dos direitos dos titulares, comprovadamente, abalam e muito uma marca.

Nesse sentido, esclarecer o que mudou com o e-commerce com a entrada em vigor com a LGPD passou a ser uma questão importante.

De início, entende-se que não é demais esclarecer que o usuário/titular dos dados passou a ter, com a entrada em vigor da LGPD, diversas garantias e uma das principais dessas garantias é o direito a consultas ou informações sobre seus dados. Que aliado ao direito de alteração e mesmo de eliminação dos seus dados, em caso de omissão ou negativa por parte da empresa, lhe é possível realizar denúncias junto à ANPD ou mesmo ajuizar ações perante o judiciário, em razão do descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O que antes apenas era possível, com fundamento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e esta é uma das principais mudanças que afeta diretamente o e-commerce.

Importa esclarecer que o direito a consultas que busca pela existência ou não de dados pessoais parte do titular, mencionado acima, está amparado pela LGPD, conforme dispõe o Inciso II, do Art. 19 da Lei:

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular:

[...]

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular (BRASIL, 2018).

O e-commerce, tal qual os demais segmentos que tratam dados, passou a ter uma nova regulação desde a entrada em vigor da LGDP, uma vez que o ambiente da internet, deixou de contar apenas com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/90 e da Lei nº 12.965/14 - Marco Civil da Internet, que nasceu com objetivo principal de regular o uso da internet no Brasil, ou seja, trouxe consigo, já no seu Art. 1º a função de estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres, para o uso da internet no Brasil. Vejamos:

Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria (BRASIL, 2014).

Chama-se a atenção para o fato de que o Marco Civil da Internet, já trazia a exigência da necessidade de o usuário permitir, expressamente (por escrito), para que houvesse o compartilhamento de seus dados, como assim dispõe o Art. 7º, nos Incisos VII e IX, da Lei nº 12.965/14:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

[...]

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;

[...] (BRASIL, 2014).

No mesmo sentido, já trazia aquela ideia da Autodeterminação Informativa, que hoje tornou-se comum e nem por isso, menos importante, pois estabelecia o direito a solicitação de exclusão dos seus dados pessoais e que, não por acaso, o texto foi modificado, adequado, e por que não dizer, melhorado pela LGPD, conforme se comprova pela alteração trazida pelo Art. 7º, Inciso X:

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;

[...] (BRASIL, 2018).

O Marco Civil da Internet ainda trazia a exigência para que as empresas do e-commerce pudessem aplicar corretamente, as Políticas de Privacidade de Dados, conforme se comprova pelo disposto no Art. 11 da Lei:

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

Importante notar que a LGPD trouxe, definitivamente, um novo panorama para as relações comerciais e não seria diferente, no campo do e-commerce, visto que suas regulações impactaram fortemente a maneira como as empresas passaram a tratar dados pessoais.

Para se ter uma ideia, a LGPD que tem como função principal, regular as atividades de tratamento de dados pessoais, alterou os Arts. 7º e 16º do Marco Civil da Internet, obrigando as empresas se adequarem às exigências trazidas pela LGPD em dois aspectos.

O primeiro, conforme citado acima, que assegurou aos usuários da internet, o direito à exclusão definitiva dos seus dados pessoais, mediante simples requerimento, quando finalizado o seu contrato com a empresa. Claro, ressalvados aqueles casos em que houver necessidade de guarda obrigatória dos registros, conforme também é previsto no próprio Marco Civil (Art. 15).

O segundo diz respeito à proibição para guarda ou armazenamento de dados excessivos do titular, mesmo mediante seu consentimento, salvo, naquelas situações/hipóteses em que a própria lei estabeleceu a necessidade da guarda (Art. 15).

Veja-se que, em ambos os casos, a preocupação das duas leis (Marco Civil e LGPD) está voltada para a privacidade e proteção dos dados pessoais, quando da realização de operações na internet, o que é, de fato, o principal objeto das empresas de comércio eletrônico.

Dessa forma, pensar no que muda para o e-commerce com a entrada em vigor da LGPD é pensar, desde o início, que todas as empresas, especialmente, aquelas que realizam suas operações no online, ou seja, aquelas que praticam o e-commerce, precisam de agora em diante, seguir novas regras para a coleta e tratamento de dados e, deve adotar cuidados especiais para os casos de dados de coleta de dados sensíveis, conforme já esclarecemos anteriormente.

Dentre essas mudanças, chamamos a atenção para a aplicação correta das bases legais e nisso, temos que uma das principais mudanças trazidas pela Lei, para esse segmento, diz respeito ao fato de que, os dados somente poderão ser manipulados por essas empresas mediante o fornecimento do consentimento de forma clara e autorizações expressas dos usuários.

Outra mudança que se pode deixar de mencionar é aquela que diz respeito ao marketing praticado pelas empresas. Desde a entrada em vigor da LGPD, os profissionais de marketing junto com suas assessorias jurídicas, tem se debruçado em criar novas estratégias para a coleta de dados de forma a não infringir a Lei, considerando, especialmente o que falamos sobre o tratamento dos dados coletados, que passaram a ter a obrigatoriedade de somente poderem ser tratados pelas empresas mediante o citado consentimento, cujo fornecimento, repita-se, deverá ser fornecido de forma clara e inequívoca, sob pena de incorrer em infração à Lei.

Já que está se falando de marketing não é possível não mencionar o que muda com o regramento para o chamado marketing de relacionamento nas empresas de e-commerce, muito embora a regra se aplica também às demais empresas. Com a entrada em vigor da LGPD as empresas de e-commerce precisam, necessariamente, revisar as regras e as práticas para o chamado marketing direto e também o chamado marketing de atração, pois essas duas modalidades são exercidas a partir do uso de um banco de dados já existente nas empresas, que é normalmente utilizado para realizar essa comunicação direta com o titular dos dados, seja por e-mail (o chamado e-mail marketing), seja por via de uma ligação telefônica (telemarketing), seja por meio de SMS. Enfim, qualquer que seja a modalidade pressupõe que os dados utilizados foram, a partir de um banco de dados, preexistente e nisso questiona-se, todos esses dados, coletados anteriormente à entrada em vigor da Lei possuem consentimento ou estão protegidos por uma base legal “adequada”?

Se a resposta for não, a prática é passível de sanção. Veja, portanto, que por ser um segmento de marketing que se ocupa diretamente do uso dos dados pessoais dos clientes, consumidores e por isso, titulares dos dados, devem as empresas redobrar os cuidados com o tratamento desses dados. Pois qualquer divulgação por meio dessas informações, pode representar prova direta da violação aos direitos dos titulares de dados e, portanto, repita-se, passíveis de aplicação das penalidades impostas pela LGPD em conjunto com o próprio CDC e essa é uma mudança que ressignificou o marketing, especialmente para as empresas do e-commerce, naturalmente, pelo seu ambiente e forma de trabalho.

Ainda sobre o impacto das mudanças trazidas pela LGPD ao e-commerce, tem-se que mencionar que, não é que as empresas estão proibidas de tratar os dados, mas as empresas precisam, a partir da entrada em vigor da Lei buscar a adoção de novos métodos de trabalho, buscando tornar o relacionamento com os clientes/titulares de dados, cada dia mais transparentes, além de deixar claro que nesse relacionamento empresa/cliente estão sendo respeitadas todas as exigências e especificidades impostas ou trazidas pela entrada em vigor da LGPD.

Como se explica a necessidade de adoção desses cuidados? Explica-se, considerando que desde a entrada em vigor da Lei, havendo vazamentos de dados decorrentes de uso não autorizado dos dados ou mesmo por meio de outras infrações às normas estabelecidas na Lei (por exemplo, não adequação), poderão ser motivo de aplicação das mencionadas sanções administrativas, que poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Nesse sentido, cumpre-nos responder: Afinal, quais as principais mudanças que se entende que devem ser adotadas pelas empresas?

Aquela que diz respeito a necessidade de mudança cultural quanto ao entendimento relativo à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade nas questões de tratamento de dados.

E não menos importante, aquela que diz respeito a necessidade obrigatória de adequação, do chamado Termo de Uso e, principalmente, da Política de Privacidade. Esclarecemos que o principal motivo, para além da imposição legal, é a demonstração de que a empresa está adequada às exigências da Lei e que busca facilitar ao cliente/titular de dados, o acesso às informações sobre os dados pessoais desse cliente, que estão guardados sob sua responsabilidade.

Dessa maneira, conclui-se que estas são as principais mudanças trazidas ao e-commerce pela entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, considerando, em especial, a importância desse segmento ao mundo digital e a esta nova era.

CAPÍTULO V TERMO DE ACEITE E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

As empresas em geral, ao longo dos anos, desde que se passou a utilizar a contratação de produtos e serviços por meio da internet buscaram praticar o estabelecimento das regras em geral, por meio dos termos de aceite, que são aplicados aos contratos realizados e assinados no ambiente virtual. Já que estamos falando de negócios nesse ambiente, a publicidade da Política de Privacidade nos sites dessas empresas, tornou-se o meio pelo qual, essas regras são apresentadas ao cliente/usuário/titular dos dados e, isso é um fato.

Não se pode duvidar, que o Termo de Aceite e a Política de Privacidade, são documentos considerados de grande importância para que as empresas possam realizar o tratamento dos dados pessoais do usuário, da forma como está estabelecido na legislação. Sendo que são esses contratos que garantirão aos usuários a correta utilização de seus dados, de acordo com a finalidade estabelecida nestes contratos e que será praticada pelas empresas que os coletam.

Ocorre que, considerando a importância que foi atribuída à privacidade e a proteção dos dados pessoais, quando da entrada em vigor da Lei LGPD - Geral de Proteção de Dados, as empresas foram obrigadas a adotar e implementar, com maior rigor, alguns cuidados com os termos de aceite e, especialmente, com a Política de Privacidade, que passou a ter regramento mais protetivo aos direitos do consumidor, nesse caso, os titulares dos dados.

De certo que a LGPD trouxe novas definições em relação a diversos termos e temas, como por exemplo, sobre o tratamento de dados e com isso, termos como dados pessoais, dados sensíveis, consentimento, base legal, dentre outros, foram

acrescentados ao dia a dia das empresas, para que os dados passem a ser tratados adequadamente, de acordo com a Lei.

Partindo desse ponto, deve-se inicialmente, pensar nos conceitos ou definições básicas do que são, o termo de aceite e, naturalmente, a Política de Privacidade, o que ora passamos a descrever, posto que esse é o tema de nosso interesse aqui.

O Termo de Aceite - em descrição geral é um documento elaborado e disponibilizado pela empresa (controlador) para que o usuário (titular dos dados) possa sinalizar que concorda com a política estabelecida para uso de um sistema, um site, um serviço etc., e que é disponibilizado logo no início do acesso ao site da empresa.

O termo de aceite deve demonstrar de forma clara e inequívoca, que o usuário leu e que concorda com os termos ali dispostos, por essa razão, a sugestão é para que o termo já faça menção ao que dispõe a LGPD, sobre a manifestação livre, informada e inequívoca, conforme indica a Lei, por exemplo:

O presente termo, tem por objetivo, registrar a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual, você (o usuário), concorda com o tratamento de seus dados pessoais, que ora são disponibilizados, para finalidade específica, em conformidade com a LGPD - Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Diante disso, de acordo com a interpretação da Lei, entende-se que o usuário, ao concordar com o termo de aceite, estará ciente de que os seus dados ali fornecidos, serão utilizados, exclusivamente, para a finalidade indicada e que, desta forma, estarão protegidos de acordo com o que estabelece a LGPD.

Em síntese, o termo de aceite é, portanto, uma espécie de contrato em que o usuário de um site “aceita” acessá-lo, autorizando a coleta dos seus dados, de acordo com a finalidade deste ou daquele site, de acordo com seu interesse.

Falar do termo de aceite, importa também, explicar sobre o Termo de Uso.

O Termo de Uso – é caracterizado por uma espécie de contrato de adesão, onde o cliente/usuário, aceita os termos ali descritos e declara tomar conhecimento dos procedimentos que serão adotados e que permitirão o uso do site que está sendo, por ele acessado.

A Política de Privacidade – Descrita de forma simples, a Política de Privacidade, é um documento, considerado muito importante, que tem por objetivo, explicar de forma clara, os processos e as práticas que serão adotadas pela empresa e que são disponibilizadas, por meio de um site, de um aplicativo ou mesmo através de um provedor de internet, para que se cumpra com o dever de publicidade dessas regras, regras essas, que são estabelecidas para regular a relação entre contratante e contratado e para garantir a segurança, a privacidade e a proteção dos dados pessoais do usuário/titular dos dados.

Em resumo, a Política de Privacidade consiste no estabelecimento das regras gerais e específicas que passarão a valer em relação ao usuário e a empresa, descrevendo como e quais os dados serão coletados, como serão tratados, armazenados e, se for o caso, compartilhados, com base nos dados fornecidos, conforme prevê a LGPD.

Superada esta etapa das definições básicas do que são o Termo de Aceite e a Política de Privacidade.

É muito importante que se esclareça, que o pensamento atual é de que, para que a Política de Privacidade esteja em conformidade com a Lei, ela precisa descrever os dados pessoais que serão coletados, estabelecer a finalidade para qual os dados são coletados, bem como, estabelecer rigorosamente com quem esses dados serão compartilhados.

O ponto de partida para o estabelecimento da Política de Privacidade é levar ao usuário/titular dos dados a informação sobre todas as atividades que serão realizadas por meio da Política de Privacidade. Isso deve ser feito de forma muito transparente, estabelecendo principalmente, as medidas de segurança que empresa irá adotar para proteger os dados pessoais e quais mecanismos serão utilizados, desde a coleta passando por todo o processo de tratamento dos dados, incluindo o armazenamento desses dados, pois dessa forma, o usuário poderá, por meio do consentimento e ciente da possibilidade de revogação deste, assinar o Termo de Aceite, de forma consciente.

Importante chamar a atenção para o fato de que, uma vez não estando a empresa com o Termo de Aceite e a Política de Privacidade, devidamente em conformidade, isso pode gerar, para além dos riscos jurídicos, impactos econômicos, prejuízos ou mesmo abalo a credibilidade e a reputação da empresa, pois essa quebra de confiança pode, por vezes, impactar muito negativa e fortemente a marca de uma empresa, dado o dinamismo com que circulam as informações negativas no mundo virtual atualmente.

Dessa forma, a empresa deve buscar garantir o cumprimento legal das obrigações impostas pela Lei, pois isso representa sim, um investimento e não um custo para ela.

Um dado importante a ser observado é que, as empresas devem considerar, de acordo com seu produto, seu público-alvo, a faixa etária de seus consumidores, dentre outras particularidades, que além dessa ideia geral, existe na maioria das vezes, a necessidade de pensar em questões mais específicas para tratar na

Política de Privacidade.

Como por exemplo, estabelecer uma data de vigência para a Política de Privacidade e mantê-la sempre atualizada; notificar regularmente o cliente/usuário sobre quaisquer atualizações realizadas na Política de Privacidade; informar claramente os casos em que terceiros poderão ter acesso aos dados fornecidos e descrever detalhadamente quem são esses terceiros, quais dados serão acessados e qual a finalidade do compartilhamento; tornar público e de fácil acesso os dados de contato da empresa para o caso de reclamação e ou discordâncias com eventuais pontos do termo de aceite ou da Política de Privacidade, além é claro, de descrever de forma clara, quais são os direitos dos usuários/titulares em relação aos dados que lhe pertencem e a empresa também deve deixar claro, que informações adicionais, caso solicitadas pelo cliente/usuário, devem ser fornecidas.

Sendo um pouco mais prático: O que deve obrigatoriamente conter na Política de Privacidade? E pergunta-se mais: Quais são os elementos indispensáveis ou o que não podem faltar como conteúdo, quando da elaboração de uma Política de Privacidade?

Durante muito tempo, o conteúdo aplicado a Política de Privacidade dependia da lei aplicável, posto que isso poderia variar, por exemplo, de acordo com o país onde estava sediada a empresa, considerando o mundo globalizado e a possibilidade de realização de compras por usuários de qualquer parte do mundo.

Cumpramos esclarecer que vários dos pontos indispensáveis para se fazer constar na Política de Privacidade já podem ter sido mencionados acima, mas em se tratando daqueles que são indispensáveis não podemos deixar de citar:

- A descrição obrigatória da propriedade do site ou do App;

- A informação clara sobre quais dados serão coletados;
- Deve descrever se dados sensíveis serão coletados e tratados;
- Com quem os dados serão compartilhados, se for o caso;
- Se houve transferência/compartilhamento internacional de dados, descrever com base, por exemplo, no Regulamento Geral da União Europeia que torna obrigatório explicitar todas as medidas adotadas para tornar segura essa transferência;
- Descrever qual a finalidade da coleta dos dados;
- Quais as bases legais estabelecidas pela LGPD serão aplicadas para a coleta dos dados, de acordo com a finalidade e aqui, podemos citar por exemplo, a base legal do consentimento, a base legal do contrato;
- Descrever de forma clara, quais são os direitos dos usuários;
- A notificação aos usuários sobre alterações na Política de Privacidade;
- E como já dito, deve constar a data de vigência da Política de Privacidade.

De mais a mais, sobre a Política de Privacidade, considera-se de suma importância esclarecer, que diferente do que muitos pensam, ela não é, e não pode ser considerada, apenas como “aquele documento” que é disponibilizado no site das empresas. Mais do que isso, aliás, muito mais do isso, “aquele documento” resume a verdadeira Política de Privacidade, que em síntese, podemos descrever como um programa de governança de privacidade e proteção de dados dentro da empresa.

O que isso significa, afinal? Significa dizer que a empresa, ao elaborar sua Política de Privacidade considerará alguns aspectos que são importantes para atingir mais do que simplesmente o “resumo” daquele documento que subirá ao site.

Deve considerar nesse processo de elaboração do documento, a mudança na cultura da empresa, por meio de todos os colaboradores, incluindo é claro, nos tempos atuais, todos os impactos da LGPD não apenas no cumprimento das regras escritas, mas especialmente, das regras que deverão serem seguidas dentro da empresa. Em que, cujo reflexo será demonstrado no documento, mas antes, será vivenciado dia a dia na empresa, por meio da mudança na cultura, demonstrado no comportamento prático de cada colaborador, de cada membro da diretoria, em todos os níveis, ou seja, trata-se de um trabalho conjunto, pensado e elaborado por toda a empresa.

Desde o planejamento inicial da elaboração da política, deve ser demonstrada de forma cabal, a importância da privacidade dos dados para além da preocupação com a proteção dos dados pessoais, transformando essa ideia em uma cultura cada dia mais sólida dentro da empresa, de maneira que isso faça total sentido para todos dentro da empresa, de forma que atinjam o ponto de não mais ocorrer dúvidas sobre tal importância.

Do que estamos falando aqui, certamente, estamos falando de um nível de conscientização que é importantíssima para conceber um programa verdadeiro de governança, privacidade e proteção de dados, totalmente em conformidade com o que hoje é estabelecido pela legislação geral.

Independente dos dados ou do volume de dados trafegados dentro da empresa, muito embora quanto maior o volume maior deve ser o cuidado, mas o nível de responsabilidade também está diretamente ligado à essa proteção dos dados coletados e tratados todos relacionados a tal finalidade destinada aos dados coletados e informados aos clientes/usuários/titulares dos dados.

Quando falamos que se trata de um trabalho conjunto e que necessita do comprometimento de todos dentro da empresa, é porque essa ideia é importante, pois estamos falando de um processo dentro da empresa que não se interrompe. Ele é contínuo e passará por atualizações constantes e permanentes, visto que, todos os envolvidos pensarão nesse programa de forma contínua, dentro do cenário das transformações que lhes são impostas pelo próprio avanço tecnológico e pela necessidade de promover os treinamentos constantes de atualização dos colaboradores. Inclusive, de novos colaboradores, com a finalidade de mantê-los sempre dentro do mesmo pensamento e cultura adotada e mantida pela empresa, para a descrita Política de Privacidade.

Também é verdade que a integração não apenas entre todos os colaboradores e diretoria, mas também, entre todos os departamentos, como descrevemos em capítulo próprio. Gerará uma espécie de sintonia departamental que será o reflexo dessa interação e dessa difusão da cultura que será implantada e vivida dentro da empresa e que, em resumo, irá refletir o que chamamos de boas práticas de governança que serão no dia a dia, compartilhadas entre os mais diversos setores da empresa.

Outro ponto que consideramos relevante, é pensar que não adianta o documento de Política de Privacidade existir no site da empresa se ele não representar o que

pensa a empresa, já que a empresa é formada por pessoas e se essas pessoas não cumprem com as diretrizes determinadas na política interna da empresa, isso não poderá ser exigido da outra parte que são os clientes.

E de igual modo, o comprometimento com a segurança, privacidade e proteção dos dados não terá sentido dentro do programa interno da empresa. Ou seja, se aquela mensagem que a empresa manda aos clientes não chegar antes aos colaboradores da ponta, também os clientes nunca estarão seguros e tranquilos se não houve segurança quando do compartilhamento dos seus dados, quando da confiança do fornecimento dos seus dados à uma empresa.

Não há dúvidas de que, nessa nova era, os dados são, como já mencionamos anteriormente, o novo petróleo, dada a sua importância para as empresas. E nesse sentido, considerando a importância dos dados que lhes são confiados, devem as empresas, cada vez, investir em tecnologias e segurança para evitar ou minimizar ao máximo, quaisquer situações que coloquem em risco ou que gerem impactos decorrentes dos chamados ciberataques, cibercrimes.

Dessa maneira, conclui-se que, as empresas atualmente, trabalham incansavelmente, para criar Políticas de Privacidade que são, como explicitado, cada vez mais, programas internos de garantia de privacidade e proteção dos dados, para além da simples ideia de um documento apenas, intitulado de Política de Privacidade. Esse é o entendimento, esse é o ponto relevante que deve ser entendido e absorvido pelas empresas de acordo com a implementação da LGPD, consideradas as exigências trazidas como finalidade de proteger os dados pessoais das pessoas.

■

CAPÍTULO VI COMO FICAM O TELEMARKETING E O E-MAIL MARKETING?

■

Como já discorre-se aqui e nunca é demais lembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/18, que começou a vigorar no dia 18 de setembro de 2020, disciplina e define as categorias de dados, para quem vale as regras, fixa as hipóteses de coleta e tratamento de dados, traz os direitos dos titulares de dados, detalha condições especiais para dados sensíveis e segmentos (como de crianças e adolescentes), estabelece obrigações às empresas, institui um regime diferenciado para o Poder Público, aplica sanções em caso de violações e previu a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), já devidamente estruturada - que é o órgão responsável por regular a Lei, elaborar instruções para o cumprimento de suas normas, com capacidade de zelar e fiscalizar o seu cumprimento.

Dessa forma, qualquer empresa que incluir em sua base de dados, informações de seus clientes, por mais básicas que sejam, estão sujeitas à aplicação da LGPD, em razão do tratamento de dados que ocorre a partir desses dados armazenados.

Importa dizer que, algumas empresas, em especial, precisam ficar alertas, em razão do impacto direto em suas atividades. Nesse caso, podemos citar, como exemplo, as empresas que atuam na área de eventos, as empresas de telemarketing, aquelas que se ocupam da utilização de e-mail marketing, seja para captação de clientes, para venda de produtos ou mesmo para notificações em geral.

Há que se considerar, dentre outras coisas, a existência de uma categoria, aquela dos “dados sensíveis”, que como já explicitado anteriormente, registros como

esses, passaram a ter um nível maior de proteção, para evitar, por exemplo, discriminação. São dados que se registram, a rigor, a origem racial ou étnica de pessoas, suas convicções religiosas ou filosóficas, também opiniões políticas, além de filiação sindical e questões genéticas, biométricas, também podem revelar informações sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.

Por outro lado, é importante relembrar, que considerando os fatos que motivaram a criação da lei (tanto a lei europeia quanto a brasileira), e nunca é demais mencionar, que essa motivação para a criação das leis, muito embora já se discutia a necessidade de uma proteção legal para os dados pessoais, mas se deram a partir de um grande vazamento de informações ocorrida de forma autorizada pelo Facebook à Cambridge Analytica (uma empresa norte americana) que coletou dados de forma “inadequada” do FACEBOOK¹⁹ de cerca de mais de 87 (oitenta e sete) milhões de usuários.

Esses dados foram utilizados para influenciar a opinião de eleitores em vários países do mundo, inclusive, nos EUA, ajudando políticos a se elegerem. Inclusive, nas eleições de 2016, em que Donald Trump, sagrou-se vencedor. Então, a partir daí, políticos brasileiros decidiram pela criação da Lei, cujo teor segue as diretrizes da lei europeia.

Mas questiona-se: Qual a relação desse fato com o tema em questão?

De forma simples, a correlação está na demonstração que as empresas devem ter, de agora em diante, com as práticas na utilização dos dados massivos que estão em seu poder, como as empresas de telemarketing e de exploração de e-mail marketing, por exemplo.

De início, é muito importante esclarecer, que diferente do que muitas pessoas e empresas pensaram, elas não estão proibidas de exercer suas atividades em razão

da entrada em vigor da Lei, mas estão serão obrigadas a se adequarem ao uso correto dos dados que estão em seu poder e que nunca é demais esclarecer, esses dados contidos nos bancos de dados das empresas não lhe pertencem, eles pertencem aos titulares dos dados (funcionários e consumidores) e exatamente por isso, as empresas de agora em diante, precisam do consentimento destes para que seus dados possam ser utilizados e exatamente por isso, tratar desse tema é importante aqui.

Muito se pensou, quando do anúncio da publicação da LGPD, que todas as empresas que detinham cadastro de clientes, de comercialização de e-mail marketing e telemarketing, poderiam encerrar suas atividades por conta da Lei.

A grande verdade é que, todas as empresas de telemarketing, as empresas de envio massivo de e-mail marketing, precisam redobrar seus cuidados com as atividades que desenvolvem, pois se estas são baseadas, eminentemente, na utilização de bancos de dados, cuja autorização, em sua grande maioria, não foi consentida pelos titulares dos dados. Por isso, repita-se, não podem ser tratados sem a devida autorização, devem, portanto, estas empresas, se adequarem, pois do contrário, correm sim, os riscos de terem suas atividades encerradas, em razão do rigor da Lei para esses casos de utilização indevida de dados pessoais.

Assim, diante da necessidade de garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados do cliente, usuário, ou seja, do titular dos dados, as empresas deverão proceder com a adequação correta às regras da LGPD, para que, no mínimo, o consentimento lhe seja permitido, possibilitando assim, que estas empresas possam explorar suas atividades.

Até então, muitas empresas, operavam de forma ilegal, pois muitas delas sequer, informavam a origem dos dados “compartilhados” e que eram utilizados para realizar os contatos com os pretensos “clientes” e, dessa forma, totalmente indevida a utilização destes dados.

A partir da entrada em vigor da Lei, esse cuidado, em que pese não parecer tão importante até aqui, possui sim, a ser de grande importância, pois do contrário, os dados serão utilizados de forma ilegal. Portanto, as empresas de telemarketing e de e-mail marketing operarão de forma inadequada e passíveis de aplicação das sanções pela ANPD e mesmo de ações judiciais por parte dos consumidores/titulares dos dados.

A aquele temor do início, tratou-se de um engano, pois todo esse trabalho das empresas de telemarketing e e-mail marketing, ainda será possível.

Com base na própria LGPD, estas empresas, os departamentos de marketing das empresas, poderão, sob o fundamento da BASE LEGAL -que em muitos casos será o legítimo interesse -, poderão continuar com suas atividades, desde que devidamente adequadas às regras da LGPD.

Aqui cabe um parêntese para explicar novamente (O que é o legítimo interesse?). É, em resumo, a possibilidade que a empresa tem, na condição de controladora, de justificar o uso do dado sem o consentimento do titular, baseado na sua atividade e justificada a finalidade.

Frise-se que é muito importante esclarecer que para que isso ocorra, essas atividades não podem violar os direitos e as liberdades fundamentais do titular de dados e, como dito, tenham finalidades em um tratamento justificável.

Por fim, para que o legítimo interesse nesses casos, seja válido, deverão ser realizadas diversas análises, a partir de situações concretas, como por exemplo:

- a) Deve, comprovadamente, dar apoio e promoção de suas atividades;
- b) Deve alinhar-se à proteção de direitos, em relação ao titular dos dados;
- c) Deve, a prestação de serviços demonstrar que beneficiem o titular dos dados, por exemplo.

Via de regra, o cuidado que deve ser tomado aqui é que, essa empresa que enviou o e-mail, por exemplo, ao ser solicitada a retirada do seu e-mail do cadastro pelo titular dos dados, deverá fazê-lo, imediatamente.

Isso, com base no direito à Autodeterminação Informativa que nada mais é do que, o direito de saber o que está sendo feito com seus dados, podendo por tanto, requerer a exclusão, a alteração ou até mesmo a anonimização.

Ah! Então o cuidado maior é esse?

Não, claro que não, o maior cuidado ainda deve ser com a proteção desses dados para evitar que haja um vazamento ou compartilhamento e conseqüentemente, o uso indevido desses dados. Pois em sendo identificada a fonte do vazamento ou o uso indevido dos dados, esse ato será passível de penalidade, quer por meio de sanções administrativas, quer por meio de ações judiciais.

Ao que se pergunta: Como devem ser adequados os CallCenters das empresas de telemarketing?

Esse é um cuidado que passou a ser imprescindível, para todas as empresas de telemarketing, visto que o cuidado com os dados pessoais deve fazer parte da realidade das empresas e, isso, principalmente, porque há o risco constante de exposição dos dados pessoais no atendimento, durante as várias etapas do desenvolvimento do atendimento ao cliente.

Não se pode esquecer que a LGPD tem como maior beneficiário o titular dos dados, muito embora, diversas empresas ainda não tenham se adequado.

A necessidade de adequação desse segmento de empresas se dá principalmente, porque a maioria dos titulares de dados, se sentem inseguros quanto a utilização de seus dados pelas empresas e, mais ainda, pelo elevado número de ligações que são recebidas diariamente, sem autorização prévia para que seus dados constem do banco de dados dessas empresas que realizam os contatos de forma insistente.

Não há dúvida alguma quanto ao fato de que a LGPD está impactando no setor das empresas de telemarketing e aquelas que se utilizam de e-mail marketing, isso porque essas empresas realizam diariamente a coleta de dados e esse tratamento de dados, em muitos casos, ocorre, inclusive, com dados sensíveis.

Como dito anteriormente, não há proibição por parte da Lei para que as empresas operem com os dados dos titulares, mas todas essas empresas precisarão, de agora em diante, em razão desta autorização para coleta e tratamento destas informações/dados, serem totalmente transparentes sobre a finalidade específica aplicada ao uso dos dados e informar se haverá ou não compartilhamento dos dados com empresas parceiras.

Daí se extrai a necessidade da prática de uma comunicação sempre muito clara com o titular de dados, explicando detalhadamente, qual será o uso, a finalidade,

que será atribuída aos dados pessoais dele e, essa utilização se dará somente, mediante seu consentimento; do contrário, o uso dos dados será indevido.

Assim, para que as empresas se adequem a LGPD é preciso regular seus sistemas de preenchimento de cadastro e uso dos dados, conforme determina a LGPD, baseando-se no consentimento para o uso de dados e informações.

Além disso, é necessária uma avaliação por parte das empresas, quanto aos aspectos jurídicos decorrentes da utilização de informações pessoais, para que, tanto os sistemas de informações, quanto os aspectos jurídicos, estejam em conformidade com a lei.

Veja-se que, as regras valem tanto para as empresas de telemarketing, quanto para as empresas de e-mail marketing.

Nesse sentido, retorna-se ao teor da necessidade de preparação e treinamento de conscientização de toda a equipe, quanto às exigências da LGPD. É necessário revisitar os treinamentos de tempos em tempos, em todas as empresas, em todos os departamentos, para todos os colaboradores, a fim de que estes não percam de vista, os rigores da Lei e os riscos decorrentes do descumprimento do que está estabelecido pela LGPD.

Mas, especialmente, as empresas de telemarketing e de e-mail marketing, devem, a partir da entrada em vigor da Lei, buscar sua adequação adotando algumas medidas básicas, para além daquelas estabelecidas pela Lei, como por exemplo:

A empresa, ao ter solicitada pelo cliente, a exclusão de suas informações, deverá

proceder com a exclusão dos dados, visto que isso demonstrará para todos os colaboradores, que a empresa está cumprindo com o que determina a Lei e essa cultura será difundida e acatada por todos. Isso, porque além demonstrar que está cumprindo a Lei, a empresa demonstra que respeita a decisão do consumidor e isso, por si só, já passará confiança e credibilidade ao consumidor. Essa prática também ajuda a melhorar a experiência do consumidor e ajuda a fortalecer o relacionamento entre a empresa e o usuário dos serviços, o consumidor, o titular dos dados.

Lembrando por fim, que o consumidor, com a entrada em vigor da Lei, está na condição de titular dos dados e, portanto, tem autonomia e propriedade sobre seus dados e sem sua autorização, o processo de tratamento de dados é inválido. Contudo, nada adianta para a empresa o tratamento irregular dos dados.

A empresa, deve buscar contar e capacitar sua equipe, mantendo-a atualizada quanto ao que determina a LGPD, pois dessa forma, minimizará os riscos de existência de problemas decorrentes do descumprimento das regras da LGPD e, consequentemente, evitará os riscos de aplicação das penalidades.

É muito importante que os profissionais da empresa conheçam todos os aspectos legais, decorrentes das determinações da LGPD e isso, não deve ser apenas na teoria, mas especialmente, na prática, tendo em vista que a LGPD não atua apenas no campo da teoria, mas em especial, é a parte prática que de fato, irá dizer sobre a verdadeira adequação da empresa.

Como esclarecido acima, os treinamentos constantes, devem fazer parte da atualização dos colaboradores, porém, não é esse o único aspecto, pois dessa maneira, eles passam a se sentir cada vez mais seguros e motivados a apresentar resultados que refletirão no melhor atendimento dos regramentos determinados pela Lei.

Outro ponto a ser considerado é que, ultimamente, dentro de uma empresa de telemarketing, existem muitos processos que estão sendo automatizados, pela chamada digitalização dos processos, por meio das mais diversas plataformas, que prometem trazer resultados específicos para o tipo de atendimento que normalmente já são prestados. Qual é o ponto de vantagem aqui? Uma maior precisão na utilização dos dados e uma chance infinitamente menor de haver o cometimento de erros de coleta e tratamento de dados, esse processo de automação, portanto, é um caminho sem volta, pois trouxe diversos benefícios às empresas, conforme demonstrado acima.

Dentre esses benefícios temos como exemplo, a possibilidade de gravação de voz durante as chamadas, pois dessa forma, o registro ocorre de maneira mais segura e, porque não dizer, mais eficiente.

Além disso, deve a empresa, se ocupar de utilizar-se, por exemplo, de sistemas que possam monitorar sua estrutura de TIC²⁰. Dessa forma, a empresa terá como antecipar a problemas e ter acesso a levantamentos e estatísticas que tornará mais eficiente o seu dia a dia.

O fato é que, as empresas de telemarketing, tal qual as empresas de e-mail marketing, tiveram que buscar uma espécie de aprimoramento, para adequarem-se às regras trazidas pela LGPD. Nesse sentido, muitas buscaram implementar plataformas que realizam de forma completa o tratamento de dados, como forma de estarem minimamente adequadas à LGPD, retornando para si, melhores resultados no atendimento e uma significativa redução dos riscos no tratamento dos dados.

[19 Atualmente o Facebook possui o nome de Meta.](#)

20 TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação - É descrito de forma simples, como sendo um conjunto de tecnologias que permitem a comunicação entre as pessoas.

PARTE III

■

FISCALIZAÇÕES E SANÇÕES

CAPÍTULO I QUAL O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) definiu que Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão da Administração Pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei. Para melhor entender sobre essas responsabilidades, é necessário discorrer sobre alguns pontos interessantes, o que ora passamos a fazer.

Como já discorremos anteriormente e, nunca é demais lembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), criada em 14 de agosto de 2018, começou a vigorar em 18 de setembro de 2020, tratou de disciplinar e definir: as categorias de dados, definir para quem valeriam as regras, fixou as hipóteses de coleta e tratamento de dados, trouxe estabelecidos os direitos dos titulares de dados, detalhou as condições especiais para o tratamento de dados e de dados sensíveis e segmentos (como de crianças e adolescentes), estabeleceu obrigações às empresas, instituiu um regime diferenciado para o Poder Público, definindo a aplicação das sanções para os casos de violações e, previu a criação da ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que atualmente, já consta como devidamente estruturada, sendo o órgão responsável por regular a Lei, elaborar instruções para o cumprimento de suas normas, com capacidade de zelar e fiscalizar o cumprimento da Lei.

Vale lembrar que a ANPD não foi originalmente criada pela LGPD – Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e que, somente foi criada pela Lei nº 13.853 de julho de 2019, que dispôs sobre a proteção de dados pessoais e então criou a ANPD, que trouxe consigo, algumas alterações na própria LGPD.

A LGPD definiu que a ANPD seria um órgão da Administração Pública, que ficaria responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei, conforme dispôs o Art. 5º, Inciso XIX. Veja-se:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) (BRASIL, 2018).

O fato é que, posteriormente, o Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020²¹ aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e remanejou e transformou cargos em comissão e funções de confiança.

Outro fato muito importante a se dizer, é que inicialmente e durante algum tempo, a ANPD esteve diretamente ligada ao Poder Executivo, mas que, posteriormente, ganhou autonomia, para além da técnica.

Em 14 de junho de 2022, foi publicada a Medida Provisória nº 1.124/22, que alterou a LGPD e transformou a ANPD em Autarquia, uma autarquia especial, que passou a ter autonomia e patrimônio próprios.

Veja-se que a LGPD, Lei nº 13.709/18 estabeleceu em seu Art. 55º, a

necessidade de criação futura da Lei (que como dito, mais tarde foi criada pela Lei nº 13.853/19), o referido Art. 55º foi revogado e deu lugar ao art. 55-A. Nesse Art., estabelecido pela Medida Provisória 869/18, foi revogado que:

Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República. (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018).

Dando lugar a um novo Art. 55-A, trazido pela Medida Provisória nº 1.124/2022, que assim dispõe:

Art. 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)

Portanto, aquela autonomia, que antes era apenas técnica, conforme antes dispunha o Art. 55-B:

Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica à ANPD. (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018).

Passou a ser também, autonomia decisória e passou a contar com patrimônio próprio, com sede e foro no Distrito Federal.

Considera-se relevante também, esclarecer como foi criada a estrutura da ANPD,

nos termos da lei e a isso, ocupa-se a explicar:

A Lei 13.709/18 - LGPD, em seu artigo 55-C, dispõe sobre como é a composição da ANPD, e nele, tem-se de forma clara que sua composição se dará da seguinte maneira:

- 1) Por meio do Conselho Diretor, que é considerado o órgão máximo de direção da ANPD;
- 2) Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
- 3) Da Corregedoria;
- 4) Da ouvidoria;
- 5) Da Procuradoria;
- 6) De Unidades Administrativas;
- 7) Além das Unidades especializadas, que a lei considerou como necessárias para a aplicação da lei.

Veja-se o que dispõe o Art. 55-C:

Art. 55-C. A ANPD é composta de: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019).

I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

III - Corregedoria; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IV - Ouvidoria; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

V - Procuradoria; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.124, de 2022)

VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Descrita como é a estrutura da ANPD, cabe-se dizer como são compostos os conselhos:

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea 'f' do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois), de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019).

Esclarecidas as questões relativas à criação, autonomia e mesmo à questão da formação da estrutura da ANPD, passa-se a tratar de algumas questões que se entende serem muito pertinentes.

A exemplo disso, considera-se importante dizer, que de início, muito se duvidou da possibilidade de que a LGPD iria realmente “pegar” como Lei, pois acreditava-se que a composição dos Conselhos da ANPD, por estar ligada ao Poder Executivo, sua composição ocorreria com interferências políticas, por meio de pessoas, que seriam indicadas para ocuparem os cargos destes conselhos, sem a observância mínima de capacidade técnica, como ocorrem em diversas Autarquias, Ministérios, Secretarias e diversos outros órgãos governamentais.

Especialmente, porque no parágrafo 1º, do Art. 55º, da Lei, foi concedido ao Presidente da República, o poder de escolha e nomeação com a consequente aprovação pelo Senado Federal:

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

O fato é que o mercado como um todo foi surpreendido positivamente, e os Conselhos da ANPD, foram formados por especialistas, com conhecimentos técnicos relevantes, e muitos destes conselheiros são tão capacitados, que alguns chegaram a participar da elaboração do projeto de criação da Lei. Portanto, não se confirmou aquela desconfiança sobre a possibilidade de interferências políticas e fragilização da autonomia, autonomia esta, que mais tarde veio a ser confirmada e ampliada, por meio da própria Medida Provisória nº 1.124/22, transformou a ANPD em autarquia especial e que passou a ter autonomia e patrimônio próprios.

Sabe-se que coube a ANPD a capacidade de zelar e fiscalizar o cumprimento da Lei e sobre essa capacidade de zelar, tem-se que algumas providências precisam ser adotadas e nesse sentido, a fiscalização é uma delas. Sobre a qual

debruçamos doravante.

No uso de suas atribuições, por meio do Conselho Diretor da ANPD, aprovou em 28 de outubro de 2021, a Resolução CP/ANPD nº 01, que regulamentou o processo de fiscalização, além do processo administrativo sancionador, no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O fato é que, o referido conselho, exercendo tais competências normativas, fiscalizatórias e sancionatórias, que foram instituídas pelo Art. 55-J, inciso IV, §2º da Lei nº 13.709/18, aprovou o regulamento do processo de fiscalização e em seu Art. 70º, estabeleceu que as fiscalizações teriam início a partir de janeiro de 2022. Veja-se:

Art. 70. O primeiro ciclo de monitoramento terá início a partir de janeiro de 2022.

Vale observar, que muito embora o artigo faça menção ao termo monitoramento, mas em verdade, está se falando do início efetivo das fiscalizações.

E, como não poderia ser diferente, a LGPD, estabeleceu que, dentro das competências da ANPD, a aplicação das sanções que, geralmente, são a maior preocupação por parte das empresas.

O fato é que a Lei foi criada em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, portanto, as empresas tiveram mais de 02 (dois) anos para se adequar.

As sanções passaram a vigorar desde 01 de agosto de 2021 e as fiscalizações, previstas para terem início a partir de janeiro de 2022, segundo constou da Resolução 01/21 da ANPD, datada de 28 de outubro de 2021 e, publicada no Diário Oficial de União, em 29 de outubro de 2021.

Dentro do processo de fiscalização, quando encontradas irregularidades, as empresas poderão sofrer as chamadas sanções administrativas, que possuem, de acordo com a lei, uma gradação que ocorrem, de acordo com o que está descrito no Art. 52, da Lei, da seguinte forma:

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: (Vigência)

No inciso I, está prevista a aplicação de advertência:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

[...]

No inciso II, está prevista a aplicação de multa:

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

[...]

Muito embora, particularmente, entenda que a maior penalidade está diretamente ligada ao fato de que, a suspensão do direito de tratar dados é uma penalidade mais gravosa, pois impede que a empresa trate dados até que esteja solucionada a irregularidade da adequação e que pela lei, pode ser de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

[...]

Veja-se como exemplo a impossibilidade que a empresa terá de emitir boletos para cobrança de seus serviços, pelo prazo acima, até que seja regularizada a situação da adequação.

Dessa forma, restou claro, que as multas são relativamente penosas caso não haja a devida proteção aos dados pessoais e a ANPD deverá observar os mecanismos

e procedimentos internos adotados preventivamente pela empresa, e a implementação de boas práticas de governança.

Isso certamente será um diferencial de mercado – seletividade dos clientes e empresas operadoras e que fará com que as empresas se perguntem: se custa caro fazer a implementação e concluirão que, definitivamente NÃO, não custa caro. Muito mais caro poderá ser o dano à imagem da empresa e a rejeição do mercado (consumidores e fornecedores – pela não adequação).

A ANPD é, portanto, o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei.

21 Decreto nº 10.474. Fonte: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.474-de-26-de-agosto-de-2020-274389226>>. Acesso em 21/07/22 às 07h:52min.

■

CAPÍTULO II COMO A FISCALIZAÇÃO ACONTECE?

■

Das Definições:

Definida a questão de quem é o órgão responsável pela fiscalização imposta pela LGPD para os casos de descumprimento das regras para o tratamento de dados, tem-se a necessidade de esclarecer e demonstrar, como acontecerá a fiscalização que será conduzida pela ANPD.

Considera-se necessário esclarecer, que diante da entrada em vigor da Lei, o órgão passa a ter a função primeira, de regular e de orientar preventivamente, todas empresas sobre como serão aplicadas as sanções impostas pela Lei.

Dos Conselhos da ANPD:

Importa-se dizer, como já foi mencionado anteriormente, que o Conselho Diretor da ANPD, no uso de suas atribuições, aprovou por meio da Resolução nº 01 - Regulamento do Processo de Fiscalização e Processo Administrativo Sancionador, que ocorreu em 28 de outubro de 2021, portanto, o processo de fiscalização já está valendo desde janeiro de 2022, bem como, o processo administrativo sancionador, no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção

de Dados, na forma do Anexo a esta Resolução.

Da Entrada em Vigor da Lei:

A resolução entrou em vigor na data de sua publicação, a saber, 29 de outubro de 2021, portanto, já está valendo desde esta data.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Do Processo de Fiscalização e seus Objetivos:

Assim, a ANPD, por meio da Resolução 01, estabeleceu que, sua atuação, no processo de fiscalização, será sempre para a proteção dos direitos dos titulares de dados, conforme dispõe o Art. 3º, da mencionada Resolução 01. Veja-se:

Art. 3º A ANPD atuará para a proteção dos direitos dos titulares de dados, para promover a implementação da legislação de proteção de dados pessoais, e para zelar pelo seu cumprimento.

O procedimento inicial, que visa, em síntese, determinar um padrão e tornar transparente a maneira como será o processo de fiscalização, conta com a regulação dos procedimentos internos e dos conselhos. Além disso regula sobre os procedimentos que visam orientar todas as empresas, quer públicas ou privadas que realizam o tratamento de dados pessoais, prevenindo e reprimindo os casos em que haja a possibilidade de infrações, além é claro, de orientar também os titulares de dados.

Aqui, cabe justificar que, o número de empresas que já conseguiram se adequar às exigências da lei é consideravelmente baixo, segundo pesquisa realizada pela LGPD no Mercado Brasileiro e divulgada no site Migalhas.com:

[...] Ainda são poucas as empresas que dizem estar com 100% em conformidade com a LGPD. Essa é uma das conclusões da pesquisa “LGPD no Mercado Brasileiro”. O levantamento, que escutou 366 empresas, gerou um e-book com mapeamento do nível de maturidade das companhias de diferentes segmentos em relação à adaptação à nova lei, bem como seus principais desafios²².

Nesse sentido, fazendo uso do que está disposto como sendo o exercício do poder fiscalizatório da ANPD, o órgão pode:

- a) Notificar as empresas, em caso de descumprimento das regras relativas ao correto tratamento de dados pessoais;
- b) Pode realizar auditorias nas empresas, quer na condição de controladoras (aquelas que detém o poder de decisão sobre o tratamento de dados), quer na condição operadoras (ou seja, aquelas empresas que tratam dados em nome da controladora);
- c) Pode ainda, requerer a apresentação de cópias e documentos necessários para desenvolver a fiscalização, quer sejam por meio físicos ou digitais, que contenham informações ou dados que apresentem relevância ao objeto da fiscalização, para que desse modo, seja possível avaliar tanto as atividades do tratamento de dados, quanto à finalidade a que se propõe este tratamento de dados.

Vale dizer, que de início, as fiscalizações poderão ocorrer provocadas a partir de algumas modalidades.

Por meio de denúncias, que podem ser feitas por qualquer pessoa, natural ou jurídica, desde que não seja o próprio titular dos dados.

Nesse caso, a Resolução 01, em seu Art. 4º, Inciso III, tratou de definir como sendo:

III - denúncia: comunicação feita à ANPD por qualquer pessoa, natural ou jurídica, de suposta infração cometida contra a legislação de proteção de dados pessoais do País, que não seja uma petição de titular;

[...]

Por meio de petição eletrônica. Nesse caso, por parte dos titulares de dados ou pessoas interessadas, decorrentes de fatos graves que ganhem notoriedade e que afetem direta ou indiretamente, a vida dos titulares dos dados.

No mesmo artigo 4º, mas no inciso V, sobre a petição de titular:

V - petição de titular: comunicação feita à ANPD pelo titular de dados pessoais de uma solicitação apresentada ao controlador e não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação, nos termos do inciso V do art. 55-J da LGPD; e

[...]

Por meio de comunicações por parte das próprias empresas, em caso de ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar riscos ou danos relevantes aos titulares de dados.

Importa dizer que, em se tratando de incidentes, com informações e ou dados, nem todo incidente será considerado vazamento de dados, mas todo vazamento de dados será considerado um incidente.

Incidente pode ser qualquer fato que ocorra com os dados de forma não planejada, mas não necessariamente ocorrerá o vazamento dos dados, mas por outro lado, ocorrendo o vazamento, logo, esse vazamento será um incidente.

Veja-se que a modalidade de requerimento é um misto de um conjunto de comunicações que em síntese, representam, segundo a Lei, tanto a denúncia quanto a petição do titular.

VI - requerimento: conjunto de tipos de comunicação, compreendendo a petição de titular e a denúncia.

Importante esclarecer, que o titular de dados, antes de registrar uma denúncia, por meio de petição, deve, obrigatoriamente, informar a empresa supostamente, infratora, sobre o incidente, buscar esclarecimentos e exigir providências, nos casos em que haja confirmação do vazamento e, somente posterior a esse registro de solicitação poderá realizar a denúncia, por meio de petição eletrônica, perante a ANPD.

Dessa maneira, as denúncias e petições de titulares, sobre as infrações à LGPD, que decorram de descumprimento da Lei, devem ocorrer por meio de petições, que serão protocoladas eletronicamente, diretamente no sistema do órgão, por meio da plataforma do governo, intitulada SEI - Sistema Eletrônico de Informações²³.

Para registro da denúncia, esta deverá ocorrer por meio de protocolo eletrônico, com a identificação de que se trata de uma denúncia relacionada à LGPD, como por exemplo, COMUNICAÇÃO DE DENÚNCIA LGPD, DENÚNCIA POR INFRAÇÃO À LGPD, LGPD DENÚNCIA etc.

Outro ponto a ser esclarecido é que, nos casos de comunicações de ocorrências ocasionadas por incidentes de segurança nas empresas e que, segundo a LGPD, deverão ser comunicados à ANPD imediatamente, estão dispostos no Art. 48º, da LGPD. Veja-se:

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

A Lei nesse mesmo Art. 48, em seus parágrafos e incisos estabelece, que as comunicações devem ocorrer em prazo razoável²⁴ e deve constar, obrigatoriamente:

§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo:

I. uma descrição da natureza dos fatos;

II. as informações sobre os titulares de dados envolvidos no vazamento de dados;

III. a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

IV. os riscos relacionados ao incidente;

V. os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata, e;

VI. as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

Além disso, outro fato bem importante e que pode trazer repercussões que impactem na “vida” e na imagem da empresa, é a possibilidade de avaliação se o incidente apresenta gravidade ou não. Assim ocorrendo, a empresa deverá seguir dois passos que possuem relevância e impactam diretamente na imagem da empresa, mas que buscam proteger os interesses dos titulares dos dados, veja-se o que dispõe o art. 48, parágrafo 2º da LGPD:

§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como:

I - ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e

II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

Pode-se observar que, ocorrendo a comunicação e sendo detectada por parte da ANPD, que o fato ocorrido conta com gravidade no incidente, o órgão poderá requerer uma salvaguarda aos direitos dos titulares dos dados, determinando medidas em que haja uma ampla divulgação do fato, em meios de comunicação e medidas para tentar reverter ou mitigar os efeitos do incidente ocorrido.

Por outro lado, definidas as formas de provocação da ANPD em casos de incidentes, quer por meio de denúncias, por meio de petições, quer por meio de comunicações. Há que considerar, o outro lado, ou melhor dizendo, a outra parte a quem são endereçadas as comunicações, e nesse caso, estamos falando do órgão responsável pela fiscalização das infrações à LGPD.

Muito embora, se mencione a possibilidade de denúncias, petições eletrônicas e comunicados, a ANPD, poderá, de ofício, iniciar um processo de fiscalização, é o que diz, por exemplo, o Inciso I, do Art. 16, da Resolução 01. Veja-se:

Art. 16. No exercício de sua competência fiscalizatória, a ANPD poderá atuar:

I - de ofício;

[...]

Da Intimação:

Assim, considerando as ações que deverão ocorrer por parte da ANPD, para que se inicie uma fiscalização, tem-se que o procedimento se iniciará com uma INTIMAÇÃO, que funcionará como sendo uma espécie de comunicação entre a ANPD e a empresa regulada, empresa supostamente infratora.

Nesse sentido, fazendo uso do que está disposto como sendo o exercício do poder fiscalizatório da ANPD, enquanto órgão fiscalizador, que deverá, segundo o Art. 10º, intimar as empresas:

Art. 10. Os atos administrativos serão comunicados por intermédio de intimação, nos termos do art. 12 deste Regulamento, que deverá conter:

I - a identificação do intimado;

II - a finalidade da intimação e a informação de continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

III - a data, a hora e o local, ou o prazo para tomada da providência, quando houver;

IV - a informação se o intimado deve comparecer pessoalmente, fazer-se representar, manifestar-se ou apresentar defesa ou recurso no processo ou, ainda, cumprir diligência; e

V - a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

Como Proceder em caso de intimação:

A partir disso, obrigatoriamente, pergunta-se: Sendo minha empresa intimada pela ANPD, o que devo fazer?

Deve a empresa, inicialmente, reunir todas as pessoas do seu time que possam de alguma maneira ter conhecimento ou que possam contribuir com o levantamento de todas as informações possíveis sobre o incidente, e verificar quais os procedimentos internos devem ser adotados para levantar todas as evidências que deram causa à denúncia, que por sua vez levou à intimação.

Após a realização de um levantamento minucioso por meio de uma coleta de todos os dados impactados, por meio de documentos e, a empresa deve observar dois caminhos:

- 1) Se a empresa já passou por um processo de adequação/implementação às regras da LGPD;
- 2) Se a empresa ainda não passou por um processo de adequação/implementação às regras da LGPD.

Em caso positivo, ou seja, estando a empresa adequada às regras decorrentes da implementação à LGPD. Após a verificação ou análise, por meio da realização interna de testes dos procedimentos implementados, a detecção por meio de

Relatórios de Incidentes e ou Relatório de Impacto, o chamado Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), indispensável para as empresas já adequadas.

Em caso negativo, ou seja, não estando a empresa adequada às regras decorrentes da implementação à LGPD, deverá, ato contínuo, buscar uma consultoria especializada em adequação de empresas à LGPD para que possa fazer os levantamentos internos de conformidade e realizar as demais investigações que sejam necessárias para apontar o nível de desconformidade, por meio de questionários, diagnósticos dentro da empresa e, independente da conclusão, deve comunicar a ANPD, todos os detalhes de forma minuciosa sobre o incidente, de acordo e obedecendo os prazos estabelecidos na Lei.

Por fim, se realmente houve a detecção de falhas no processo interno de adequação da empresa, que levou a ocorrência do incidente, será necessária a adoção de todas as medidas de contenção ao incidente. Além, é claro, de prestar todas essas informações à ANPD, conforme descrito acima.

Veja-se que é muito importante pensar que estando a empresa devidamente adequada, os impactos decorrentes de eventual vazamento de dados, para os casos em que a empresa está adequada são infinitamente menores, do que os casos em que a empresa não está adequada.

Além disso, quando a empresa não está adequada, ela precisará “correr” atrás das providências para estar em conformidade, e isso, de uma hora para outra é quase impossível, pois o processo de adequação não ocorre da noite para o dia, mas pode levar meses. Fator que pode impactar em aplicação, por parte da Autoridade Nacional, de sanções que certamente afetarão demais a empresa, para além dos danos financeiros, os danos comerciais e de imagem, conforme já descritos anteriormente.

Outro ponto importante é que, estando a empresa devidamente adequada, a própria equipe, por meio de treinamentos de conscientização, adoção de medidas de segurança, quer no âmbito da área de tecnologia e sistemas de informação, quer no âmbito jurídico, certamente evitará os danos e prejuízos financeiros e, também evitar prejuízos que poderiam ser causados à imagem e à reputação da empresa.

Dos Deveres das Empresas:

A ANPD, estabelece no Art. 5º, da Resolução 01, que as empresas controladoras ou operadores, que na Resolução 01, são chamadas de agentes regulados, estão sujeitas às fiscalizações e devem cumprir com os deveres nela apontados. Veja-se:

Art. 5º Os agentes regulados submetem-se à fiscalização da ANPD e têm os seguintes deveres, dentre outros:

I - fornecer cópia de documentos, físicos ou digitais, dados e informações relevantes para a avaliação das atividades de tratamento de dados pessoais, no prazo, local, formato e demais condições estabelecidas pela ANPD;

II - permitir o acesso às instalações, equipamentos, aplicativos, facilidades, sistemas, ferramentas e recursos tecnológicos, documentos, dados e informações de natureza técnica, operacional e outras relevantes para a avaliação das atividades de tratamento de dados pessoais, em seu poder ou em poder de terceiros;

III - possibilitar que a ANPD tenha conhecimento dos sistemas de informação utilizados para tratamento de dados e informações, bem como de sua rastreabilidade, atualização e substituição, disponibilizando os dados e as informações oriundos destes instrumentos;

IV - submeter-se a auditorias realizadas ou determinadas pela ANPD;

V - manter os documentos físicos ou digitais, os dados e as informações durante os prazos estabelecidos na legislação e em regulamentação específica, bem como durante todo o prazo de tramitação de processos administrativos nos quais sejam necessários; e

VI - disponibilizar, sempre que requisitado, representante apto a oferecer suporte à atuação da ANPD, com conhecimento e autonomia para prestar dados, informações e outros aspectos relativos a seu objeto.

§ 1º Os documentos, dados e as informações requisitados, recebidos, obtidos e acessados pela ANPD nos termos deste Regulamento são aqueles necessários ao exercício efetivo das suas atribuições, bem como aqueles sujeitos às regras de acesso e classificação de sigilo previstas em regulamentação específica.

§ 2º Cabe ao agente regulado solicitar à ANPD o sigilo de informações relativas à sua atividade empresarial, como dados e informações técnicas, econômico-financeiras, contábeis, operacionais, cuja divulgação possa representar violação a segredo comercial ou a industrial.

§ 3º Os documentos apresentados sob a forma digitalizada deverão cumprir os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020.

§ 4º O agente regulado, por intermédio de representante indicado, poderá acompanhar a auditoria da ANPD, ressalvados os casos em que a prévia notificação ou o acompanhamento presencial sejam incompatíveis com a natureza da apuração ou em que o sigilo seja necessário para garantir a sua eficácia.

A Resolução que trata da fiscalização por parte da ANPD, em cumprimento à LGPD, traz, portanto, de forma discriminada, sobre os deveres das empresas, quanto a, por exemplo, obrigação de fornecimento de cópias de documentos, permissão de acesso às instalações para verificação das atividades de tratamento de dados, acesso aos equipamentos e sistemas de informação e realização de auditorias, guarda e manutenção de documentos, disponibilização de representante da empresa (Encarregado/DPO), dentre outros procedimentos que são necessários para a realização do processo fiscalizatório da ANPD.

Mas o fato é que, além disso, ficou estabelecido no Art. 6º, que não havendo o cumprimento das regras impostas pela LGPD, por parte das empresas, quanto aos deveres apontados acima, tais atos serão considerados obstrução à fiscalização. Vejamos:

Art. 6º O não cumprimento dos deveres estabelecidos no art. 5º poderá caracterizar obstrução à atividade de fiscalização, sujeitando o infrator a medidas repressivas, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias com o objetivo de concluir a ação de fiscalização obstruída por parte da ANPD.

A ANPD, estabelece também, nos artigos 7º e 8º, as formas e as regras para contagem de prazos para as intimações.

Há ainda que se pensar que, a ANPD, ainda no processo de fiscalização, descrito na Resolução 01, apresenta 02 (dois) documentos que são considerados importantes:

O primeiro deles é o Relatório de Ciclo de Monitoramento (RCM), que é instrumento de avaliação, de prestação de contas e de planejamento das atividades de fiscalização da ANPD, cuja periodicidade é anual;

O segundo deles é o MTP - Mapa de Temas Prioritários (MTP), que é um documento que irá estabelecer os temas que serão considerados prioritários e que serão levados em conta pela ANPD, para fins de estudo e planejamento das atividades de fiscalização, cuja periodicidade ocorrerá de dois em dois anos.

Art. 19. O Relatório de Ciclo de Monitoramento e o Mapa de Temas Prioritários são instrumentos de monitoramento.

Assim, resta-nos entender que, a ANPD contará com a atividade de monitoramento, que terá como objetivo, o planejamento e o subsídio da atuação de fiscalização com informações relevantes, análise da conformidade, prevenção de práticas irregulares, disseminação da cultura de proteção de dados e correção dessas práticas irregulares, visando minimizar danos ao titular dos dados, segundo estabelece o Art. 18º, da Resolução 01:

Art. 18. A Coordenação-Geral de Fiscalização realizará o monitoramento das atividades de tratamento de dados pessoais, observados os limites previstos nos arts. 3º e 4º da LGPD, com intuito de:

I - planejar e subsidiar a atuação fiscalizatória com informações relevantes;

II - analisar a conformidade dos agentes de tratamento no tocante à proteção de dados pessoais;

III - considerar o risco regulatório em função do comportamento dos agentes de tratamento, de modo a alocar recursos e adotar ações compatíveis com o risco;

IV - prevenir práticas irregulares e fomentar a cultura de proteção de dados pessoais; e

V - atuar na busca da correção de práticas irregulares e da reparação ou minimização de eventuais danos.

Um ponto extremamente relevante, quando se fala do processo de fiscalização é que a ANPD²⁵, antes da aplicação das sanções, poderá promover medidas que visam a orientação, conscientização e educação dos agentes de tratamento de dados pessoais e só após isso, poderão ser aplicadas sanções, é o que dispõe os artigos 27 e 28, da Resolução 01, vejamos:

Art. 27. A ANPD promoverá medidas visando à orientação, à conscientização e à educação dos agentes de tratamento, dos titulares de dados pessoais e dos demais integrantes ou interessados no tratamento de dados pessoais.

Nesse sentido:

Art. 28. As medidas aplicadas ao longo da atividade de orientação não constituem sanção ao agente regulado.

Então, a ANPD, entende que várias são as medidas que constituem “orientação” e não penalidades, como exemplo, aquelas dispostas no art. 29 da Resolução 01. Veja-se:

Art. 29. Constituem medidas de orientação:

I - elaboração e disponibilização de guias de boas práticas e de modelos de documentos para serem utilizados por agentes de tratamento;

II - sugestão aos agentes regulados da realização de treinamentos e cursos;

III - elaboração e disponibilização de ferramentas de autoavaliação de conformidade e de avaliação de riscos a serem utilizadas pelos agentes de tratamento;

IV - reconhecimento e divulgação das regras de boas práticas e de governança; e

V - recomendação de:

a) utilização de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares de seus dados pessoais;

b) implementação de Programa de Governança em Privacidade; e

c) observância de códigos de conduta e de boas práticas estabelecidas por organismos de certificação ou outra entidade responsável.

§ 1º Poderão ser adotadas outras medidas não previstas neste artigo desde que compatíveis com o disposto nos arts. 27 e 28.

§ 2º Os agentes regulados, ou suas associações representativas, poderão sugerir a adoção das medidas de orientação listadas acima, sujeita à avaliação da ANPD.

Das Medidas Preventivas da ANPD:

Ficou a cargo da ANPD, antes de aplicação das sanções, a elaboração de guias de boas práticas e governação e divulgação destes, a elaboração de modelos de documentos para serem utilizados pelas empresas, sugestões de formas para realização de treinamentos de conscientização, disponibilização de ferramentas para avaliações dentro das empresas para a correta identificação de riscos pelos agentes de tratamento de dados, definição, recomendações de padrões técnicos a serem aplicados no controle por parte dos titulares de dados.

E não menos importante, a própria implementação de programas de governança em privacidade, com base em códigos de conduta e boas práticas, por entidades e organismos certificadores, além de outras, ainda não estejam previstas na Resolução, inclusive, aquelas sugeridas pelas próprias empresas, que lógico, estarão sujeitas à avaliação da ANPD.

Dessa maneira, o que se tem aqui é a implementação de medidas que são consideradas preventivas e que buscam de alguma maneira, preparar as empresas para evitarem a ocorrência de dados aos titulares de dados, por meio da implementação da adequação à conformidade das empresas, evitando assim, os riscos aos titulares de dados, decorrentes da ocorrência de incidentes e vazamentos de dados por omissão, conforme disciplina o Art. 30º, da Resolução 01:

Art. 30. A atividade preventiva visa reconduzir o agente de tratamento à plena conformidade ou evitar ou remediar situações que acarretem risco ou dano aos titulares de dados pessoais.

O fato é que, como dito anteriormente, essas medidas não são consideradas penalidades, mas sim, medidas preventivas, que visam preparar as empresas para evitar a aplicação das sanções, para o que está inserido no processo de fiscalização da ANPD:

Art. 31. As medidas aplicadas pela Coordenação-Geral de Fiscalização ao longo da atividade preventiva não constituem sanção ao agente regulado.

Mas a ANPD tratou de discriminar, quais são as medidas que podem, a princípio, serem consideradas medidas preventivas e o fez por meio do Art. 32º da Resolução 01:

Art. 32. São consideradas medidas preventivas:

I - divulgação de informações;

II - aviso;

III - solicitação de regularização ou informe; e

IV - plano de conformidade.

Parágrafo único. Poderão ser adotadas outras medidas não previstas neste artigo, se compatíveis com o disposto nos arts. 30 e 31.

Importante observar que, o parágrafo único deixa claro que as medidas descritas não são um rol taxativo, ou seja, uma relação definitiva e limitada. Mas sim apenas uma relação exemplificativa, que poderão serem adotadas outras medidas preventivas, desde que elas sejam compatíveis com as medidas descritas nos artigos 30 e 31, mencionados acima.

Das Medidas Repressivas da ANPD:

Além das medidas preventivas adotadas, ficou à cargo da ANPD, dentro do processo de fiscalização, considerando o poder sancionador estabelecido na Resolução 01, da ANPD, a apuração de infrações decorrentes do não cumprimento da lei, no âmbito da proteção dos dados pessoais, sob a competência do órgão, aceita a denúncia ou mesmo de ofício, determinar, após análise, a abertura de processo administrativo, como medida repressiva, nos termos do Art. 37º, da Resolução 01:

Art. 37. O processo administrativo sancionador destina-se à apuração de infrações à legislação de proteção de dados de competência da ANPD, nos termos do artigo 55-J, IV, da LGPD, podendo ser instaurado:

I - de ofício pela Coordenação-Geral de Fiscalização;

II - em decorrência do processo de monitoramento; ou

III - diante de requerimento em que a Coordenação-Geral de Fiscalização, após efetuar a análise de admissibilidade, deliberar pela abertura imediata de processo sancionador.

Assim, realizada a abertura de processo administrativo, serão implementadas as fases desse processo, que inclusive, para esse ato, não cabe recurso, ou seja, o processo poderá ser aberto, independente de oposição da empresa, conforme consta do Art. 38:

Art. 38. Não cabe recurso administrativo contra o despacho de instauração do processo administrativo sancionador.

Dessa maneira, ainda que a empresa se insurja contra a abertura do processo administrativo, não caberá recurso para a abertura do processo, apenas para o teor do que for apurado no processo administrativo.

Do Procedimento Preparatório da ANPD:

Havendo necessidade, a ANPD poderá realizar procedimentos que sejam preparatórios, para levantar informações, com base nos indícios, para averiguar preliminarmente, sobre a prática e ocorrência de infrações, quando não identificadas de imediato comprovações mínimas necessárias para a abertura do processo administrativo, como assim possibilita o Art. 40 da Resolução:

Art. 40. A Coordenação-Geral de Fiscalização poderá, de ofício ou diante de requerimento, mediante procedimento preparatório, efetuar averiguações preliminares, quando os indícios da prática de infração não forem suficientes para a instauração imediata de processo administrativo sancionador.

Dessa forma, é plenamente possível, a realização prévia de procedimento que seja preparatório para a abertura de processo administrativo, que poderá não ou não correr em sigilo, como fala o parágrafo único do Art. 40º:

Parágrafo único. O procedimento preparatório poderá tramitar em sigilo, no interesse das investigações, a critério da Coordenação-Geral de Fiscalização.

No procedimento preparatório, a ANPD poderá solicitar diligências para tornar possível a abertura do processo administrativo, isso sob a fundamentação do que determina a própria LGPD e o regulamento interno da ANPD:

Art. 41. Quando necessário para o esclarecimento da demanda, a Coordenação-Geral de Fiscalização poderá determinar a realização de diligências, conforme disposto na LGPD, no Decreto nº 10.474, de 2020, e no Regimento Interno da ANPD.

Da Possibilidade de Realização de Termo de Ajuste de Conduta (TAC):

Necessário entender que o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) é um documento normalmente utilizado por órgãos públicos, muito comum seu uso, por exemplo, pelo Ministério Público que, para evitar a penalização direta, em casos que ficou demonstrado certos pontos em favor da outra parte, o ajuste (acordo) para uma determinada conduta, ou seja, essa parte, considerada infratora, se compromete a “ajustar” os pontos que foram objeto da falha apontada e que feriu a lei, de forma que ela possa, dali em diante, passar a cumprir o que for determinado pela lei.

O Art. 43º da Resolução 01 estabelece:

Art. 43. O interessado poderá apresentar à Coordenação-Geral de Fiscalização proposta de celebração de termo de ajustamento de conduta.

Assim, fica estabelecida a possibilidade de realização de um termo de ajuste de conduta, entre a empresa infratora e a ANPD, ficando ajustadas as medidas que deverão ser adotadas e implementadas na empresa, como forma de não mais incorrer em infração.

Da Garantia da Ampla Defesa e do Contraditório:

Como não poderia ser diferente, considerando, inclusive, que se trata de uma garantia da Constituição Federal, a Resolução 01, da ANPD, assegura a todas as empresas, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Art. 45. O processo administrativo sancionador será instaurado pela Coordenação-Geral de Fiscalização, garantindo-se ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, lavrado o auto de infração, decorrente da fiscalização, fica assegurado à empresa acusada de cometer as infrações, o direito a apresentação de defesa, com base no Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 47. Em caso de decisão de lavratura do auto de infração, a Coordenação-Geral de Fiscalização intimará o agente de tratamento interessado para apresentar defesa no prazo máximo de dez dias úteis, na forma indicada na intimação.

Cabendo assim, a empresa autuada apresentar sua defesa, juntando todas as provas que forem consideradas necessárias para atenuar ou excluir sua culpa nas acusações apresentadas pela ANPD. Veja-se:

Art. 50. Cabe ao autuado a prova dos fatos que alegar, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para instrução.

A empresa pode, inclusive, se apresentar em qualquer fase do processo, mesmo que considerada revel, como disciplina o parágrafo único do Art. 50º:

Parágrafo único. Qualquer que seja a fase do processo, nele poderá intervir o revel, sem direito à repetição de qualquer ato já praticado.

É importante explicar que havendo condenação da empresa no processo administrativo, esta poderá recorrer, por meio de recurso, que será apresentado à instância máxima do Conselho Diretor, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da intimação da decisão:

Art. 58. O autuado será intimado para cumprir a decisão de primeira instância ou interpor recurso administrativo ao Conselho Diretor, como instância administrativa máxima, no prazo de dez dias úteis, contados da intimação da decisão.

§ 1º A intimação do autuado encerra a fase de decisão.

§ 2º O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão e deverá ser protocolizado na forma indicada na intimação.

Dessa forma, considerando que o processo fiscalizatório, se inicia com a denúncia, considerando a possibilidade da adoção de medidas preventivas, oriundas daquilo que for disciplinado pelos guias de boas práticas e governança, pela possibilidade de realização de termos de ajustes de conduta, pela abertura de processo disciplinar, pela possibilidade de apresentação de recurso e mesmo assim, em caso de condenação após julgamento da instância máxima do Conselho Diretor da ANPD, o último estágio a aplicação das penalidades ou sanções, conforme já amplamente esgotado anteriormente.

Fica, portanto, o registro para os riscos de condenação no processo fiscalizatório, pois os procedimentos descritos são, sim fortemente embasados em provas que, certamente, podem levar a condenação da empresa. Portanto, ainda que haja atenuantes, as sanções são elevadamente pesadas e, com base na graduação aqui

demonstrada, trazem riscos enormes para as empresas infratoras.

Veja-se que as sanções vão de simples advertências, passando por multas ou ainda a possibilidade de suspensão do direito de tratar dados que, considerando uma penalidade enorme, foi, com base na Resolução 01, acrescido de uma penalidade ainda maior, que é a possibilidade da ANPD, tornar pública a infração ao mercado, causando danos que podem ser irreparáveis à imagem da empresa infratora, pois trará um forte abalo à credibilidade da marca.

Enfim, assim se explica, como a fiscalização se dará nas empresas.

22 Fonte: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/356993/pesquisa-empresas-financeiras-se-adequam-mais-a-lgpd-que-de-servicos>>. Acesso em 22/08/22 às 07h:28min.

23 SEI - Sistema Eletrônico de Informações – Integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônico. Fonte: <<https://www.gov.br/economia/pt-br/aceso-a-informacao/sei/sobre>>. Acesso em 22/07/22 às 07h:35min.

24 Prazo razoável, pode ser considerado aquele, que considerando o volume ou gravidade do evento, poderá ser utilizado pela empresa para prestar as informações à ANPD e aos titulares dos dados, tendo em vista, que a lei determina em regra, que estas informações devam ser apresentadas imediatamente.

25 Site ANPD: <<https://www.gov.br/anpd/pt-br>>. Acesso em 12/08/22, às 10h:12min.

■

CAPÍTULO III COMO A EMPRESA PODE SE PROTEGER?

■

Superada a questão de como ocorrerá a fiscalização, não se pode deixar de pensar, que existem meios para que a empresa possa buscar se proteger, evitando assim, que possa ser alvo de fiscalizações e, claro, de sanções que como já esgotamos anteriormente, não são nada benéficas às empresas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do abalo a imagem.

De mais a mais, não há que considerar, que haja dois universos que direcionam para a aclamada proteção da empresa, senão, aquele que, claramente, indica que a adequação da empresa às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é tida como o único caminho para que a empresa possa se proteger adequadamente, aos riscos de fiscalização e mesmo, de sanções decorrentes do descumprimento da Lei.

A própria inadequação em si, já representa um risco para a empresa, pois uma vez, não estando ela adequada às exigências da lei, esse fato, por si só já representa um risco de fiscalização e mesmo de aplicação de sanções.

Dessa forma, cumpre-nos esclarecer, que a correta adequação da empresa, deve ser o caminho para a busca da proteção e, diga-se de passagem, não há meio termo e não há, segundo meu entendimento, caminho alternativo.

Considerando que todas as empresas, quer públicas ou privadas, deverão, aos olhos da Lei, buscarem a implementação, cabe-nos descrever como se dará esse processo de implementação, visando assim, esclarecer de que maneira ocorrerá a

proteção das empresas, no quesito que diz respeito à se protegerem dos eventos de fiscalizações. Repita-se, de eventuais sanções, derivadas destas fiscalizações ou claro, da não adequação ou mesmo dos riscos de vazamentos de dados pela não adequação e implementação do passo a passo necessário à garantia da privacidade e proteção dos dados pessoais dos titulares de dados de uma empresa.

Assim, questiona-se, mais uma vez: A quem se aplica a Lei?

Repete-se, que a Lei se aplica a todas as empresas, tanto públicas, quanto privadas, que lidam com dados de clientes e funcionários e que, portanto, devem obrigatoriamente, se adequarem às diretivas da Lei.

Dessa maneira, partimos para um segundo e importante questionamento: Toda empresa precisará implementar a LGPD?

Deve-se observar, principalmente, que não importa, por exemplo, o tamanho ou regime tributário da empresa, mas se ela possui na sua atividade, o manuseio de qualquer tipo de dados de clientes ou funcionários e, então, ela obrigatoriamente, irá precisar se adequar.

Podemos utilizar como exemplo, uma pequena padaria que não possui funcionários e, não manipula qualquer dado de clientes - aqui fica clara a questão de clientes internos (os funcionários) e clientes externos (os clientes) - logo, ela não precisará se preocupar com a adequação, mas uma empresa de e-commerce, por exemplo, mesmo que ela tenha apenas um funcionário, precisará se adequar, pela existência de clientes internos e desta maneira, haverá o tratamento de dados desse cliente interno, o funcionário.

É importante lembrar que estar em conformidade com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não é uma tarefa tão simples como algumas empresas e pessoas acreditaram ou pensaram.

De início, cumpre esclarecer, que exige por parte de quem irá realizar a implementação do processo, interação entre aqueles que desenvolverão o trabalho e os responsáveis pelas diversas áreas da empresa e suas equipes. Pois há a necessidade de uma interconexão dos conhecimentos da equipe jurídica, combinando esforços e conhecimentos com a equipe técnica de Tecnologia da Informação (TI), como forma de realizar a interpretação das leis, aplicando metodologias de processos, tecnologias e mesmo de segurança da informação, sempre aliando é claro, à correta interpretação da Lei nesse processo de implementação.

É importante pensar e esclarecer, que a preocupação maior da empresa, não deve se limitar à implementação de ferramentas de controle e segurança dos dados de seus clientes, tais como: instalação de um firewall ou medidas que evitem ataques DDoS (ataque de hackers).

Aqui, cabe um parêntese, para explicar que DDoS são “[...] ataques distribuídos de negação de serviço, que variam de pequenos a sofisticados e grandes, com possibilidade de diminuição da largura de banda e ou interrupções não planejadas em seu sistema ou rede”.

Essa preocupação, claro, tem relevância, pois impacta diretamente no funcionamento da rede ou dos sistemas de informação da empresa, mas a preocupação da empresa, deve-se voltar também para a necessidade de proteção dos dados pessoais, visto que desses ataques podem derivar vazamento dos dados e isso, está ligado à privacidade e proteção dos dados, objeto da LGPD.

Na verdade, vai muito além disso, as empresas precisam, a partir da LGPD, garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, mais do que nunca e esse cuidado, em que pese parecer não tão importante, é sim, de grande relevância no processo e deve ser a preocupação maior da empresa, para salvaguardar os dados de clientes internos e externos sob sua responsabilidade.

Dessa maneira, conclui-se, que a instalação de um novo e mais potente/moderno servidor, um firewall ou um sistema de antivírus, não são suficientes para “fazer o dever de casa”.

A LGPD pode parecer bastante complexa e traz imposições, além de exigir o cumprimento de múltiplas soluções, visando, sobretudo, a garantia da segurança dos dados pessoais de seus funcionários e do seu cliente/consumidor, os verdadeiros titulares dos dados.

Assim, deve-se considerar que a adequação não deve ser realizada por “qualquer pessoa” da empresa (não ao menos, sem formação específica).

Não basta uma adequação contratual e a nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados (DPO), exige-se que a implementação correta, seja realizada por uma equipe ou assessoria devidamente preparada para proteger efetivamente a empresa, criando processos e implementando, por meio de treinamentos, inclusive, uma nova cultura dentro da empresa, para a questão do tratamento dos dados.

O entendimento é aquele de que, deve a empresa, utilizar-se da formação de uma equipe ou de uma assessoria bem-preparada, para realizar o processo de implementação da LGPD. Veja-se o que se entende basicamente, como sendo o que precisa ser feito, ainda que de forma superficial, enquanto explicação:

Questiona-se: Por onde a empresa deve iniciar sua proteção para o que se chama de adequação a Lei?

Ao que descrevemos que, a empresa poderá ou deverá, no processo de adequação, inicialmente:

- 1) Estabelecer as necessidades e o contexto: reunir as equipes e mapear a situação interna no que se refere às operações de processamento de dados, a fim de compreender em que medida a LGPD se aplica ao seu negócio;
- 2) Identificar os riscos: realizar um gap assessment (avaliação das lacunas) (parte legal e técnica) para identificar as providências a serem adotadas;
- 3) Analisar e avaliar os riscos: analisar e definir bases legais para tratamento; avaliar os mecanismos de segurança das bases de dados;
- 4) Definir o projeto de acordo com os riscos: definir responsabilidades; nomear um Encarregado de Proteção de Dados; readequar e documentar os processos internos de tratamento de dados;
- 5) Mapear o fluxo de dados: importante para a definição da nova governança junto a TI dos controles de consentimentos;
- 6) Educar: incentivar a adoção de boas práticas e a mudança na cultura interna (através de treinamentos periódicos, por exemplo) e externa;

7) Após a análise da empresa quanto a parte técnica e jurídica, entender as necessidades da empresa e apresentar diagnóstico acompanhado de um plano de ação, criar, portanto, um programa/projeto de adequação, considerando, além do porte da empresa, as diversas multiplicidades de outras variáveis como por exemplo, quantidade de sistemas, formas de entrada de dados, etc.

Dito isso, pode parecer simples a questão da implementação da LGPD, mas o processo não é tão simples e de forma resumida, apenas com o cunho de esclarecer, a implementação na prática é significativamente muito mais complexa e recheada de detalhes e análises, que visam fechar todas as lacunas, porventura existentes na empresa, quanto à proteção de dados pessoais dos titulares.

Assim, considerando a necessidade de adequação das empresas, após a adoção das medidas descritas na Lei, deverá a empresa, ao final do processo de adequação, apresentar os requisitos de conformidade com a LGPD.

E que, conforme explicado inicialmente, deverá a empresa adotar todas as ações preventivas e necessárias para atender ao que determina a Lei nº 13.709/2018. Ainda que resumidamente, deve-se entender como requisitos básicos para que a empresa possa estar minimamente em conformidade com a LGPD. Vejamos:

- A empresa deverá após estabelecer as necessidades e o contexto, ou seja, após reunir as equipes e mapear a situação interna no que se refere às operações de processamento de dados, ter compreendido de forma clara, em que medida a LGPD se aplica ao seu negócio;

- Também deverá, após identificar os riscos, por meio da realização do gap

assessment (avaliação das lacunas) tanto da parte legal quanto da parte técnica, ter identificado quais as providências deverão ser adotadas no processo de adequação da empresa;

■ Deverá, após a análise e avaliação dos riscos, definir bases legais para tratamento e aplicar todos os mecanismos de segurança necessários às bases de dados da empresa;

■ Após a definição do projeto, de acordo com os riscos detectados, definir as responsabilidades, nomear um Encarregado de Proteção de Dados, readequar e criar todos os contratos, documentar todos os processos internos de tratamento de dados e criar uma política de privacidade de dados;

■ Após mapear o fluxo de dados, que como se sabe, é muito importante para a definição da nova governança junto a área de tecnologia da informação, por meios das ferramentas de controles;

■ Após os treinamentos educacionais e periódicos, por exemplo, buscar incentivar e manter a adoção de boas práticas e, principalmente, buscar incutir as mudanças da cultura interna e externa nos processos da empresa;

■ Após a implementação de todo o projeto desenvolvido e, após elaboradas e revisadas: as políticas de privacidade (internas e externas); os contratos com colaboradores e contratos com terceiros, que impliquem no processamento de dados, inclusive, com empresas parceiras (operadoras) e, após a revisão de todos os contratos com os parceiros e fornecedores que realizem tratamentos de dados, a empresa deverá assegurar-se de que buscou todos os meios para garantir sua execução;

■ Após registrar todo o processo de implementação da LGPD, a empresa deverá, por óbvio, documentar todas as análises e todos os procedimentos, implementando os registros de Processamento de Dados internos na empresa;

■ Além disso, deverá monitorar e notificar, ou seja, organizar uma política de tratamento dos incidentes para garantir o cumprimento de requisitos de comunicação às autoridades em caso de vazamento ou uso indevido de dados pessoais;

■ Deverá criar um Modelo de Resposta e, ao elaborar o modelo de resposta para cada incidente, encaminhá-lo ao Órgão Controlador, visando evitar multas e sanções às infrações detectadas.

Por fim, tais iniciativas aqui descritas, visam, sobretudo, informar as empresas sobre a necessidade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, com vistas a evitar as possíveis sanções previstas em Lei, esclarecendo os cuidados que deverão ser adotados. Além, é claro de gerar uma compreensão sobre os mecanismos e controles internos de cada empresa, bem como, buscando evitar o tratamento de dados com fins discriminatórios, incidentes de vazamento de dados, indicando de forma clara às empresas, sobre as principais ameaças e riscos presentes nos ambientes corporativos.

CAPÍTULO IV ADEQUAÇÃO PARA ALÉM DAS SANÇÕES

Imaginar e entender que as medidas e iniciativas descritas anteriormente, visam, trazer informações às empresas sobre as necessidades de se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, evitando as sanções previstas na Lei. Além disso, tem como objetivo esclarecer sobre os cuidados que deverão serem adotados, como forma de gerar nas empresas, compreensão sobre os mecanismos e controles internos, bem como, evitar que haja o tratamento de dados de forma discriminatória, evitar também, que hajam incidentes de vazamento de dados, indicar de forma clara para as empresas, sobre as principais ameaças e riscos que podem ocorrer nos ambientes corporativos é sim, um excelente ponto de partida para a busca da adequação empresarial, porém, a empresa não deve se limitar a essa questão, pois o processo de adequação ao final, não se limita a isso. E é exatamente sobre esse ponto que se pretende realizar uma investigação aqui.

Ainda que seja um fator extremamente relevante, cuidar para que a empresa evite fiscalizações e diminua os riscos de vazamentos e, claro, se livre de sanções que são considerados como já se disse antes, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do abalo à imagem, fatores que, com o passar do tempo não serão mais os únicos pontos a serem retratados como preocupantes nas empresas, se considerarmos, que as adequações trazem benefícios que certamente, vão além da necessidade de evitar sanções.

Aqui, não se trata apenas da empresa buscar proteção, por via da adequação à Lei, protegendo adequadamente os dados pessoais dos funcionários e clientes, trata-se de algo que, como dissemos, estão classificados como tão relevantes que vão para além dos riscos mencionados e que se amoldam ao descumprimento da Lei.

Não se trata apenas, da falta de alternativa ou da falta de escolha por um caminho alternativo à adequação, trata-se de olhar para um novo cenário no campo empresarial que trará, sem dúvida alguma, mudanças relevantes para como as empresas funcionam e como elas irão cuidar de suas marcas, de seus nomes no mercado.

Do que exatamente está se falando?

Fala-se que, muito se descreveu como sendo todas as empresas, passíveis de sanções que se resumiam, a princípio, em:

a) Advertências;

b) Multas;

c) Da possibilidade de suspensão do direito de tratar dados pela empresa, pelo de 30 (trinta) podendo chegar a 180 (cento e oitenta) dias;

d) Da possibilidade de responder judicialmente, por ações indenizatórias, que no Brasil, já passam de 600 decisões judiciais com base na LGPD, além de diversas multas em processos administrativos, aplicadas por órgãos como o PROCON.

E, como também até já fora explicitado, além da possibilidade de suspensão do direito de tratar dados, que já se considera uma penalidade muito gravosa, pois pode, por exemplo, tirar da empresa a possibilidade de emitir seu faturamento mensal (que é uma forma de tratar dados) pelos prazos acima mencionados, o

que impactaria de forma grave na manutenção das atividades de muitas empresas, visto que, muitas delas não sobreviveriam por dois, três meses ou mais, tendo que honrar com todos os custos operacionais, folha de pagamento, impostos, sem a entrada de receitas, vindo a literalmente ter problemas, onde várias delas, poderiam até mesmo, ter que encerrar suas atividades, em razão do evento da suspensão do tratamento de dados.

Nesse caso, chamamos a atenção para o que fora trazido pela Resolução 01 - que tratou de definir o processo fiscalizatório - como sendo um agravamento ou uma gradação dessas penalidades, que seria o que se pode descrever como:

A possibilidade de a ANPD tornar pública a infração ao mercado, causando danos que podem ser irreparáveis à imagem da empresa infratora, pois trará um forte abalo à credibilidade desta empresa.

Daí, tem-se o fato de que para além das sanções, as empresas já começam a enxergar que existe um dano, considerado muito maior e que vai para além das sanções, que sem dúvida alguma, impactam financeiramente na vida das empresas, mas que é potencialmente considerado um dano maior, que é o dano à sua imagem e que, em muitos casos, não podem ser reconstruídos a curto prazo, nem mesmo com altos investimentos financeiros que se destinariam a reverter tais cenários, pois abalam mais do que os cofres, abalam a própria credibilidade da empresa no mercado.

O fato é que, as empresas passarão a ser cobradas e por que não dizer, escolhidas, selecionadas, basicamente em dois grupos, aquelas empresas que estão adequadas e aquelas empresas que não estão adequadas. Isso funcionará como um diferencial de mercado, pois cada dia mais as empresas e as pessoas irão tratar a adequação como algo relativo à sua reputação o que, certamente, trará cada vez mais explícito, o caráter de competitividade para as empresas.

Quando se fala de desta “escolha”, pode-se observar por duas ópticas, aquela relativa aos Bancos, às empresas fornecedoras e empresas parceiras que, considerando a responsabilidade que pela Lei é solidária, ou seja, se uma está adequada e outra não. A que está adequada possui a metade da responsabilidade por indenizar o titular de dados em casos de vazamento por aquela empresa que não se adequou e isso passará a ser uma exigências das grandes empresas e em caso de não adequação, será um motivo para negativa de contratação ou de desenvolvimento de negócios ou serviços.

De outro ponto de vista, tem o olhar do próprio titular de dados, que em muito pouco tempo, estará preparado culturalmente, para escolher dentre as empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos, para decidir com qual delas vai preferir contratar, pois aquelas empresas que estão adequadas, cuidarão dos seus dados e isso, certamente, se tornará um diferencial de mercado.

Veja-se que, a adequação deixará de ser “apenas” um conjunto de medidas que visam, a princípio, cumprir a Lei, protegendo os dados pessoais em tratamento com mecanismos para evitar ataques cibernéticos evitando vazamento de dados. Passa a ser muito mais do que isso.

Além disso, a ideia principal aqui, é que para além da adequação enquanto cumprimento das exigências da Lei, existem vários benefícios que são trazidos para as empresas por meio da adequação e que, por vezes, não são levados em conta ou, considerados como tais (benefícios).

O Diferencial Enquanto Valor Agregado: A ideia primeira a ser abordada aqui é o valor que é trazido para a empresas, considerando os aspectos anteriormente abordados que se somados, redundam em pontos extremamente positivos na vida das empresas, elevando o seu valor de mercado.

A Competividade: Outro ponto interessante a se pensar é que, com o passar dos dias, mais e mais empresas buscarão a implementação e a adequação às regras impostas pela Lei e isso, quando espelhado em outras empresas gerará um segundo fator importante, que está diretamente ligado à competitividade entre as empresas.

A Credibilidade: Esse é um dos pontos mais relevantes que podem ser observados nas empresas após sua adequação e que, certamente se obtém com a adoção das medidas de segurança, pois uma vez adequada, a empresa passa a contar com maior credibilidade, visto que, ao demonstrar preocupação com a privacidade e com proteção dos dados dos titulares, aumenta naturalmente, a confiança de todo um mercado consumidor, pois como dito, no processo de escolha, tanto as pessoas, como as empresas parceiras, fornecedores passando, inclusive, a ser um gerador de novos negócios à empresa, pois a credibilidade tende a aumentar.

A Segurança dos Dados na Empresa: Veja-se que para que uma empresa se adeque às regras da Lei ela precisa, primeiramente, como até já explanamos anteriormente, reunir suas equipes, mapear toda uma situação interna, identificando como se dão suas operações de processamento de dados, buscando compreender em que medida a LGPD se aplica ao seu negócio. Nesse processo, a empresa deverá identificar todos os riscos, realizando um gap assessment, que nada mais é, do que uma avaliação das lacunas, porventura existentes na empresa, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista técnico, para que assim, possa identificar quais providências devem ser adotadas a partir dali e além disso, a empresa fará uma análise, uma avaliação desses riscos para então, definir quais bases legais utilizará para o tratamento de dados.

Veja-se que houve aí, em verdade, uma avaliação criteriosa dos mecanismos de segurança dos dados existentes e a serem implantados e tratados na empresa. O que significa que a adoção de medidas de segurança em cada departamento da empresa representará maior segurança para toda a empresa, pois, a partir dos critérios que passarão a ser adotados por cada departamento, quando somados

aos treinamentos de conscientização, mudança na cultura interna da empresa, tornarão essa empresa, muito mais segura.

Dessa maneira, as empresas começam a entender, por fim, que Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não se ocupou apenas em intervir na vida das empresas, apenas para fazer cumprir com os cuidados em relação à privacidade e proteção dos dados, mais do que isso, indiscutivelmente, trouxe uma nova cultura para essas questões (de privacidade e tratamento de dados) e para todo um trabalho de conscientização e difusão dessa nova cultura no tratamento dos dados, elevando a condição de como esses dados serão de agora em diante, tratados dentro das empresas.

Importante é que as empresas passarão a ver todo esse processo, não apenas como obrigação legal, mas principalmente, para além do respeito aos direitos fundamentais dos titulares de dados que passaram a ser ampliados para questões outras que, como dito, vão desde o desenvolvimento de uma nova cultura dentro das empresas, gerando para estas maior credibilidade, maior confiabilidade por parte de clientes, fornecedores e empresas parceiras, maior competitividade entre as empresas, maior segurança interna dos dados dentro das empresas, agregando por via de consequência, maior valor agregado como diferencial de mercado, desenvolvimento e fixação da imagem da marca dessas empresas.

Dessa maneira, conclui-se que, a adequação está seguramente para além das sanções, mas está sim, embasada em uma nova diretriz. A saber, uma nova cultura, um novo rumo que são, em especial, o diferencial de valor agregado, que perpassa para a criação de uma nova era, a era do respeito aos direitos fundamentais.

PARTE IV

■

BÔNUS

CAPÍTULO I CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO

Ao final de leituras como esta, me parece razoável pensar “O que devo fazer agora? ou “Quem devo procurar para me ajudar a implementar a LGPD em minha empresa?” ou ainda “Existem assessorias jurídicas e profissionais que entregam esses serviços para que eu possa continuar focado na minha atividade?” A resposta é sim para quase todas as perguntas.

A partir de agora, acredita-se que já tenha ficado claro, ainda que minimamente, sobre a importância da privacidade dos seus dados e especialmente, a proteção dos dados pessoais de todas as pessoas, especialmente, dentro de cada empresa que se utiliza de dados para gerir suas mais diversas atividades empresariais.

Diante disso, é muito importante entender que já existem consultorias jurídicas especializadas em Privacidade e Proteção de Dados e mais, existem aquelas que, eu, juntamente com um time de especialistas em Direito Digital, que para além de tratar da questão da Privacidade e da Proteção dos Dados, nos especializamos na adequação e na implementação da LGPD nas empresas. Portanto, buscar profissionais que tenham conhecimentos sólidos em Segurança Digital, Governança e Gestão de Dados é sim uma das principais formas de entender o que devem as empresas, fazer de agora em diante. A quem deve, exatamente, buscar enquanto ajuda, para implementar a LGPD na sua empresa, visto que já existem sim, consultorias jurídicas e profissionais com formação e especialização em DPO – Data Office Protection, ou como descrito na Lei brasileira, Encarregado de Proteção de Dados, o Encarregado.

As empresas, ao contratar um profissional ou ao buscar uma consultoria jurídica para realizar sua adequação, deve observar de forma criteriosa alguns requisitos

importantes. Vejamos.

A empresa que está buscando, enquanto consultoria jurídica para implementação das regras impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deve apresentar em seu escopo de negócios, qualificação para elaboração dos projetos de adequação a LGPD.

Deve estar habilitada para apresentar pareceres e consultas jurídicas sobre o assunto em específico, deve estar apta a prestar orientação sobre as regras da Lei, bem como, orientações sobre todas as regras de confidencialidade e privacidade, deve atuar na elaboração de cronogramas de implementação, desenvolvimento de termos, documentos e atuar com um foco importante que é a implementação de Políticas Internas de Privacidade, além de realizar um acompanhamento da estruturação junto aos departamentos de Tecnologia e Administrativo.

Outro ponto importante é a capacidade de análise e elaboração de documentos: como por exemplo, desenvolvimento de Políticas de Privacidade, desenvolvimento de termos de uso e condições, desenvolvimento de regras para estrutura interna voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, desenvolvimento de políticas trabalhistas igualmente voltadas para a mencionada Lei, não se esquecendo de que o mapeamento dos dados coletados, a orientação sobre o tratamento de dados, o treinamento e capacitação de todos os colaboradores, parceiros e prestadores de serviços em relação aos programas e políticas elaborados (Controlador e Operador), são pontos indispensáveis para levar em consideração no ato da contratação de uma consultoria jurídica que se proponha trabalhar com a implementação da Lei e adequação de empresas às exigências legais.

O escritório de consultoria jurídica deve se propor a atuar na implementação da LGPD, considerando, por exemplo, que o assessoramento à empresa deve ocorrer em todo o ciclo de adequação, desde o diagnóstico até a

adequação/implementação da final da LGPD, dando tratamento, por exemplo, a alguns tópicos que consideramos relevantes.

Apresentação de um Diagnóstico de Privacidade: Considerado o ponto de partida para a adequação da empresa às regras das LGPD, tem-se que este, é o trabalho de entrada que permitirá identificar a maturidade dos processos internos da empresa e os gaps (lacunas) que devem ser trabalhados para atender às exigências da LGPD.

A partir deste serviço, deverá ser elaborado um plano de ação, que deverá ser validado pela empresa contratante. As atividades listadas no plano de ação, podem ser realizadas pela equipe do cliente ou pela equipe da consultoria jurídica especializada, incluindo a própria gestão do projeto.

Apresentação de um Diagnóstico em Segurança Cibernética para a LGPD: De certo que a LGPD estabelece a necessidade de revisar ou incrementar mecanismos de proteção em cyber security, estes, de competência da área de TI (Tecnologia da Informação), por meio de trabalhos integrados entre a equipe da consultoria e a equipe TI da empresa, cujos mecanismos, visam identificar as fragilidades cibernéticas e apresentar as respectivas soluções de mitigação.

Apresentação de um Projeto de adequação: Deverá ser apresentado, após o diagnóstico, um projeto para adequação da empresa, sendo que, é através deste serviço que será possível a consultoria jurídica adequar sua empresa ao projeto de adequação à LGPD.

Por meio da consultoria jurídica, sua empresa poderá contemplar a execução de um projeto de ponta a ponta, incluindo a gestão desse projeto, ou, se for o caso, apenas a construção dos artefatos demandados pela LGPD, tais como: Plano de Contingenciamento, Plano de Recuperação de Desastres, Política de Segurança,

Política de Privacidade e, Plano de Resposta a Incidentes, dentre outros.

No escopo do projeto de adequação, tem-se, que um dos principais elementos é: o data mapping.

Que consiste no mapeamento de dados, ou ainda, o flow (fluxo dos dados) ou mesmo o inventário de dados, que se referem a um documento essencial quando do processo de adequação às normas de proteção de dados (LGPD). Ele determina a necessidade de criação das regras e dos procedimentos, Termos de Uso, Política de Privacidade, enfim, os desdobramentos e a mudança de cultura da empresa em face da LGPD.

Deve-se entender que, a eleição de prioridades é um ponto importantíssimo de todo o projeto, sendo que, a prioridade primeira da lista, nesse caso, está diretamente ligada à compreensão do impacto da LGPD na empresa e deve obter a adesão do gestor, do sócio e ou do dono da empresa, apresentando a importância de uma Política de Privacidade e solicitando suporte, incluindo orçamento e recursos.

O segundo passo consiste em designar uma pessoa responsável pela proteção de dados, que possa implementar as medidas regulamentadas ou até mesmo, designar a formação de um comitê de implementação da LGPD.

Existe ainda, a importância de se identificar as atividades de processamento da empresa e o perfil de dados que ela é responsável, sendo este, o terceiro ponto da lista de prioridades. Para isso, é necessário definir uma metodologia de mapeamento desses dados e registrar o processo dos operadores de privacidade, para rever, periodicamente, o “ciclo de vida dos dados”.

Há um quarto passo que consiste na determinação do papel e das obrigações que a empresa tem como um controlador ou operador.

Após isso, é necessário fazer a comunicação das mudanças aos funcionários da empresa e proceder com a atualização dos contratos, com funcionários, fornecedores e clientes, para que estejam cientes das novas regras da empresa.

E, não menos importante, deve-se avaliar os riscos de privacidade ligados ao processamento de dados da empresa. Sendo que, para isso, deve-se implementar uma etapa de avaliação de risco de privacidade dos dados, considerando os riscos para os “donos” das informações tratadas, sendo este, um ponto importante para que esse item seja executado.

Ainda sobre as prioridades, tem-se a necessidade de implementação de um programa de gerenciamento de dados, para cobrir os requisitos da LGPD, com base nos riscos identificados na etapa anterior.

Em sétimo lugar, está a necessidade de definição de uma base legal para as atividades de processamento de dados da organização. Para isso, será necessária uma equipe ou indivíduos responsáveis por definir as bases jurídicas das quais a empresa depende.

Há ainda, no rol de prioridades, a necessidade de definir medidas técnicas para uma segurança de dados eficaz e relatórios internos que reportem sobre os incidentes de segurança para que, se necessário, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) seja notificada.

Toda empresa que tem envolvimento com terceiros, sejam empresas, indivíduos

ou clientes. Diante disso, na lista de prioridades, existe a importância de identificar todos os terceiros com que a empresa compartilha dados pessoais e, a partir daí, estabelecer uma gestão responsável por esses dados.

Necessário, ainda, identificar o fluxo de dados com organizações internacionais e estabelecer um mecanismo de transferência de dados seguro (se for o caso, da empresa operar com a transferência ou compartilhamento internacional de dados).

Existe também, a necessidade de criação de processos eficazes na transparência de dados e direito à privacidade.

E, por último, a necessidade de criação de um programa de conscientização, que treine os funcionários e parceiros, sobre os requisitos da LGPD na empresa.

Nesse processo de treinamento e conscientização, chamamos a atenção para o fato de que todo esse processo, pode variar de 03 (três) meses a 01 (um) ano, dependendo do porte e do número funcionários existentes na empresa, mas que pelo seu caráter de renovação, deve ser contínuo dentro da empresa, até como forma de preparar os novos colaboradores que vão sendo admitidos ao time das empresas.

Realização de Treinamentos: Necessário ainda, o treinamento, para que a equipe da sua empresa esteja preparada para incorporar a cultura mínima necessária ao projeto de implementação.

Desta forma, a consultoria deve propor e ministrar treinamentos para os colaboradores, orientando sobre as boas práticas, bem como, sobre quais

cuidados devem ser tomados no dia a dia, com vistas a manter os ditames da LGPD.

Nomeação de um DPO – Data Protect Office/Encarregado de Proteção dos Dados: O Encarregado de Proteção de Dados é uma função obrigatória pela lei, em todas as organizações brasileiras, conforme dispõe o Art. 41 da LGPD.

Alternativamente, caso a empresa não possua profissional com formação e treinamento adequados ou não disponha de tempo hábil para a formação deste profissional, poderá optar por terceirizar o serviço, enquanto realiza a formação do profissional interno ou mesmo para reduzir o custo fixo mensal da empresa.

A terceirização dos serviços de um DPO/Encarregado de Proteção de Dados, é uma solução prática e de baixo custo para organizações que não possuem a expertise e os conhecimentos necessários para nomear seu próprio DPO - Data Protection Officer, ou de acordo com a Lei brasileira: o Encarregado – Encarregado de Proteção de Dados.

O serviço apresentado, consiste na terceirização da figura do DPO/Encarregado de Dados, em empresas de variados portes e segmentos, incluindo todas as atribuições e responsabilidades associadas ao mesmo, nos termos das exigências dos Art. 5, Inciso VII, Art. 23, Inciso III e, especialmente do Art. 41 da Lei 13.709/18, a saber, a LGPD.

Respeitada a liberdade da empresa em realizar uma pesquisa de preço e coleta de informações sobre a terceirização dos serviços acima, durante ou após a fase de adequação, a empresa deve observar, cuidadosamente, se a consultoria jurídica possui pessoal capacitado que pode atuar como DPO/Encarregado de Proteção de Dados, assessorando sua empresa no atendimento de todas as demandas da LGPD, atendendo o que dispõe o Art. 41 da Lei e demais exigências que a

função requer.

Vale dizer que o DPO/Encarregado de Proteção de Dados, pode ser contratado de forma exclusiva ou compartilhada com outras empresas, devendo sempre observar o atendimento ao SLA das solicitações. A grande vantagem de dispor de um DPO, é que não se faz necessário investir na capacitação e retenção de recursos internos, pois o serviço deve ser prestado de forma contínua na empresa, conforme determina a lei.

Diante disso, em algum momento você se questionará: Quais as vantagens e desvantagens da implementação da LGPD na minha empresa?

Considerando que as pessoas estão cada vez mais seletivas e deixando de lado a imposição legal, temos de início, a vantagem competitiva, o diferencial de mercado, pois os clientes (novos e antigos), questionarão cada vez mais, se a plataforma da empresa está adequada para proteger os dados desses clientes, que ficam sob a guarda da empresa, em detrimento, por exemplo, do contrato de prestação de serviços em que há, o compartilhamento de dados, quer no sistema interno, quer com às instituições bancárias (Controlador e Operador). A não existência da política, que estará cada vez mais, elevando-se os riscos que serão suportados por ambos e, as empresas quer pequenas, médias ou grandes, de qualquer segmento, não irão mais ignorar a não adequação, doravante.

Dentre as desvantagens, podemos enumerar como sendo, as principais, as demandas judiciais e as sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que se iniciam com as advertências, multas. Importante frisar, que as penalidades começaram a ser aplicadas desde agosto de 2021.

Nesse mesmo sentido, a ANPD ainda poderá determinar como sanção, que a

empresa seja impedida de tratar dados por até 180 (cento e oitenta) dias, o que somado ao que dispõe a Resolução 01 da ANPD que poderá, com base no Art. 48, parágrafo 2º da LGPD, verificada a gravidade do incidente, caso necessário para a salvaguardar os direitos dos titulares, determinar ao controlador, a adoção de providências, como: a ampla divulgação do fato em meios de comunicação e; adoção de medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente ocorrido na empresa, o que particularmente, consideramos uma das grandes desvantagens da não implementação, uma vez que isso poderá afetar diretamente na imagem da empresa.

Além do que, um dos grandes riscos/desvantagens, advém do maior agente fiscalizador (o cliente, consumidor e funcionário) que poderão ajuizar, desde 18 de setembro de 2020, ações judiciais, em decorrência de problemas causados pela não implementação das determinações da LGPD e ou por vazamento e ou compartilhamento indevido de seus dados.

Há que se considerar, em especial, que os clientes, consumidores, funcionários, são os titulares dos direitos sobre os dados e podem, a qualquer tempo, solicitar: acesso, retificação, exclusão e até cancelamento dos dados, além é claro, de podem ingressar com as medidas judiciais cabíveis em caso de descumprimento.

Avaliar o custo para implantação das exigências da LGPD:

Questiona-se: O custo para implementação é muito alto?

Esse custo é inviável para uma microempresa, por exemplo?

Veja-se que, o custo da implantação é considerado baixo, em detrimento dos

elevados riscos e das implicações decorrentes da não adequação, inclusive, guardadas as proporções de uma grande empresa, cujo custo de implementação é infinitamente maior.

Por fim, é importante esclarecer, que a preocupação maior de uma empresa, não deve se limitar à implementação de ferramentas de controle e segurança dos dados de seus clientes, tais como: instalação de um firewall (físico ou software) ou mesmo, medidas que evitem, por exemplo, ataques de hackers aos dados, simplesmente.

Na verdade, a preocupação da empresa deve ir muito além disso, as empresas precisam, a partir da entrada em vigor da LGPD em 18 de setembro de 2020, garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Mais do que nunca, esse cuidado, em que pese parecer não tão importante, é sim, de grande importância no processo como um todo e deve ser a preocupação maior da empresa para salvaguardar os dados de clientes e funcionários sob sua responsabilidade.

Dessa maneira, conclui-se que a instalação de um novo e mais potente/moderno servidor, um firewall ou um sistema de antivírus, não são medidas suficientes para considerar feito “o dever de casa”, mas a contratação de uma consultoria bem-preparada pode sim, resolver tanto os problemas da área de segurança da informação quanto os problemas do ponto de vista legal.

Seguindo esse viés, fica claro, que sua empresa deve, como primeiro passo, buscar o entendimento de que, a consultoria jurídica que será contratada, para realizar todo o processo de implementação da LGPD, deverá apresentar e alinhar dois perfis profissionais necessários: um profissional que será responsável pela parte de tecnologia e outro profissional que será responsável pela parte jurídica e que, nesse caso, deve dominar a nova Lei. Mais importante ainda é que essa consultoria jurídica conte com profissionais que dominam as duas áreas, pois esses dois perfis são indispensáveis para o projeto de adequação da empresa.

Como dito, a LGPD, muito embora seja uma Lei de menos de 65 (sessenta e cinco) artigos, mas é considerada complexa, do ponto de vista de ser colocada em prática, pois traz muitas imposições e exige o cumprimento de múltiplas soluções, visando a garantia da segurança dos dados pessoais dos seus clientes, consumidores e de funcionários.

Dessa forma, há que se questionar: Sua empresa já está preparada para a implementação da LGPD?

Qual consultoria jurídica sua empresa buscará para solucionar os problemas de segurança, privacidade e proteção de dados, que devem ser resolvidos por meio da adequação da sua empresa utilizando-se da implementação do que determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais?

Para o esclarecimento de dúvidas, informações e mais esclarecimentos sobre o tema, disponibilizamos o site: www.moraiseadvogados.adv.br. Ou ainda, por meio das redes sociais: @moraiseadvogados pelo Instagram ou Facebook - Moraes & Advogados ou ainda, pelo perfil pessoal do autor @celsodemorais.

REFERÊNCIAS

■

BARBIERI, Carlos. Governança de Dados: Práticas Conceitos e Novos Caminhos. 1ª ed. Ed. Alta Books, 2019.

BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. 3ª ed. Ed. Forense. 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Acesso em 09 de dez. 2021.

CRESPO. Marcelo Xavier de Freitas. Crimes Digitais. 1ª. ed. 2ª tiragem. Ed. Saraiva, 2011.

DONDA, Daniel. GUIA PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD: Conheça estratégias e soluções para adequar sua empresa em conformidade com a lei. 1ª ed. Ed. Labrador. 2020.

DONEDA, Danilo. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais: Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. 3ª ed. Ed. Thompson Reuters Brasil. 2021.

GARCIA, Lara Rocha. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): guia de implantação/Lara Rocha Garcia; Edson Aguilera-Fernandes; Rafael Augusto Moreno Gonçalves; Marcos Ribeiro Pereira-Barretto. 1ª ed. Ed. Bucher. 2020.

LEÃO. Ana Patrícia Dantas. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1ª ed. Ed. ESA. 2015.

MALDONADO, Viviane Nóbrega, Opice Blum, Renato, Coordenadores. COMENTATÁRIOS AO GDPR: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. - 3 ed. – São Paulo: Tomson Reuters Brasil, 2021.

MARINHO. Fernando. OS 10 MANDAMENTOS DA LGPD: Como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados em 14 passos. 1ª ed. – Ed. Atlas. 2020.

OPICE BLUM, Renato. PROTEÇÃO DE DADOS: Desafios e soluções na adequação à lei. Alessandra Borelli Vieira ... [et al.]; organização Renato Muller da Silva Opice Blum. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.

PINHEIRO. Patricia Peck. DIREITO DIGITAL. 5ª ed. Ed. Saraiva. 2012.

PINHEIRO. Patricia Peck. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: Comentários à Lei 13.709/2018. 3ª ed. Ed. Saraiva Jur. 2021.

SALES. Fernando Augusto de Vita Borges. MANUAL DA LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados. 1ª ed. Ed. Mizuno, 2021. Direito Digital Disponível em:

<https://www.projuris.com.br/direito-digital/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20direito%20digital,espa%C3%A7os%20e%20em%20aparelhos%20eletr%C3%A9ticos>
Acesso em 26 de ago. 2022.

Empresas financeiras se adequam mais à LGPD que de serviços. Ribeirão Preto. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/356993/pesquisa-empresas-financeiras-se-adequam-mais-a-lgpd-que-de-servicos>. Acesso em 22 de ago. 2022.

Empresas não conseguem se adequar a lei de proteção de dados – pesquisa. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/empresas-nao-conseguem-se-adaptar-a-lei-de-protecao-de-dados-diz-pesquisa/>. Acesso em 12 de dez. 2021.

GDPR — General Data Protection Regulation — Regulamento Geral de Proteção de Dados. Disponível em: <https://www.hscbrasil.com.br/gdpr/#:~:text=Em%2025%20de%20maio%20de,en>
Acesso em 09 de dez. 2021.

Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor - notícia. Brasília. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-entra-em-vigor>. Acesso em 16 de ago. 2022.

Projeto de lei geral de proteção de dados pessoais é aprovado no Senado. Brasília. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/07/10/projeto-de-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-e-aprovado-no-senado>. Acesso em 16 de ago. 2022.

SÚMULA N. 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet. Primeira Seção, em 13.12.2006 DJ 14.02.2007, p. 246, Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/electronica/stj-revista-sumulas-2012_28_capSumula334.pdf. Acesso em 18 de ago. 2022.

Telecomunicações como serviços essenciais. Brasília. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/electronica/stj-revista-sumulas-2012_28_capSumula334.pdf. Acesso em 18 de ago. 2022.

Vazamento de dados Serasa. São Paulo. Disponível em: <https://tecnoblog.net/428888/procon-sp-nao-gostou-das-respostas-do-serasa-sobre-vazamento-de-dados/>. Acesso em 09 de dez. 2021.

Vazamento de dados Facebook. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-eleva-para-87-milhoes-o-n-de-usuarios-que-tiveram-dados-explorados-pela-cambridge-analytica.ghtml>. Acesso em 09 de dez. 2021.